Paolo Grossi

Mitologias jurídicas da modernidade

2ª Edição
Revisada e Ampliada

- Tradução de Arno Dal Ri Júnior -

FUNDAÇÃO
BOITEUX

Florianópolis
2007

Obra original publicada na Itália (2001) com o título
MITOLOGIE GIURIDICHE DELLA MODERNITÀ
© Dott. A. Giuffrè Editore, S.p.A.
Via Busto Arsizio, 40 - 20.151 Milano

© Edição brasileira: Fundação José Arthur Boiteux - Universidade Federal de Santa Catarina
© Arno Dal Ri Júnior

Ficha Catalográfica

G878m Grossi, Paulo
Mitologias jurídicas da modernidade. 2. ed. rev. e atual. / 2. ed. rev. e atual. / Paulo Grossi; tradução de Arno Dal Ri Júnior – Florianópolis: Fundação Boiteux, 2007.
160p.

Tradução de: Mitologie giuridiche della modernità
Inclui bibliografia
ISBN: 85-87995-30-8

1. Direito – História. 2. Cultura e direito. 3. Modernidade. I. Dal Ri Júnior, Arno. II. Título.

CDU: 34(091)

Catalogação na publicação por: Onélia Silva Guimarães CRB-14/071

EDITORA FUNDAÇÃO BOITEUX

Presidente Prof. Orides Mezzaroba
Vice-Presidente Prof. Ubaldo Cesar Balthazar
Secretária-Geral Prof. Leilane M. Zavarizi da Rosa
Secretário Adjunto Prof. José Isaac Pilati
Tesoureiro Geral Prof. Aires José Rover
Tesoureiro Adjunto Prof. Carlos Araújo Leonetti
Orador Prof. Luiz Otávio Pimentel

Conselho Editorial Prof. Aires José Rover
Prof. Antonio Carlos Wolkmer
Prof. Arno Dal Ri Júnior
Prof. José Rubens Morato Leite
Prof. Mário Lange de S. Thiago
Prof. Orides Mezzaroba
Prof. Luis Carlos Cancellier de Olivo
Prof. Luiz Otávio Pimentel

Coleção "Arqueologia Jurídica"
Cátedra Aberta da Fondazione Cassamarca
Sob a direção de Arno Dal Ri Júnior

Diagramação Studio S Diagramação & Arte Visual
(48) 3025-3070 – studios@studios.com.br

Revisão Arno Dal Ri Jr.

Endereço UFSC – CCJ – 2º andar – Sala 216
Campus Universitário - Trindade
CEP 88036-970 - Caixa postal 6510
Florianópolis - SC - Brasil
Tel/Fax: (48) 3233-0390
E-mail: livraria@funjab.ufsc.br
Site: www.funjab.ufsc.br

Aos caros e não esquecidos alunos do
"Curso de Pós-Graduação-Mestrado
em Direito" da primavera de 2005 na
Universidade Federal do Rio Grande do Sul

"J'ai fait comme ces médecins qui,
dans chaque organe éteint, essayent
de surprendre les lois de la vie"

Alexis de TOCQUEVILLE, *L'ancien régime*
et la Révolution, Avant-propos

PREFÁCIO

Publico aqui, ligados por algumas notas introdutórias iniciais e sobretudo por um mesmo tema de fundo, quatro ensaios que têm por tarefa denunciar em voz alta, perante um público mais amplo do que os poucos historiadores do direito de sempre, simplismos e mitologias que constituem uma pesada hipoteca sobre a consciência do jurista italiano e europeu (ao menos na Europa continental). Ensaios que têm por tarefa pedir uma reflexão mais vigilante e mais contundente sobre um acúmulo de noções e princípios fundamentais da civilização jurídica moderna, considerados patrimônio supremo e indiscutível para a atualidade e para o amanhã.

O historiador do direito vem, desse modo, tirar a paz dos juristas continentais, que mais parece uma sonolenta imobilidade. Seria interessante se esta obra servisse como uma contribuição mínima para a aquisição de uma consciência culturalmente mais complexa.

O destinatário privilegiado deste livro é, portanto, o jurista que se encontra em fase de formação. Em particular, o estudante da faculdade de direito.

PAOLO GROSSI

Citille in Chianti, Itália, Epifania de 2001.

SUMÁRIO

Prefácio 7

UM LIVRO, A SUA ÍNDOLE, A SUA MENSAGEM
ALGUMAS NOTAS INTRODUTÓRIAS

1. As mitologias jurídicas da modernidade e o papel do historiador do direito 13
2. Compreensão historiográfica e instrumentos comparativos 18
3. Um aceno sobre o conteúdo 19

I
JUSTIÇA COMO LEI OU LEI COMO JUSTIÇA?
OBSERVAÇÕES DE UM HISTORIADOR DO DIREITO

1. Direito e lei entre medieval e moderno 23
2. A ordem jurídica na perspectiva medieval 27
3. Os sinais do "moderno": estatalidade do direito e transfiguração da lei 34
4. Um itinerário "moderno": do direito à lei 41

II
ALÉM DAS MITOLOGIAS JURÍDICAS DA MODERNIDADE

1. Mitologia jurídica como estratégia vencedora na modernidade . 49
2. Projeto moderno do direito e complexidade do universo jurídico 55
3. Reduções modernas: uma visão potestativa do direito 59
4. Indo recuperar a complexidade: a descoberta do direito como ordenamento 63
5. Em direção a novas fundamentações para a positividade do direito 68
6. Interpretação–aplicação e novas fronteiras da positividade do direito 75
7. Em direção ao declínio da mitologia jurídica pós-iluminista 78

III
CÓDIGOS: ALGUMAS CONCLUSÕES
ENTRE UM MILÊNIO E OUTRO

1. O Código e o seu significado na modernidade jurídica 87
2. O Código e os elementos que historicamente o caracterizam 98
3. O Código hoje: algumas considerações do historiador do direito 114

IV
AS MUITAS VIDAS DO JACOBINISMO JURÍDICO
(OU SEJA: A "CARTA DE NICE", O PROJETO DE "CONSTITUIÇÃO EUROPÉIA" E AS SATISFAÇÕES DE UM HISTORIADOR DO DIREITO)

1. O papel crítico do historiador do direito no diálogo com o estudioso do direito vigente 123
2. Um risco da modernidade: absolutização e mitificação 125
3. Um esclarecimento indispensável: significados e mensagens do jacobinismo jurídico 127
4. A "redução" jacobina da complexidade social 130
5. A "Carta de Nice" como a última "carta" de direitos 135
6. A ilusão de uma redução do direito em um pedaço de papel ... 137
7. E o seu característico individualismo: o indivíduo como indubitável protagonista 140
8. O indivíduo insular 143
9. O insuficiente projeto de dimensão coletiva do sujeito no tecido da "Carta": um sinal de continuidade pós-iluminista 145
10 A exigência de um resgate: contra a monopolização estatal da dimensão política; a sociedade intermediária como autenticamente política 146
11. O insuficiente projeto de dimensão social do sujeito 151

Referências bibliográficas 155

UM LIVRO, A SUA ÍNDOLE, A SUA MENSAGEM

Algumas notas introdutórias

1. As mitologias jurídicas da modernidade e o papel do historiador do direito. — 2. Compreensão historiográfica e instrumentos comparativos. — 3. Um aceno sobre o conteúdo.

1. As mitologias jurídicas da modernidade e o papel do historiador do direito

Acredito piamente – e escrevi muitas vezes nos últimos tempos, tornando-me quase monótono – que um dos papéis, e certamente não o último, do historiador do direito junto ao operador do direito positivo seja o de servir como sua consciência crítica, revelando como complexo o que na sua visão unilinear poderia parecer simples, rompendo as suas convicções acríticas, relativizando certezas consideradas absolutas, insinuando dúvidas sobre lugares comuns recebidos sem uma adequada confirmação cultural. O historiador também pode esconder-se no outro papel, o de erudito conhecedor do passado próximo e remoto. Papel que não hesito em considerar – em relação ao primeiro – nobre mas menor e, no fundo, ao qual se pode renunciar.

A presente obra tem por objetivo corresponder a essa minha certeza, oferecendo alguns instrumentos de desmitificação cultural. O autor se deu conta, nas suas já longas e contínuas pesquisas histórico-jurídicas, de que um grande e emaranhado nó de certezas axiomáticas lentamente se

sedimentou no intelecto e no coração do jurista moderno, um nó que foi aceito de modo submisso, que ninguém sonhou discutir por ter sido fundamentado em um lúcido projeto originário de mitificação, mitificação como processo de absolutização de noções e princípios relativos e discutíveis, mitificação como passagem de um mecanismo de *conhecimento* a um mecanismo de *crença*.

O historiador, que por profissão é um relativizador e, conseqüentemente, um desmitificador, sente-se no dever de advertir o jurista que um nó como esse pode e deve ser desfeito, e que seu olhar deve ser liberado da lente vinculante colocada diante de seus olhos por duzentos anos de habilíssima propaganda.

A obra que hoje publicamos quer chamar a atenção de todo jurista (e, em particular, do estudante da faculdade de direito) para uma visão menos simplista, repercorrendo com olhar desencantado os duzentos anos de história jurídica continental européia que pesam sobre os nossos ombros e que nos deixam marcas; quer, sobretudo, trazer as aparentes conquistas de um progresso definitivo e indiscutível para o âmbito das soluções relativas da história, mostrar essas soluções em todos os seus aspectos. Essas certamente são, por um lado, autênticas conquistas históricas, mesmo se, por outro lado, são também instrumentos contingentes de defesa de interesses contingentes.

O livro que publicamos hoje também quer chamar a atenção de todo jurista (assim como daquele em formação) sobre

os custos culturais do simplismo de ontem e do seu – intimamente conexo – otimismo.

Um exemplo poderá esclarecer melhor. O direito moderno está intimamente vinculado ao poder político como comando de um superior a um inferior – de cima para baixo –, visão imperativista que o identifica em uma norma, ou seja, em uma regra respeitável e autoritária; essa visão, consolidada mesmo recentemente pelo furor da influência kelseniana[1], tem um custo que, na nossa opinião, é altíssimo: a perda da dimensão sapiencial do direito. Isso porque uma visão desse tipo somente pode se concretizar em um sistema legislativo que tenha apenas uma fonte plenamente expressiva da juridicidade, ou seja, a lei. Uma lei – essa dos modernos – que se concretiza mais em um ato de vontade do que em um ato de conhecimento. Pode também ocasionalmente ser redigida por sábios e ter um grande conteúdo sapiencial, mas tem a sua força não no conteúdo, e sim no fato de provir do órgão máximo de poder político. Ainda que, depois, venha artificiosamente se identificar na assembléia legislativa, o representante único da vontade popular, e na lei, a expressão única da vontade geral, trata-se somente de presunções absolutas e de verdades axiomáticas cunhadas por uma hábil estratégia de política do direito.

A perda da dimensão sapiencial não significa somente subtração do direito a uma classe de indivíduos competen-

[1] Em referência ao grande jurista austríaco Hans Kelsen (1881-1973) sobre o qual falaremos mais tarde, no segundo ensaio.

tes, os juristas, sejam esses mestres teorizadores ou juízes aplicadores, mas também a perda do seu caráter ôntico, do direito como fisiologia da sociedade, a ser descoberto, lido na realidade cósmica e social e traduzido em regras. Um custo que a visão ordenamental[2] atenuaria muito, se não estivesse bloqueada na consciência comum pelo vitorioso permanecer de convicções imperativas. A lição do historiador consiste em chamar a atenção do jurista atual para a íntima sabedoria do direito em culturas diferentes daquela que se consolidou no apogeu da Idade Moderna na Europa continental, plenamente no direito comum (*ius commune*) medieval e pós-medieval, em medida notável na civilização do *common law*.

Simplismo e otimismo parecem ser os traços que mais caracterizam o jurista moderno, fortalecido no seu coração pelas certezas iluministas. Mas são muitos os problemas evitados, as interrogações que não se quis pôr, assim como é muito fácil sentir-se satisfeito ao contemplar um mundo povoado por figuras abstratas, projetadas por uma lanterna mágica muito bem manobrada.

Muitas interrogações, ao contrário, pressionam e exigem respostas. Qual é o verdadeiro vulto do povo soberano ostentado e exaltado nas cartas revolucionárias? Qual democracia pode ser realizada em um Estado que permanece monoclassista (como a Itália até os primeiros anos do século XX)? O partido

---

[2] Ordenamental enquanto visão que concebe o direito mais como ordenamento do que como comando. Serão oferecidos esclarecimentos a respeito no segundo ensaio.

político constitui um filtro fiel da vontade popular e até que ponto a democracia partidocrática é a expressão do povo soberano? É satisfatória, de um ponto de vista substancialmente justicial, a garantia oferecida pela legalidade, pela segurança jurídica, pela divisão de poderes? É possível se satisfazer com a lei como justiça quando a mesma lei é reduzida a comando respeitável, mas passível de todo tipo de conteúdo e, portanto, vazio? Por que manter a infalibilidade e, conseqüentemente, a irresponsabilidade jurídica dos detentores do poder político perante as pesadas responsabilidades que recaem sobre os ombros dos detentores do poder administrativo e, atualmente, também do poder judiciário?

Talvez não seja o momento de rever *funditus* o problema e a ordem do que os juristas dizem ser as "fontes do direito" hoje, onde o abismo cada vez maior entre prática dos negócios e normas imperativas oficiais faz emergir um processo contínuo de privatização da produção do direito? Talvez não seja o momento de se libertar do decrépito esquema da hierarquia das fontes, agora que, no fervor da experiência, a ordem das fontes desmente esse esquema e está já vivendo um outro?

Alguns poderão afirmar que essa é uma provocação. Pode até ser. Porém, não foi preparada pelo autor para tornar eficaz a sua obra; origina-se nos fenômenos históricos que, finalmente, podem ser contemplados através do novo vulto que apresentam. É natural que o historiador, ao desnudar essa consciência negativa do jurista positivo, faça, por si mesmo, uma provocação. Acrescento: é natural.

2. Compreensão historiográfica e instrumentos comparativos

Uma advertência: não deve ser dado a essas páginas um valor que não possuem nem querem possuir, ou seja, o valor de proposta. O historiador tem um objetivo fundamental a alcançar: a compreensão do seu objeto historiográfico. Objetivo difícil de ser alcançado, porque se trata de penetrar na tipicidade de um certo clima histórico e da sua mensagem. Pode acontecer – e freqüentemente acontece – que tal tipicidade seja melhor exaltada por um instrumento precioso nas mãos do historiador: a comparação.

A comparação é um momento importante, que tende a salientar as diferenças, as oposições; o historiador que a utiliza corre o risco de parecer propor nos dois sentidos opostos, o bem e o mal, e a sua obra pode ser vista como maniqueísta. Ao menos nas nossas mãos, a comparação é utilizada somente para aguçar a crítica do olhar. As páginas que seguem possuem um valor exclusivamente crítico: querem liberar alguns pontos essenciais do nosso passado próximo de lugares comuns, exercitando sobre esses uma compreensão autenticamente historiográfica, compreensão mediante a comparação. O que, no nosso caso, tratando-se de objetos inchados e deformados por uma propaganda bissecular, pode significar reduzir a proporções mais modestas criaturas consideradas como gigantescas na consciência comum. Mas, veja-se bem: esse reduzir não significa avaliação negativa feita com espírito maniqueu; neste caso, reduzir significa reconduzir o fenômeno as suas reais dimensões históricas.

Uma advertência similar me vem espontaneamente quando escrevo, pensando na avaliação tendenciosa a qual foi submetida uma obra que escrevi sintetizando a experiência jurídica medieval, maliciosamente e arbitrariamente recebida como apologia filo-medievalista por um crítico que fazia da prevenção a sua lente perfeita.

3. Um aceno sobre o conteúdo

A obra é composta por quatro comunicações elaboradas para três ocasiões diferentes, mas interligadas por um duplo aspecto.

Em primeiro lugar, pelo tema, que é unitário e que consiste, como já tínhamos advertido, em uma tentativa de revisão crítica de tais fundamentos da modernidade jurídica, aceitos de um modo submisso como uma dogmática meta-temporal e ainda muito absolutizada na mente do jurista contemporâneo.

Em segundo lugar, porque todas as três comunicações tiveram como destinatário um público que não era composto por especialistas, sendo que o autor teve de se empenhar para tornar o seu discurso mais elementar e, portanto, mais compreensível, depondo o tecnicismo que freqüentemente obscura os escritos dos juristas.

As três comunicações são, na consecução, no interior dessa obra:

- uma conferência proferida na Universidade de Pisa, para os estudantes do primeiro ano da Faculdade de Direito;

- o "discurso oficial" proferido na ocasião em que foi entregue o Prêmio Internacional Duque de Amalfi, cujo título inspirou essa obra;
- a conferência de conclusão proferida em um congresso em Florença, sobre a codificação;
- a conferência ministrada em Rimini, no "*Meeting per l'amicizia tra i popoli*", por ocasião do Encontro que tinha por tema *Se ti distrai, l'Europa è giacobina*.

Desses, somente o discurso em Amalfi foi transcrito no seu texto original. Os demais foram modificados para serem adaptados à presente coletânea.

Em todos esses ensaios, o martelo bate sobre o mesmo profundo e penetrantíssimo prego, e é natural que existam também, ao longo da obra, repetições e insistências. Valem para indicar ao leitor os pontos que o autor considerou essenciais e, portanto, relevantes e centrais à sua atenção.

I
JUSTIÇA COMO LEI OU LEI COMO JUSTIÇA?

Observações de um historiador do direito*

* Conferência proferida em Pisa, em 23 de novembro de 1998, no âmbito do Seminário promovido pela Faculdade de Direito da Universidade de Pisa, no ano acadêmico 1998-1999, coordenado pelo Prof. Eugenio Ripepe, sobre o tema "Interrogações sobre o direito justo". Uma versão provisória foi publicada pelo Ateneu para a utilização exclusiva dos estudantes (Pisa, Serviço editorial Universitário, 2000).

1. Direito e lei entre medieval e moderno. — 2. A ordem jurídica na perspectiva medieval. — 3. Os sinais do "moderno": estatalidade do direito e transfiguração da lei. — 4. Um itinerário "moderno": do direito à lei.

1. Direito e lei entre medieval e moderno

Uma circunstância que sempre me alarmou profundamente, ao menos desde o período em que era estudante na faculdade de direito, é a teimosa desconfiança que o homem do povo, o homem comum, tem no que diz respeito ao direito. Uma desconfiança que nasce da convicção de que o direito é alguma coisa bem diferente da justiça, enquanto se confunde com a lei (talvez possa-se especificar: justo porque se confunde com a lei).

O homem do povo, portador do bom senso do homem comum, não está errado. O direito mostra-se para ele somente como lei, e lei é o comando autoritário que cai do alto sobre a indefesa comunidade dos cidadãos sem levar em conta os fermentos que circulam na consciência coletiva, indiferente à diversidade das situações que pretende regular. De fato, é correntemente ensinado que são virtudes comuns da lei: os aspectos abstrato e geral, ou seja, a sua indiferença perante casos e motivos particulares; a rigidez, ou seja, a sua insensibilidade às possíveis diferentes exigências dos seus destinatários; a autoritariedade, ou seja, a indiscutibilidade do seu conteúdo.

O que o Estado moderno assegura aos cidadãos é somente um complexo de garantias formais: é lei somente o ato que provém de determinados órgãos (normalmente o Parlamento) e segundo um procedimento detalhadamente especificado. O problema do seu conteúdo, ou seja, da justiça da lei, da correspondência ao que a consciência comum reputa justo, é substancialmente estranho a essa visão. Obviamente, a justiça permanece como objetivo do ordenamento jurídico, mas é um objetivo exterior; os cidadãos podem somente ter a esperança de que os produtores de leis – que são, pois, os detentores do poder político – ajustem-se a essa, mas devem de qualquer modo prestar obediência também à lei injusta. Recordo sempre com horror o que escrevia, em um condenável paroxismo legalista, o meu mestre de direito processual civil, Piero Calamandrei, sobre a suprema necessidade de obediência até mesmo ao preceito legislativo que gera horror ao cidadão comum[1]. E, no século XX, não faltaram leis que horrorizaram a nossa consciência moral: posso indicar ao menos os provimentos italianos pela tutela da raça, de 1938, aberrantes e repugnantes no seu perverso racismo, que ainda hoje sentimos pesar como vergonha sobre a civilização jurídica italiana[2].

O homem do povo tem, deste modo, razão de desconfiar: se o direito é lei, e se lei é somente um comando abstra-

---

1 CALAMANDREI, Piero. *La certezza del diritto e le responsabilità della dottrina* (1942), atualmente em *Opere giuridiche*. volume I. Napoli: Morano, 1985.

2 Trata-se das normas emanadas durante a ditadura fascista de Benito Mussolini, claramente inspiradas nas leis raciais em vigor a partir de 1935 no Estado nacional-socialista alemão (Nota do tradutor).

to com conteúdos indiscutíveis, pensado e desejado no longínquo Olimpo dos palácios do poder, a sua identificação com um raio que cai sobre a cabeça dos desavisados não é pois tão peregrina.

O historiador do direito pode, porém, mostrar um horizonte mais razoável para o homem do povo: a situação de hoje, em que começam a florescer novos fermentos, não possui raízes, nem distantes, nem profundas; nasceu agora há pouco, mesmo se uma propaganda sutil e persuasiva pretendeu fazer com que essa se apresentasse aos nossos olhos como única e otimizada solução. O historiador do direito que, por seu dever profissional, ama estender o seu olhar a tempos longínquos, isto é, fazer conexões e comparações, pode alertar para o fato de que a redução do direito à lei, e a sua conseqüente identificação em um aparelho autoritário, é fruto de uma escolha política que está próxima de nós, e que outras experiências históricas viveram de um modo diferente a sua dimensão jurídica, como, por exemplo, aconteceu com a medieval.

A visão histórica consola porque retira o caráter absoluto das certezas de hoje, relativiza-as pondo-as em fricção com certezas diferentes ou opostas experimentadas no passado, desmitifica o presente, garante que essas sejam analisadas de modo crítico, liberando os fermentos atuais da estática daquilo que é vigente e estimulando o caminho para a construção do futuro.

Por isso que me colocarei em um observatório especialmente comparativo, entre a civilização jurídica medieval e

a civilização jurídica moderna, com o objetivo de analisar como a relação entre direito, lei e justiça tenha sido vivida em ambas. Acredito que através dessa comparação a nossa análise possa tornar-se mais encorpada do ponto de vista crítico, já que, perante a formalista solução moderna de uma lei como justiça, ganhará consistência a substancial solução medieval da justiça como lei.

"Medieval" e "Moderno": dois planetas interligados por uma continuidade cronológica, mas marcados por uma efetiva descontinuidade, que é efetiva justo porque a profunda diversidade nas soluções adotadas tem origem em fundamentos antropológicos radicalmente diferentes. Colocar-se, portanto, em um ideal de fronteira divisória, acentuará a tipicidade que há pouco se acenava, assim como virá a exaltar a peculiaridade da modernidade jurídica.

Aos olhos do jurista, civilização medieval e civilização moderna parecem coincidir somente em um ponto: ambas são civilizações jurídicas, significando, de modo elementar, que ambas têm muita consideração pelo direito, considerando-o como estrutura fundamentadora em seus seios. Mas a coincidência formal e aparente é questionável: aprofundando a análise, mesmo sob esse aspecto, as escolhas se fazem diferentes, para não dizer opostas. É verdade: a presença do direito é intensa em uma e em outra, mas se tratam de presenças – por assim dizer – inversas: ao total e inegável respeito com o qual a dimensão jurídica circula constantemente nas veias do organismo medieval, contrasta a atitude de comple-

ta instrumentalização que domina no moderno; enquanto se punha – para o primeiro – entre os fins supremos da sociedade civil, torna-se – para o segundo – um instrumento, seja mesmo relevante, nas mãos do poder político contingente.

2. A ordem jurídica na perspectiva medieval

O universo medieval caracteriza-se, aos olhos atentos do historiador, por exprimir no seu seio aquilo que, em outra ocasião, apontei como um poder político não consumado[3]; entendo por não consumado não a falta de efetividade (que freqüentemente existe e que às vezes pode se agravar, transformando-se até mesmo em manifestações tirânicas), mas sim a ausência de um projeto totalizante, onicompreensivo. Em outros termos, o poder político não pretende controlar a integralidade do fenômeno social, ou melhor, distingue-se por uma indiferença substancial em relação àquelas zonas – amplas, ou mesmo amplíssimas – do social que não interferem diretamente no governo da coisa pública.

Com esse fenômeno, tem-se uma primeira conseqüência de grande relevância: o social, fundamentalmente autônomo, sem obrigações vinculantes, vive plenamente a sua história em todas as possíveis riquezas expressivas; deixado livre, dá livre curso à sua criatividade através de milhares possíveis combinações, ligações, sedimentações, do plano político ao econômico, do estamental ao profissio-

[3] Na avaliação sintética que tentamos fazer na obra *Ordine giuridico medievale.* Bari: Laterza, 1995.

nal, do religioso ao familiar, ao clã, às estirpes nobres, nos propondo uma paisagem com infinitas figuras corporativas, que são a marca do vulto medieval e, por inércia histórica, também pós-medieval.

Se vem acrescentada uma psicologia coletiva percorrida por inseguranças gerais e marcada pela humildade sincera dos indivíduos, nasce uma civilização que possui dois protagonistas essenciais: no fundo, incumbente e condicionante, a natureza cósmica com os seus fatos primordiais, vista como alvéolo protetor e garantia benéfica de sobrevivência, mas também na sua indomável imensidão; dentro das tramas do tecido de existência cotidiana, a comunidade, nicho indispensável para o desenvolvimento individual nas múltiplas manifestações que exprimem toda a complexidade da vida comum.

É um mundo de formações sociais que se delineia perante os nossos olhos, inacreditavelmente articulado e rebuscado, certamente pleno devido ao incessante gerar-se, integrar-se, estratificar-se das mais diferentes dimensões comunitárias, onde o indivíduo é uma abstração, já que pode ser concebido somente no interior da consolidada rede de relações oferecidas por aquela dimensão.

É daqui que brota e é aqui que se coloca o direito. Não como o fruto da vontade desse ou daquele poder político contingente, desse ou daquele Príncipe, mas como uma realidade historicamente e logicamente antecedente, que nasce nas vastas espirais do social, com esse se mistura, desse

se incorpora. O direito é um fenômeno primordial e radical da sociedade; para subsistir, não espera os coágulos históricos ligados ao desenvolvimento humano e representados pelas diferentes formas de regulamentação pública. Ao contrário, para ele é terreno necessário e suficiente as flexíveis organizações comunitárias em que o social se ordena e que ainda não se fundamentam na *polis*, mas sim no sangue, na fé religiosa, na profissão, na solidariedade cooperativa, na colaboração econômica.

Resumindo: *antes existia o direito*; o poder político vem depois. Tentando com essa afirmação, aparentemente surpreendente, salientar que, na cidade medieval, o direito repousa nos estratos profundos e duradouros da sociedade como se fosse uma ossada secreta, estrutura escondida dessa.

Uma segunda conseqüência emerge, relevante: o direito não é a voz do poder, não leva a sua marca, não sofre os seus inevitáveis empobrecimentos, os inevitáveis particularismos. Com uma imprescindível especificação: certo, existe também aqui uma parte do jurídico que é ligada e coligada a quem detém o governo da coisa pública e é o que hoje freqüentemente qualificamos como direito constitucional, administrativo, penal, mas o direito por excelência, a razão civil chamada a regulamentar a vida cotidiana dos homens, toma a sua forma direta e imediatamente pelo social e sobre as suas forças se desenha. Seus canais são: geneticamente, um denso florescer de costumes, em medida prevalente a respeito das poucas intervenções autoritárias dos Príncipes; sistematica-

mente, um rico ordenamento operado, mais do que por legisladores, por mestres teorizadores, juízes, tabeliões ou simples mercadores imersos na prática dos negócios e intérpretes das exigências que essa impõe.

Para a civilização jurídica medieval, pode-se corretamente falar de autonomia do jurídico, relativa, mas autonomia, do mesmo modo que se falou anteriormente de autonomia do social. Indubitavelmente, o direito nunca flutua na história, ao contrário, tende sempre a encarnar-se nela e a compenetrar-se em si mesmo; porém, existe aqui uma grande pluralidade de forças que, circulando livremente na sociedade, orientam-no, forças espirituais, culturais, econômicas, todas as forças que livremente circulam no social. O social e o jurídico tendem a se fundir, e é impensável uma dimensão jurídica vista como mundo de formas puras ou de simples comandos separados por uma substância social.

E uma terceira conseqüência emerge, igualmente relevante, e é já sumariamente delineada na última afirmação. O direito, emanação da sociedade civil na sua globalidade, é aqui realidade radical, ou seja, de raízes, das mais profundas e imagináveis raízes; é realidade que fundamenta todo o edifício de civilização, e, como tal, intimamente ligado com os grandes fatos primordiais que fundamentaram aquele edifício; fatos físicos e sociais de um tempo, pertencentes à natureza cósmica, mas absorvidos como fundamento último e primeiro de toda a construção social.

Visto do nosso ângulo de observação, o resultado que se manifesta em toda a sua tipicidade histórica é um direito que não está nos projetos de um Príncipe, que não sai da sua cabeça, que não explicita as suas vontades benéficas ou maléficas, mas de qualquer modo potestativas, que não é controlado como se fosse uma marionete, que não é manobrado para beneficiar o Príncipe. Esse direito tem uma sua *onticidade*, pertence a uma ordem objetiva, está no interior da natureza das coisas onde pode-se e deve-se descobri-lo e lê-lo. Íntima sabedoria do direito: escrito nas coisas por uma suprema sapiência e a qual decifração e tradução em regras podem ser confiadas somente a uma classe de sábios, os únicos capazes de fazê-lo com prudência.

Torna-se conseqüencial o fato de o direito ser aqui concebido sobretudo como interpretação, ou seja, de consistir principalmente na intensa atividade de uma comunidade de juristas (mestres, juízes, tabeliões) que, tendo por base textos respeitáveis (romanos e canônicos), lê os sinais dos tempos e constrói um direito autenticamente medieval, mesmo tendo como custo a possibilidade de ir além ou contra os textos que freqüentemente assumem o reduzido papel momentâneo da validade formal.

Ninguém mais do que Tomás de Aquino, que no final do século XIII agregou os estudos e promoveu a antropologia e a ciência política medievais, traduziu com tanta nitidez uma certeza similar em uma definição essencial, cuja substância circula e é amplamente recebida mesmo junto aos juristas

profissionais. É a definição de *lex*, justamente celebrada, que convém analisar com atenção porque, muito freqüentemente, o seu vigoroso conteúdo de pensamento político-jurídico foi banalizado, deixando-se monopolizar pela também relevante referência ao bem comum como finalidade da norma.

Leiamos-na por nossa conta no centro da *quaestio* 90 da "Prima Secundae" da "Suma Teológica"[4], dedicada à "essentia legis":

> "um ordenamento da razão voltado ao bem comum, proclamado por aquele que possui o governo de uma comunidade".

Nela, um elemento se salienta: a dimensão subjetiva cede lugar à dimensão objetiva; em outras palavras, o sujeito emanador não é tão relevante quanto o seu conteúdo objetivo: que é duplamente especificado; consiste em um ordenamento, ordenamento exclusivamente demandado pela razão. *Ordinatio* é a palavra que desloca o eixo da definição do sujeito ao objeto, porque insiste não sobre a sua liberdade, mas sobre limites à sua liberdade; ordenar é, efetivamente, uma atividade vinculada, já que significa tomar consciência de uma ordem objetiva preexistente e não eludível dentro do qual deve ser inserido o conteúdo da *lex*.

É justo por isso que a razão vem identificada como o instrumento do ordenar, ou seja, em uma atividade psicológica prevalentemente cognitiva: porque o conhecimento é o mai-

[4] *Summa Theologicae*, Prima Secundae, q. 90, art. 4.

or ato de humildade que um sujeito pode realizar em relação ao cosmos e à sociedade, porque o conhecimento é a projeção do sujeito além da própria individualidade para descobrir na realidade externa a ele as verdades que essa contém, para descobrir a ordem projetada e realizada pela Divindade. É verdadeiramente essencial a razoabilidade da *lex*, ou seja, a determinada e rigidíssima correspondência do seu conteúdo a um modelo que nem o Príncipe, nem o povo, nem a classe dos juristas criam, mas são chamados simplesmente a descobrir na ontologia da criação. Neste contexto, a *lex*, que possui uma dimensão cognitiva seguramente prevalente sobre a volitiva, não pode ser somente forma e comando; é, antes de tudo, um conteúdo substancial determinado porque é, antes de mais nada, leitura da realidade.

Retornando às muitas e criativas etimologias que encontram lugar na cultura medieval, viria a vontade de dizer: *lex* mais *lendo* do que *ligando*; e é por isso que se propõe como indispensável a *ratio*, a razão, por ser indispensável à capacidade de leitura e de medida do real. O que é próprio da razão, tanto que é possível afirmar que a lei consiste somente na razão[5].

Perante esse apelo obcecado à razoabilidade, facilmente vem ao jurista italiano de hoje uma desoladora consideração: porque – na nossa tradição de direito público – foi possível chegar a falar de "razoabilidade da lei", idéia considera-

[5] *Summa Theologicae*, Prima Secundae, q. 90, art. 1.

da intimamente desconsagrante por uma mentalidade tenazmente legalista. Tivemos que esperar as recentíssimas aberturas da Corte Constitucional; mas isso aconteceu somente há pouco tempo.

3. Os sinais do "moderno": estatalidade do direito e transfiguração da lei

Recolhemos os principais pontos do discurso desenvolvido até agora: a ordem jurídica na civilização medieval é, excetuando algumas zonas delicadas conexas ao governo da *polis*, uma realidade ôntica, ou seja, presente na natureza das coisas, realidade particularmente *radical* por ser exuberante às raízes de uma sociedade e por isso identificada com o costume, com os fatos caracterizantes que dão o vulto peculiar a uma civilização histórica; certamente, por isso, apresente-se sempre sob a égide da complexidade; realidade que nasce, vive, prospera, transforma-se, fora das espirais do poder público, o qual, graças ao fato de ser inconsumada, não tem pretensões excessivas, respeita o pluralismo jurídico, respeita o concurso de forças que a provocam. Dimensão histórica autenticamente medieval, esta da relativa indiferença do Príncipe em relação ao direito, mas que, por inércia, que freqüentemente é elemento primário dos teatros históricos, chega – mesmo se discutida, contestada, corroída – até aos grandes movimentos políticos e jurídicos do final do século XVIII.

Temos dito: discutida, contestada, corroída; e é assim. O itinerário que desembocará na nova perspectiva de relação

entre poder político e ordem jurídica que, na sua perfeita inversão a respeito das soluções medievais, constituir-se-á no arquétipo moderno, é uma estrada longa e acidentada, longa quase cinco séculos, onde novidades arrogantes misturam-se com as conspícuas resistências de uma ordem que tinha conseguido se fundir com os nervos mais profundos da sociedade.

Lentamente, mas incessantemente, emerge uma nova figura de Príncipe, e também uma conexão totalmente nova entre ele e o direito. O novo Príncipe é, politicamente, o fruto de um grande processo histórico totalmente voltado a libertar o indivíduo dos laços em que a civilização precedente o tinha inserido. Quanto mais o pessimismo medieval tentou inserir o indivíduo no tecido protetor, porém condicionante da natureza cósmica e da sociedade, tanto mais o planeta moderno – em marcha sempre mais decidida a partir do século XIV – esforçava-se para liberar o indivíduo, cada indivíduo, de todas as incrustações sedimentares que se encontravam sobre ele.

Tal fenômeno acontece, antes de tudo, em nível geral antropológico: estamos na gênese do individualismo moderno. Isso acontece também na ciência política, que aqui nos interessa. Também o Príncipe, esse indivíduo modelo e modelo de todo indivíduo, sofre um processo de liberação similar, libertando-se das velhas limitações medievais. Liberação, para ele, significa o desenho de um novo projeto político, munido de uma couraça que torne possível a absoluta solidão, que encontre somente em si mesmo justificações, motivos, finali-

dades; e o poder que vem colocado nas suas mãos perde aquele conteúdo delimitado por esse fundir-se na velha ordem feudal, e aproxima-se sempre mais da "potência absoluta e perpétua" teorizada no final do século XVI na "*République*" de Bodin[6]. O novo Príncipe é um sujeito que não ama mortificações provenientes da realidade desse mundo, que não está em diálogo com a natureza e com a sociedade, que não tolera humilhar-se como simples cabeça de uma relação. Ele – indivíduo de absoluta insulariedade – tenderá a projetar para o exterior uma vontade perfeitamente definida, que encontrou já nele toda e qualquer possibilidade de justificação.

Interessa-nos, em particular, a nova conexão entre esse Príncipe e a dimensão jurídica: lentamente, mas incessantemente, a velha psicologia de indiferença em relação a grandes zonas do jurídico é substituída por uma psicologia extremamente atenta, uma atitude invasiva, um envolvimento sempre maior na produção do direito. Tudo isso, bem inserido no interior de uma visão de poder político como potestade onicompreensiva, potestade sempre mais consumada. Inicia-se uma longa estrada que verá o Príncipe sobre uma trincheira de batalha contra toda e qualquer forma de pluralismo social e jurídico.

---

[6] O jurista e cientista político francês Jean Bodin, que escreveu na segunda metade do século XVI, é a fiel expressão do novo, mas também de algumas linhas do velho, presentes na França no final do mesmo século. Nos seus *Six livres de la République* o cientista político percebe com lucidez o novo modelo de Príncipe e do seu poder soberano, enquanto que o jurista (como será possível ver posteriormente) ainda contempla as persistências da radicadíssima praxis jurídica medieval.

É um processo desacobertadamente tangível no reino da França, que é, para o cientista político e para o jurista, o extraordinário laboratório histórico onde o "moderno" por primeiro toma o seu vulto mais determinado, incrementando cada vez mais os seus traços. A história da monarquia francesa do século XI ao século XVIII é a história de uma cada vez mais intensa tomada de consciência por parte do Príncipe, da sua cada vez mais precisa percepção da essencialidade do direito no âmbito do projeto estatal, da exigência sempre maior de propor-se como legislador. Melhor, de conceber na produção de normas autoritárias o emblema e o vigor da realeza e da soberania, em oposição ao ideal medieval, que via o Príncipe, sobretudo, como juiz, juiz supremo, o grande justiceiro do seu povo.

A linha de desenvolvimento corre nítida nos séculos tardo-medievais e protomodernos: ganhará sempre mais espaço a normatização direta realizada pelo Príncipe, adentrando sempre mais em zonas que antes eram consideradas proibidas; finalmente – e estamos já no final do século XVIII – os atos de esparsa normatização transformaram-se em um tecido normativo bem programado, regido por uma abordagem orgânica ao disciplinar setores relevantes da experiência jurídica, que já tende a substituir-se monocraticamente ao velho pluralismo de fontes[7].

[7] Recordamos as grandes *Ordonnances* promulgadas no final do século XVIII por Luís XIV.

Ganha espaço o protagonismo da lei, não mais entendida na vaga acepção da *lex* de Santo Tomás, essa última inclinada a dissipar-se no *ius*, mas sim no significado estreito da *loy*, lei em sentido moderno, volição autoritária do detentor da nova soberania e caracterizada pelos atributos da generalidade e da rigidez.

Mas um outro elemento discriminante salienta-se entre a *lex* dos medievais e a *loy* dos modernos: quanto à primeira, era marcada por conteúdos e finalidades bem estabelecidos – a razoabilidade, o bem comum –, tanto já a segunda propõe-se como realidade que não encontra em um conteúdo ou em um objetivo nem o seu significado e nem a sua legitimação social.

Talvez ninguém melhor do que Michel de Montaigne, impiedoso, mas agudíssimo observador de si e do mundo, na segunda metade do século XVI, soube expressar essa verdade elementar:

> "as leis possuem crédito não porque são justas, mas porque são leis. É o fundamento místico da autoridade delas; não têm outro fundamento, e é bastante. Freqüentemente são feitas por imbecis".

A dose vem recarregada algumas linhas depois:

> "quem as obedece por serem justas, não dá a obediência devida a elas".

E o faz desencalhando, de um modo que pode parecer imprudente a um moralista, o dever de obediência do cidadão a qualquer tipo de pretexto conexo ao conteúdo da norma[8].

A visão pessimista – que Montaigne, especialista no direito, contempla com os seus olhos eivados de um corrosivo ceticismo – traduz-se em um diagnóstico preciso do que tinha se transformado a *loy* na França na segunda metade do século XVI: uma norma que se autolegitima como lei, ou seja, como volição de um sujeito soberano. O organismo político, já ordenado em uma robusta – sempre mais robusta – estrutura autenticamente estatal, precisa de um instrumento normativo capaz de conter o fenômeno jurídico e de vinculá-lo intimamente ao detentor do poder, instrumento indiscutível e incontrolável, que finalmente permita livrar-se das velhas salvaguardas que falavam, com uma linguagem cada vez menos receptível pela Monarquia, de aceite por parte do povo ou dos organismos judiciários e corporativos.

A lei torna-se uma forma pura, ou seja, um ato sem conteúdo, um ato ao qual nunca será um determinado conteúdo a dar o crisma da legalidade, mas sempre e somente a proveniência do único sujeito soberano. O qual se identifica cada vez mais em um legislador, em um legislador embaraçante, unindo intimamente a qualidade da sua criatura normativa à própria pessoa e a sua supremacia.

---

8 *Essais*, livro III, cap. XIII. De formação jurídica, este *gentilhomme* da província francesa encarna bem a figura do novo intelectual humanista, observador livre e sem preconceitos da sociedade circunstante.

E, desse modo, nasce a mística da lei, essa pesada hipoteca da civilização jurídica moderna; a mística da lei enquanto lei, uma herança do absolutismo régio que a Revolução do final do século XVIII acolherá sem piscar, intensificando-a e tornando-a cada vez mais rígida em relação às aberturas subsistentes do Antigo Regime, sob o acobertamento de simulacros democráticos. E, em clima de conquista e ostentada secularização, será sacra a lei intrinsecamente injusta, assim como será sacra a lei redigida e promulgada por um soberano idiota, fazendo nosso o exemplo dado por Montaigne.

A antiga sobreposição e integração de fontes – leis, costumes, opiniões doutrinais, sentenças, práxis – cede lugar à fonte única, que se confunde com a vontade do Príncipe, o único personagem acima das paixões e dos partidarismos, o único capaz de ler o livro da natureza e traduzi-lo em normas, o único – acrescento – que tem condições – como sujeito forte – de liberar-se com uma sacudida do emaranhado inextricável, mas freqüentemente também irracional, de uso e costumes.

O velho pluralismo vai sendo substituído por um rígido monismo: a ligação entre direito e sociedade, entre direito e fatos econômico-sociais emergentes, é ressecada, enquanto se realiza uma espécie de canalização obrigada. O canal obviamente escorre entre os fatos, mas escorre no meio de duas margens altas e impenetráveis: politização (em sentido estrito) e formalização da dimensão jurídica são o resultado mais impressionante, mas também o mais corpulento.

O direito já se contraiu na lei: um sistema de regras autoritárias, de comandos que foram pensados e desejados como abstratos e sem elasticidade, insindicáveis no seu conteúdo, já que não é da qualidade desse, mas da qualidade do sujeito legislador que tiram a própria autoridade. Em pouco tempo, no clima pré-revolucionário e revolucionário, a lei receberia um ulterior reforço, o democrático, graças a afirmada (mesmo se não demonstrada) coincidência entre vontade legislativa e vontade geral. Em pleno secularismo, o resultado paradoxal é o perfeito cumprimento da mística da lei, percebida de modo tão agudo por Montaigne. Se muitos altares eclesiásticos serão cuidadosamente desconsagrados, outros tantos – profanos – serão erigidos e consagrados ao culto da lei, juntamente com a teorização de uma verdadeira mitologia jurídica (mitologia devido ao fato de ser muito freqüentemente regida por um aceite substancialmente acrítico, ou, o que dá no mesmo, ideologicamente motivado).

Para nos mantermos na França, laboratório histórico concebido por nós como paradigma, estamos já nas vésperas da codificação geral, que será iniciada a partir da zona tradicionalmente reservada de modo acirrado aos privados, ou seja, pelas relações civis. Efetivamente, o primeiro Código que Napoleão I quis, em 1804, foi o Código Civil.

4. Um itinerário "moderno": do direito à lei

O historiador atento não pode deixar de constatar a lentidão com que o processo se desenvolve, assim como os muitos

obstáculos que se entrepõem ao seu desenvolvimento. Nunca nos esqueçamos de que a civilização rapidamente liquidada pelo azedume humanista como *media aetas*, idade do meio, interlúdio insignificante ou – pior ainda – negativo entre duas idades historicamente criativas, a antiga (clássica) e a moderna, pôde se desenvolver ao longo de todo um milênio, pôde fixar raízes profundíssimas, pôde se tornar – graças também ao auxílio da Igreja Católica – costume e mentalidade, pôde forjar a consciência coletiva e uma cultura apropriada para aquela consciência. Precisamente, por ter se tornado a estrutura do organismo social, os seus valores não poderiam ser apressadamente anulados, a consolidação do novo será necessariamente lenta e difícil.

O século XVI francês, tão fértil e povoado de novidades, oferece-nos um testemunho desse fenômeno. É uma encruzilhada histórica, onde novas figuras tomam forma, novas sensibilidades florescem e misturam-se com o velho. Bodin, o fundador da ciência política moderna, mas também personagem imerso na experiência prática do direito, oferece a possibilidade de seguir o sentido do problema histórico e de verificar a dificuldade pela qual passavam os novos modelos ao substituir os velhos.

Trata-se de um texto – na minha opinião, de grande relevo no plano histórico-jurídico – inserido no capítulo central do livro primeiro da "*République*", sobre a soberania[9]:

---

[9] *Six livres de la République*, livro I, cap. VIII – *De la souveraineté*.

> "Existe muita diferença entre o direito e a lei, o primeiro registra fielmente a eqüidade;
> a lei, ao contrário, é somente comando de um soberano que exercita o seu poder".

O século XVI é aquele onde o consolidadíssimo poder da Monarquia já se traduziu, na França, em Príncipe-legislador, em um Príncipe que sacraliza a regra jurídica por ele produzida justo por identificá-la como a própria vontade absoluta e com a expressão do próprio poder. A lei desse Príncipe é a lei da qual Montaigne fala sem preconceitos. Mas estamos no início do grande processo histórico que desembocará, nos primeiros anos do século XIX, na codificação napoleônica, uma codificação geral regulamentando todas as zonas do ordenamento jurídico. No final do século XVI, efetivamente ainda permanecem muitos espaços onde o Príncipe não quis ou não pôde legislar; e é, sobretudo, o território das relações cotidianas entre privados – o que chamaremos "direito civil" – ainda entregue à acirrada regulamentação do costume, das imemoráveis consuetudes, respeitadas e observadas por sábios, juízes, operadores práticos.

Bodin, ainda no século XVI, registra dois planos, dois níveis da experiência jurídica francesa: o das leis – ainda em crescimento –; e o outro, mais subterrâneo, enraizado na sociedade, que ele não hesita em chamar *direito*. Planos diferentes, mas também realidades particularmente diferentes devido as suas qualidades intrínsecas: a lei régia liga-se somente à vontade do rei, não tendo relevo o seu conteúdo substancial; o direito é, ao contrário, o fruto da experiência de

vida de uma comunidade e registra em si as soluções mais équas que, cotidianamente, a comunidade fez suas.

O direito ainda representa, no momento em que Bodin redigia a sua "*République*", a extrema ramificação – destinada a ser reduzida e, depois, a desaparecer – de uma concepção que tende a encontrá-lo e a lê-lo nas raízes profundas da sociedade, traduzindo-o em normas que deveriam respeitar aquelas mesmas raízes.

O drama do planeta moderno consistirá em realizar o processo de absorção de todo o direito na lei, na sua identificação na lei; para isso, basta que essa seja lei, mesmo que seja ruim ou iníqua, como dizíamos no início.

E teve-se freqüentemente, sempre mais freqüentemente, um perigoso, inevitável descolamento do direito formal e legal, de um lado, e sociedade civil em perene movimento, de outro. Sem que existissem possibilidades de verificação e, desse modo, também de salvaguarda para o direito, já totalmente imobilizado nas tramas rigidíssimas de uma constelação legislativa. O direito, tecido ordenante do corpo social, que deve harmonicamente revesti-lo no seu contínuo crescimento, poderia somente vir a passar por uma crise profunda, entendendo aqui por crise a incapacidade de corresponder a sua própria natureza e função.

Em 1949, em um pós-guerra que estava revelando em toda a Europa a dilaceração provocada por essa crise, um pensador francês especialista em direito comercial, Georges Ripert, atentísssimo às relações entre fontes jurídicas e rea-

lidade econômica do capitalismo maduro, pôde escrever em um fortunado livro, significativamente dedicado ao "Declínio do direito"[10]:

> "quando o poder político manifesta-se em leis que não são mais a expressão do direito, a sociedade encontra-se em perigo".

Hoje, o jurista olha de maneira mais desencantada, mais crítica, as conquistas que a modernidade jurídica pretendia; e, há algum tempo, está realizando a revisão de muitas conclusões que uma estratégia persuasiva tinha elevado à categoria dos fundamentos dogmáticos. Vistos através de uma lente jurídica mais vigilante e mais penetrante, estes magníficos edifícios vazios erguidos pela cultura moderna (lei, legalidade, segurança jurídica) pareceriam merecedores de serem guardados, mas precisando de conteúdos adequados, que fossem apropriados a legitimá-los não somente do ponto de vista formal.

O historiador do direito, graças ao seu conhecimento específico, evocando e comparando climas diferentes, pode dar uma contribuição fundamental a essa importante obra de relativização; pode fungir – como estou repetindo insistentemente nos últimos anos – como consciência crítica de quem se dedica ao direito positivo; pode contribuir para que esse viva o presente e vigente na sua historicidade, sendo um ponto

[10] RIPERT, Georges. *Le Déclin du droit – Études sur la législation contemporaine*. Paris: L.G.D.J., 1949, prefácio, p. VI.

em uma grande linha histórica que nasce no passado, que não é destinada à exaustão no hoje, mas, ao contrário, projeta-se no futuro. Deste modo, o historiador paradoxalmente transforma-se na garantia do futuro para quem constantemente se dedica ao direito positivo, submetido ao risco de um imobilismo inatural.

II
ALÉM DAS MITOLOGIAS JURÍDICAS DA MODERNIDADE*

* Uma generosa iniciativa do Município de Amalfi foi a instituição em 1999 do Prêmio Internacional Duque de Amalfi, um dos pouquíssimos prêmios reservados a um jurista, que teve como vencedor da sua primeira edição o grande jurista italiano Pietro Rescigno. Em 2000, o prêmio foi dado ao autor dos escritos que seguem, as quais representam o texto da sua "conferência oficial", acontecida em 1.° de setembro de 2000, na Sala do Conselho do Município de Amalfi, segundo o programa do Comitê organizador. Tratando-se de um discurso voltado a um público heterogêneo, constituído sobretudo por não-juristas, devem ser consideradas como justificadas algumas referências elementares. Na redação foram omitidas as palavras que as circunstâncias pediam, pronunciadas no exórdio.

1. Mitologia jurídica como estratégia vencedora na modernidade. — 2. Projeto moderno do direito e complexidade do universo jurídico. — 3. Reduções modernas: uma visão potestativa do direito. — 4. Indo recuperar a complexidade: a descoberta do direito como ordenamento. — 5. Em direção a novas fundamentações para a positividade do direito. — 6. Interpretação–aplicação e novas fronteiras da positividade do direito. — 7. Em direção ao declínio da mitologia jurídica pós-iluminista.

1. Mitologia jurídica como estratégia vencedora na modernidade

Parece quase o aproximar-se de dois opostos quando – como se faz no título dessa conferência – são colocadas uma ao lado da outra as expressões "mitologia" e "modernidade". Na consciência comum, de fato, o apelo ao moderno evoca um tempo percorrido e dominado pelo vitorioso desmantelamento de antigas mitificações sedimentadas e enraizadas no costume graças a duas conquistas do progresso humano: a secularização e a conseqüente posse de evidentes verdades científicas. Tendo sido finalmente exilada em um cantinho apartado a velha produtora de fábulas, a Igreja Romana, torna-se grande o orgulho de poder olhar o mundo com olhos incorrompidos, capazes de ler as verdades nesse imanentes, verdades não reveladas (e, portanto, não demonstradas), ou melhor, descobertas na sólida e concretíssima natureza das coisas.

Mesmo se o historiador libera o seu olhar de vícios apologéticos, essa civilização, que tem a teimosa pretensão de propor-se como desconsagradora e demolidora de mitos, mostra ser uma formidável construtora deles. Para retornar ao nosso campo de investigação, o jurista que tiver olhos desencantados não poderá deixar de salientar tal fenômeno nas grandes correntes do jusnaturalismo do século XVIII, tão incisivas na modelagem do moderno, que freqüentemente qualificamos como o iluminismo jurídico da Europa continental. Aqui talvez se possa chegar à mais inteligente, à mais consciente, à mais hábil fundição de mitos jurídicos da longa história jurídica ocidental; um complexo de mitos organicamente imaginados e sustentados, que dão vida a uma verdadeira mitologia jurídica.

Certamente não sou o primeiro a usar esse sintagma; os jurisconsultos, por exemplo, sabem bem que a esse é dedicado especificamente um item dos "*Frammenti di un dizionario giuridico*", que são o lúcido testamento intelectual de Santi Romano, talvez o mais profundo pensador jurista italiano do século XX[1]. O interesse de Romano não é nem histórico, nem filosófico; como sempre, ele se põe problemas de teoria jurídica empenhando-se a não atravessar as suas fronteiras. Todavia, é singular o fato de que o seu exemplo refira-se quase que exclusivamente ao grande conjunto de idéias dos sé-

[1] ROMANO, Santi. *Frammenti di un dizionario giuridico*. Milano: Giuffre, 1947, item *Mitologia giuridica*.

culos XVII e XVIII: estado de natureza, contrato social, representação política, igualdade jurídica, vontade geral, e, assim por diante. É um conjunto de idéias que compõe e une em si a desinibição metodológica e, ao mesmo tempo, é busca de uma fundamentação mítica, oferecendo a desconcertante visão de um estamento intelectual que considera irrenunciável aquela operação fundadora.

Não podemos esquecer que, para a história jurídica continental, o século XVIII é momento de ruptura, de profunda descontinuidade – obstinadamente desejada – com o passado. Anteriormente nos referimos à secularização; as suas conseqüências são enormes e notórias, mas com um resultado estrategicamente negativo: as novas conquistas político-jurídicas pensavam na sua própria fragilidade sabendo não ter o tenaz apoio das metafísicas religiosas, pediam, por sua vez, para não serem apoiadas sobre as areias movediças da história, mas, mais além, mais profundamente ou, se quisermos, mais acima, onde os ventos históricos não chegam a sacudir e derrubar.

A isso serve o mito, no seu significado essencial de transposição de planos, de processo que obriga uma realidade a cumprir um vistoso salto de níveis transformando-se em uma *meta-realidade*; e, se cada realidade está na história, da história nasce e com a história varia, a meta-realidade constituída pelo mito torna-se uma entidade meta-histórica e, o que mais pesa, absolutiza-se, torna-se objeto de crença mais do que de conhecimento. O resultado estrategicamente ne-

gativo que provém da secularização pode ser exorcizado unicamente com uma trama mitológica. O iluminismo político-jurídico precisa do mito porque precisa de um absoluto ao qual se agarrar; o mito cobre nobremente a carência de absoluto que foi colocada em prática e preenche um vazio que poderia se tornar arriscadíssimo para a estabilidade da nova estrutura da sociedade civil. As novas ideologias políticas, econômicas e jurídicas finalmente possuem um suporte que garante a sua inalterabilidade.

Posteriormente analisaremos de modo concreto esse tecido ideológico que se entrelaça indissoluvelmente como se fosse uma trama mítica. O historiador do direito pressiona para que seja fixada primariamente uma reflexão, que também serve como uma advertência metodológica: obrigar a realidade histórica a um salto de níveis não implica somente a sua transposição, mas também a sua transfiguração; sob a cobertura da crença, essa deixa a dimensão relativa que é típica da história, passando por um processo de absolutização. O historiador sente se encontrar perante produtos históricos absolutizados na consciência coletiva e profundamente deformados no seu vulto original. As instâncias mitificadoras marcam e desvirtuam toda uma cultura jurídica, na qual se exalta a perda de historicidade de princípios instituídos como figuras, todos obviamente tendo as suas origens em escolhas históricas, suscitados por interesses carnais de classe, mas colocados no nicho seguro e protetor representado pelo mito. A paisagem histórica depõe confu-

são, desordem, mundanidade, complexidade, para reduzir-se a um simples desenho, nítido e linear.

O historiador do direito, na sua formação primária de consciência crítica do jurista operador do direito positivo[2], pode somente desconfiar de paisagens muito simples, lembrando que a complexidade é a riqueza de cada clima histórico, lançando legitimamente o suspeito de que aquela geometria simples seja o fruto de um sapientíssimo artifício, resolva-se em uma construção artefata; e será esta, já nos primeiros anos do século XX, nos anos da primeira fissura no conjunto de idéias jurídico pós-iluminista, a suspeita que os juristas mais conscientes terão assim que os olhos começarem a liberar-se do persuasivo véu formado por sugestões bisseculares[3].

A engenhosidade e o esmero da paisagem também se revelavam na sua harmonia de construção geométrica, onde tudo aparece exato e preciso, contido, como é, no rigor de linhas, ângulos, círculos. O problema ineliminável e indis-

---

[2] Salientei repetidamente, nestes últimos anos, essa visão do historiador do direito e da sua função nos estudos jurídicos e nas faculdades de direito; recentemente e expressamente, o fiz na conferência que proferi na Universidade de Sevilha, presente no artigo GROSSI, Paolo. Storia del diritto e diritto positivo nella formazione del giurista di oggi, in *Rivista di storia del diritto italiano*, LXX (1997).

[3] Expressivamente, na obra de Santi Romano, em muitos de seus ensaios sobre direito constitucional, mas, acima de tudo, na conferência proferida em Modena, em 1907, sobre "*Le prime carte costituzionali*"; com uma inspiração filosófica, no primeiro Capograssi do "*Saggio sullo Stato*" (1918), das "*Riflessioni sull'autorità e la sua crisi*" (1921), de "*La nuova democrazia diretta*" (1922). Para um enquadramento destes ítens no panorama doutrinário italiano, vede GROSSI, Paolo. *Scienza giuridica italiana – Un profilo storico, 1860-1950*. Milano: Giuffrè, 2000, respectivamente páginas 112-114 e 120-121.

solúvel é o fato de não se discorrer sobre figuras abstratas, mas sobre criações e criaturas históricas inconteníveis no rigor de um teorema. E, trata-se de um verdadeiro teorema político-jurídico.

Vejamos novamente, de perto, os seus traços: a nova ordem sociopolítica deve ser democrática, em oposição à decrépita ordem classista, exprimindo a vontade geral da nação; a qual tem o seu único e conveniente instrumento de expressão na representação política entendida como representação de vontade; o novo Parlamento é, portanto, o depositário da vontade geral e, a sua voz em nível normativo – a lei – identifica-se com a vontade geral; o princípio de legalidade, ou seja, a conformidade de cada manifestação jurídica com a lei, torna-se a regra fundamental de toda democracia moderna. Tudo encaixa perfeitamente, como em um teorema ou, descendo a instrumentos que nos são mais familiares, como um silogismo.

Por trás desse palco cênico em que tudo é idealizado, por trás desse raciocínio realizado através de modelos, fica escondido o Estado monoclassista, o espesso extrato de filtros entre sociedade e poder, o elitismo exclusivo das formas de representação, a grosseira defesa de ricos interesses que todo o puríssimo teorema vinha a tutelar e a consolidar[4]. E, para o historiador do direito, aparece ideologicamente carregada a

[4] Escreveu a respeito escritos lúcidos e culturamente conscientes ZAGREBELSKY, G. *Il sistema costituzionale delle fonti del diritto*. Torino: UTET, 1984, Introdução, p. X-XI.

verdade axiomática de que a lei, e somente a lei, exprime a vontade geral e, assim sendo, produz e condiciona toda manifestação da juridicidade; ou seja, tudo o que venha proposto como juridicidade mostra-se, em um exame aprofundado, mais como uma pseudo-verdade substancialmente tuteladora de interesses particulares dos detentores do poder.

Filósofos, cientistas políticos, juristas tinham trabalhado para construir a fortaleza inexpugnável de uma persuasivíssima mitologia político-jurídica; inexpugnável porque, em respeito a essa se impunha, mais do que um conhecimento, uma crença; e de crenças, já nos enchemos até ontem, quase que até hoje. A propaganda iluminista e pós-iluminista tinha acertado em cheio ao mirar com precisão o próprio objetivo.

O título dessa conferência pode ser mais bem compreendido e compreende-se qual seja o seu fim elementar: um pacato exame crítico que permita ao historiador do direito ir além das mitologias jurídicas da modernidade, liberar-se das sombras gigantescas habilmente criadas por uma extraordinária lanterna mágica, repopulando uma paisagem histórica de criações e criaturas concretamente vivas, reconduzidas ao que são concretamente as suas reais proporções.

2. Projeto moderno do direito e complexidade do universo jurídico

A grande operação que se consolida na França, no final do século XVIII, e que tende desesperadamente a reduzir o direito na lei possui vários significados, mas existe um sobre

o qual a apologética liberal sempre sobrevoou e que, ao contrário, convém salientar devido a sua incisividade sobre futuros desenvolvimentos: tinha-se plena consciência da enorme relevância do direito, de todo o direito, obviamente também do direito privado em uma cultura particularmente burguesa atentíssima à esfera patrimonial; conseqüentemente, tendia-se a sua monopolização por parte do poder; conseqüentemente, vinculava-se intimamente, quase indissoluvelmente, direito e poder; conseqüentemente, o direito, que por todo o transcorrer da civilização medieval foi dimensão da sociedade e, por isso, manifestação fundamental de toda uma civilização, torna-se dimensão do poder e por esse fica marcado na sua intimidade. Em outros termos, exaspera-se a dimensão autoritária do "jurídico", exasperando também a sua alarmante separação do "social".

Não está errado o homem do povo, mesmo em nossos dias, que traz em si ainda frescos os cromossomos do proletário da idade burguesa quando desconfia do direito: o percebe como alguma coisa que lhe é completamente estranha, que cai do alto sobre a sua cabeça, como uma telha do telhado, confeccionado nos mistérios dos palácios do poder e evocando sempre os espectros desagradáveis da autoridade sancionadora, o juiz ou o funcionário de polícia.

Essa foi a maior tragédia do direito continental moderno, a de ser identificado em uma dimensão patológica de convivência civil, em um mecanismo ligado à violação da ordem constituída. Infelizmente, o direito mais cruamente e severamente sancionador, o penal, pareceu elevar-se como modelo

da juridicidade exatamente por consistir na plena expressão da potestade punitiva.

Essa dimensão de potestade do direito – que constatamos ser mesmo recentíssima e convictamente reafirmada, até mesmo em um texto introdutório para noviços[5] – é desviada porque, assumindo a dimensão patológica através de uma cifra de identificação, faz com que seja esquecida a autenticidade fisiológica do fenômeno jurídico, confundindo a sua essência. A fisiologia do jurídico deve ser intimamente compenetrada com a fisiologia da sociedade, ou seja, está no centro da φύδις dessa, é estruturalmente participante dela. Não é o instrumento coercitivo do soberano ou o espaço para os vôos teóricos de um doutrinador; pode também sê-lo, pode se tornar, mas, *antes*, é alguma coisa a mais e diferente. Pertence ao ser de uma sociedade, condição ineliminável para que aquela sociedade viva e continue a viver como sociedade, não se modificando em um amontoado de homens em perene rixa entre si.

O direito, pela sua tensão a encarnar-se, antes de ser poder, norma, sistema de categorias formais, é experiência, ou seja, uma dimensão da vida social. Urge recuperar a juridicidade além do Estado e além do poder, urge recuperá-la para a sociedade como realidade global, como uma recuperação que é, antes de tudo, ofício do jurista.

---

[5] Do constitucionalista Maurizio Pedrazza GORLERO. *Il potere e il diritto – Elementi per una introduzione agli studi giuridici*. Padova: CEDAM, 1999, que tenta recolocar o poder político no centro do fenômeno jurídico.

Se atualmente insistimos neste tema, após todo o século precedente ter sido rico de floresceres e fermentos nesse sentido, é porque se constata que tantas percepções conscientes não conseguiram nem mesmo arranhar no coração do jurista – mais no coração do que na sua ordem racional – aquelas compactas muralhas de Jericó constituídas pelo estatalismo e pelo legalismo; para ele, as trombas de Josué devem ainda soar, ou soaram em vão. E foi esse mesmo – e já faz oitenta anos – o principal mérito de Santi Romano como pensador do direito, quando indicou na sociedade o referente da juridicidade[6], com uma mensagem tão citada pela reflexão científica sucessiva quanto rejeitada na adesão espiritual dos leitores que a citavam[7].

Imagine! Tomar consciência da sociabilidade do direito não significa ficar bloqueado pela afirmação elementar e, além do mais, banal, de que, em todos os lugares onde existe uma pluralidade de homens, existe o direito. Ao contrário, deve ser o ponto de partida para um conhecimento ulterior; que o vínculo necessário entre sociedade e direito implica na descoberta da complexidade desse último. Espelho da sociedade, reflete a sua estrutura variada, estratificada e diferenciada. Concluindo, o direito não é e não pode ser a realidade

---

[6] Com toda uma série de contribuições reflexivas de direito público em geral, que se iniciam nas primeiras duas décadas do século XX e que culminam no clássico da literatura jurídica italiana que é a obra *"L'ordinamento giuridico"*, publicada entre 1917 e 1918.

[7] Salienta-o com amargura o próprio Santi Romano, no prefácio da segunda edição do seu livro (vede ROMANO, S. *L'ordinamento giuridico*. Firenze: Sansoni, 1946, prefácio).

simples e unilinear pensada pelos nossos antepassados do século XVIII. Se uma conclusão como essa se justificava, então, pelo valor estratégico que se revestia, hoje surge somente como um sinal de aridez cultural e nada mais.

Os nossos antepassados o pensaram no Estado e para o Estado, mas, com isso, o submeteram a um empobrecimento radical. Em relação à globalidade do social, o Estado, como aparelho, como indispensável aparelho de poder, constitui-se em uma cristalização dessa; para além disso, um Estado que, por vários bons motivos, foi construído como pessoa pelo direito público do século XIX e, como tal, foi separado do fluidíssimo magma da sociedade.

Foi, o sabemos, uma operação geométrica de extrema simplificação, particularmente grave no mundo dos sujeitos, já reduzido a um palco de pessoas públicas e privadas. De toda essa operação, o historiador deve salientar um resultado de extrema pobreza: foi enterrada ou ignorada ou retirada, em nome de uma mitologia-ideológica jurídica repressora e de uma estratégia ao seu serviço, uma parte conspícua de riqueza vital do ordenamento jurídico do social; urge redescobrir o tesouro escondido, ou seja, toda a gama variada de riquezas do universo jurídico.

3. Reduções modernas: uma visão potestativa do direito

No final do século XIX, se quisermos manter objetividade ao nosso olhar, podemos contemplar os riscos (e também os danos) do normativismo que nos conquistou, caracterizado

por um direito reduzido a normas, sanções, formas. Pensar o direito como norma (e, deste modo, obviamente, como sanção) significa continuar a pensá-lo como poder, porque significa coagular e levar à exaustão a atenção do ordenamento no momento em que o comando se produz e se manifesta.

Em uma visão particularmente normativa, o que conta é o "comandante" e a sua vontade imperativa (ou, se quisermos, os "mandamentos" e a vontade imperativa deles), enquanto contam muito pouco os utentes da norma e a vida da norma na utilização que a comunidade dos consorciados faz dela. O problema de interpretação da norma, nessa ótica restrita, deve se reduzir a um procedimento de reconstrução – procedimento previsto com precisão aritmética – da vontade imperativa no momento em que essa se separou do "comandante" (sempre antropomorficamente pensado) e coagulou-se em um texto, imobilizando-se nesse até o irromper de uma nova, contrária ou diferente, manifestação de vontade.

Resumindo, ter como referência a norma, querendo ou não, significa, sempre e de qualquer modo, conceber o direito de modo potestativo, ligá-lo intimamente ao poder, mesmo tratando-se de poder em que se percebe a obstinação, tornando-se, portanto, uma realidade perigosa, difícil de ser controlada, orientada e canalizada. Ter como referência a norma e o sistema de normas significa também tomar a estrada que conduz a uma precisa separação entre produção e aplicação do direito, entre comando e vida, entre um comando que se fecha em si mesmo e torna-se, apesar do seu texto,

muito freqüentemente, além e contra esse: é a estrada que conduz a um formalismo que, às vezes, torna-se exasperado na sua abstração.

É a estrada que percorre um dos protagonistas da reflexão jurídica do século XX, o austríaco Hans Kelsen, cuja mensagem científica obteve um sucesso extraordinário entre os juristas, sendo ainda hoje particularmente escutada. Em uma obra como essa, que não tem por objetivo tomar os muitos caminhos das possíveis particularizações, é, porém, indispensável que seja citada a aventura intelectual de Kelsen, seja pelo seu valor exemplar, seja pelo seu peso.

Kelsen sempre conseguiu falar ao coração do jurista de ontem e de hoje por vários e bons motivos: em primeiro lugar, porque não é um filósofo que fala, mas um jurista técnico e empenhadíssimo em grandes operações constitucionais[8], mesmo sendo nutrido por excelentes bases filosóficas e dotado de uma notável força especulativa; em segundo lugar, porque a sua aventura é autenticamente intelectual, respeitabilíssima como tentativa apaixonada de pesquisa de novas fundamentações epistemológicas para a *scientia iuris* após tantas dúvidas demolidoras no que diz respeito a sua cientificidade acumuladas ao longo da Idade Moderna; em terceiro lugar (e venho ao ponto que conduz à finalidade dessa conferência), porque, mesmo se toda a sua obra pode ser vis-

[8] Um exemplo: a Constituição austríaca de 1920; ver, G. BONGIOVANNI. *Reine Rechtslehre e dottrina giuridica dello Stato – Hans Kelsen e la Costituzione austriaca del 1920*. Milano: Giuffrè, 1998.

ta como um grandioso exorcismo contra o poder através da sua racionalização formal-normativa[9], tendo escolhido a norma como pilar da ordem jurídica; o tempo da sua produção como momento necessariamente essencial; o comando, como evento essencial; a coerção como conteúdo essencial, manifestação essencial a sua forma; tudo isso tendo como resultado o fato de esse grandioso exorcismo se revelar substancialmente ineficaz, com o poder dominando indiretamente, com uma presença pesada, todo o itinerário kelseniano, quase como se fosse o coro em uma antiga tragédia grega[10].

Apresenta-se muito sorridente ao jurista moderno imperativista e formalista a construção kelseniana de uma "Doutrina jurídica pura", mesmo se essa se resume em um castelo de formas, em uma harmonia abstrata de linhas, ângulos, círculos, em uma geometria que deveria extrair força de si mesma, mas que tinha a sua origem no nada e no nada se fundamentava.

---

[9] Ótima a reconstrução dessa oferecida por A. CARRINO. *L'ordine delle norme – Politica e diritto in Hans Kelsen*. Napoli: ESI, 1990, 2.ª edição, um pensador benemérito por traduções italianas de obras kelsenianas e por iniciativas de reflexão na Itália sobre o pensamento de Kelsen.

[10] Sem contar que é fácil salientar como "o problema do poder jurídico foi assumindo um relevo sempre maior nas últimas obras" (N. BOBBIO. Kelsen e il potere giuridico. In: BOVERO, M. (a cura di). *Ricerche politiche – Saggi su Kelsen, Horkheimer, Habermas, Luhmann, Foucault, Rawls*. Milano: Il Saggiatore, 1982, p. 6).

4. Indo recuperar a complexidade: a descoberta do direito como ordenamento

O apelo a Kelsen serve para indicar o resultado extremo a que pode conduzir um direito reduzido a um universo de normas e sanções; é um universo bem pobre, que corre o risco de flutuar sobre a sociedade ou até, perversamente, forçá-la e condená-la nos seus desenvolvimentos vitais. É necessário, ao contrário, insistir sobre o direito como ordenamento.

Não se trata de um expediente lingüístico, substituindo um termo por outro e deixando imutável o conteúdo. Ordenamento significa o ato de ordenar, de colocar ordem, e ordem é uma noção preciosa[11] ao menos no seu aspecto: presta contas com a realidade subjacente, a pressupõe na sua onticidade querendo alcançar o objetivo de ordená-la e não de restringi-la; conseqüentemente, registra e respeita toda a sua complexidade. Conceber o direito como ordenamento possui, desse modo, o significado de iniciar a tentativa de recuperação da complexidade, da complexa riqueza do universo jurídico.

Talvez nós juristas não tenhamos plena consciência disso, mas ainda somos, em boa medida, os herdeiros e as vítimas da grande redução iluminista. "Iluminismo significa ampliação da capacidade humana de conceber e de reduzir a complexidade do mundo", "desenvolvimento de mecanis-

[11] Uma leitura bastante instrutiva é a de VIOLA, F. *Autorità e ordine del diritto*. Torino: Giappichelli, 1987, uma reflexão profunda, que desenha para o jurista novas e mais seguras fronteiras.

mos de redução da complexidade", consiste na compreensão, mas também na redução de complexidade. Isso nos foi lucidamente ensinado por Niklas Luhmann[12], um pensador que até pouco tempo todo jurista tinha o dever de citar ao menos uma vez na sua obra (quase como o zelante muçulmano na sua obrigação de fazer uma visita a Meca durante o curso da sua vida). Luhmann, o teorizador da complexidade, com a sua sociologia das renovadas fundamentações iluministas, torna-se também o teorizador da redução.

A redução teve e tem os seus valores positivos: a paisagem jurídica é simples, portanto é clara; iluminada por um sapiente monopólio centralista, também é harmoniosa. Resumindo, uma paisagem persuasiva que, aos olhos do historiador, sofre de dois vícios graves: a abstração e, conseqüentemente, a artificiosidade.

Em outro momento evoquei, em ligação com a Arcádia literária, que, partindo da exigência de se libertar dos emaranhados do barroco, conseguiu-se chegar à suprema ficção de pastorzinhos artificiosos e empoeirados. O palco jurídico não é povoado por pastorzinhos, mas sim por modelos, modelos formais extraídos de um mundo irreal, pré-histórico, e – o que é importante – todos indivíduos; dos quais somente dois fungem como protagonistas, o Estado-pessoa e o indivíduo abastado.

A perda mais substancial que se conseguiu com essa operação redutiva (que é – sabe-se – uma astutíssima operação

[12] LUHMANN, N. *Illuminismo sociologico*. Milano: Il Saggiatore, 1983; as citações estão respectivamente nas paginas 75 e 83.

estratégica) foi a da dimensão coletiva da sociedade, a essa altura já contraída na cristalização estatal. Sufocada pela totalidade macro-coletiva do Estado e pela dialética exclusiva "Estado-indivíduo", configura-se como toda a articulação comunitária fisiológica à sociedade, a cada sociedade, a qual se expressa em comunidade, é e não pode ser comunidade de comunidades. Era a articulação exasperadamente valorizada no Antigo Regime através do protagonismo de famílias, clãs, corporações, associações assistenciais e religiosas, agregações sociais e políticas intermediárias.

No centro da redescoberta da complexidade do universo jurídico é necessário redescobrir também a dimensão coletiva, ou seja, de micro-coletividade, pesadamente sacrificada pelo projeto individualista.

O historiador, perceptor de uma longa linha, sabe que, para a ciência jurídica, o curso do século XX foi um lento, mas constante, florescer de uma consciência mais ampla, válida para recuperar as forças coletivas precedentemente reprimidas com a violência ou, quando muito, exorcizadas com a irrelevância. Uma conquista difícil e de escassos resultados, ao menos nos seus primeiros passos.

Para se ter um exemplo desse fenômeno, basta abrir e folhear o Código civil italiano de 1942, que é expressão do clima corporativista que reinava na Itália naqueles anos: é fácil constatar como o fenômeno associativista é considerado em um modo redutivo; é valorizado tudo aquilo que nasce de um contrato, como acontece com os vários contratos de soci-

edades e, primeiras entre essas, as sociedades comerciais; é tímida a presença das associações livres, que o legislador – quase que para salientar um desprezo – chama de "associações não reconhecidas", contrapondo-as às formalizadíssimas "pessoas jurídicas".

As sociedades intermediárias são ignoradas. Será necessário esperar a Constituição republicana de 1948 para que, graças ao impulso do solidarismo católico de Mortati e de Dossetti, seja reconhecido às formações sociais o papel que efetivamente tinham na sociedade. No imediato pós-guerra, em meio ao desinteresse geral dos juristas italianos especializados em direito privado, saliento o grande mérito cultural do meu predecessor nessa investidura ducal amalfitana, o civilista Pietro Rescigno, que, como jurista especializado em direito privado, tendo por base uma excelente preparação sociológica, começou a estudar as mais conspícuas manifestações associativas (ou seja, partidos e sindicatos), sem dissolver o valor dessas em um genérico e anônimo associacionismo, concebendo-as, ao contrário, como autênticas formações sociais[13].

Uma consideração deve ser feita: existem extratos e dimensões do universo jurídico a serem desenterrados e valorizados. Certamente a experiência jurídica italiana, mesmo a atual, possui uma extensão e uma profundidade bem maior de quanto

[13] Os principais ensaios a que se faz referência podem ser lidos em RESCIGNO, P. *Persona e comunità – Saggi di diritto privato*. Padova: CEDAM, 1987.

pode cobrir a sombra protetora, mas condicionante, da experiência política do Estado. O direito, na sua autonomia, forte por ser enraizado no costume local, viveu e vive, desenvolveu-se e desenvolve-se também fora daquele cone de sombra, mesmo fora dos trilhos constringentes do chamado direito oficial; conseqüência inevitável de não ser dimensão do poder e do Estado, mas sim da sociedade na sua globalidade.

Não é um discurso anarquizante, mas, ou melhor, trata-se do registro daquela realidade efetiva que constitui a pluralidade dos ordenamentos jurídicos. É o grande reino das liberdades do direito, que, efetivamente, não coincide com o majestoso e respeitável ordenamento jurídico do Estado. Aquela que, nos primeiros anos do século XX, foi uma feliz intuição doutrinal, tem a sua verificação na efetividade da vida jurídica, a não ser que tenhamos lentes míopes diante dos nossos olhos. Como historiador do direito, toquei e toco com as mãos essa realidade pluri-ordenamental quando, por tarefa inerente ao meu ofício, sou chamado a analisar as propriedades coletivas na região alpina, sobretudo do arco alpino oriental: uma ordem jurídica fundamentada em costumes primordiais que podem ser qualificados como pré-romanos, que contrastam com a configuração individualista e quiritária da propriedade moderna apoiada pelo direito oficial, que, até aos nossos tempos, tiveram uma vida muito distante, que o Estado moderno sempre tentou "liquidar", nunca deixando de perseguir e desnaturar. Como historiador do direito, não hesito em registrar a presença, no mesmo território do

Estado italiano, de ordenamentos jurídicos originários, ordenamentos alienígenas, que nascem de diferentes antropologias (ou mesmo opostas) e são portadores de diferentes (ou mesmos opostos) valores jurídicos, que têm a sacrossanta pretensão de conviver com a oficialidade dominante por serem o sinal da complexidade da experiência jurídica que o direito do Estado não consegue levar à exaustão.

Devido à familiaridade que tenho com elas, tenho feito, como outras vezes o fiz, referência ao caso das propriedades coletivas. Mas os exemplos poderiam se multiplicar. A conclusão é certa, ou seja, a paisagem jurídica, justo por estar nos nervos do social, é complexa por natureza. A Idade Moderna, idade de mitologias jurídicas, encolheu-se em um constrangedor horizonte de modelos, sendo a complexidade da experiência jurídica notavelmente sacrificada. Visão potestativa do direito, sua estatalidade, sua legalidade, constituíram um observatório deformante, já que, baseando-se unicamente no momento e no ato da produção, a regra jurídica se apresenta como norma, ou seja, como comando autoritário do titular do poder.

5. Em direção a novas fundamentações para a positividade do direito

É um observatório que deve ser, se não deposto, ao menos integrado; a esse propósito, a visão ordenamental pode servir como uma verdadeira salvação.

Repetimos: ordenamento é uma noção que tem a ordem no seu coração; e ordem, justo por não poder prescindir da realidade a ser ordenada, justo por ser, necessariamente, escuta e recepção de instâncias provenientes da realidade, põe-se como preciosa mediação entre autoridade e sociedade, não assumindo o aspecto desagradável da coerção. É claro que estaríamos perante um simulacro falsificador se fosse verdade o que se fala sobre a existência de uma ordem durante o domínio russo em Varsóvia, fruto de um enorme tributo de sangue e de mortos, ou sobre a existência de uma ordem como a de Hitler ou a de Stalin, ambas obtidas através da violência policial.

A ordem é – isso sim – noção que traz consigo rigor, exatamente porque compõe e ajusta o inevitável conflito entre os fatos históricos, por si obstinados e desligados; ordem implica rigor, assim como rigor implica a transformação em direito de toda incomposta e magmática realidade social. A visão de um direito "dócil", como foi proposto no persuasivo desenho de um dos mais inteligentes e cultos constitucionalistas italianos[14], parece-nos entregue às tramas de uma feliz idealização mais do que as de um diagnóstico realista.

Porém, uma coisa é certa: a ordem, se é rigor, se torna rigoroso o mundo indócil dos fatos, significa respeito à complexidade e à pluralidade do real; ou seja, o oposto de massificação e de simplificação forçada. A inteligência perspicaz de Tomás de Aquino, contemplador de uma paisa-

[14] ZAGREBELSKY, G. *Il diritto mite – Legge diritti giustizia*. Torino: Einaudi, 1992.

gem universal ainda não fragmentada, nem politica, nem juridicamente e, ao contrário, percorrida e regida por uma consciência ordenadora coletiva – a paisagem do século XIII –, especifica-o bem em uma daquelas explicações onde emerge a sua excepcional força especulativa: "*esse unum secundum ordinem, non est esse unum simpliciter*", a unidade realizada mediante a ordem nunca é uma unidade simples[15]. Em outros termos, ordenar não significa submeter o real a uma renovação fictícia fazendo "*de albo nigrum*", construindo uma unidade desmentida pelos fatos subjacentes, mas significa compor a unidade complexa e plural, fazendo com que as diversidades possam se tornar força daquela unidade sem se aniquilarem. Como salienta o próprio Tomás, a ordem é a unidade que harmoniza, mas, ao mesmo tempo, respeita as diversidades[16].

De tudo isso, é urgente levar em consideração o fato de termos, por dois séculos, angustiado-nos em um zelo obcecado pela formalização e pelo esclerosamento da positividade do direito. Falar de direito positivo, até pouco tempo atrás, era como se referir a uma noção fechada, impermeável.

O jurista a pronunciava com incipiente orgulho, pensando estar se referindo a um universo de normas fechado em si mesmo, como se fosse uma fortaleza de fronteira, forte na

---

[15] S. TOMMASO. *Summa contra gentiles*, II, C. 58.

[16] "Ordo includit distinctionem, quia non est ordo aliquorum nisi distinctorum" (S. TOMMASO. *Scriptum in 4 libros Sententiarum magistri Petri Lombardi*, l. 20, l. 3, lc.).

sua separação de todo o resto, circundada por um fosso intransponível formado pela estatalidade, pela oficialidade, pela autoridade. E o jurista se satisfez com essa couraça sem se dar conta da prisão e da imobilização que a mesma constituía para ele.

Era – e ainda hoje é – uma noção de positividade que não nos restitui, senão opacamente, a complexidade que a ordem jurídica tem por dever organizar, e não trair; uma complexidade que, porém, continua a ser traída quando o direito positivo continua a ser pensado como um universo de normas, um castelo de comandos, posto (*positum*) por uma autoridade que formalmente possui o poder e, portanto, munida do crisma tranqüilizante da oficialidade.

Tudo isso é, de um ponto de vista cultural, ou seja, para uma cultura jurídica que tenta se propor como válida ordenadora do presente, uma posição tão criticamente baixa que chega a impedir uma observação completa. Esse "ontem", que tínhamos esperanças que fosse completamente superado, continua no "hoje" no interior da consciência de muitos juristas, sobretudo na consciência dos práticos, deseducados por uma doutrina jurídica que abdicou da sua nobre função pedagógica. Esse "ontem" continua no "hoje" através da perfeita vigência do artigo 12 das disposições preliminares ao Código civil italiano de 1942, que confirma o dogma da estatalidade do direito e fixa os limites da juridicidade identificando-os com os do Estado. Sei bem que aquele artigo é um evidente violador do pluralismo jurídico

impresso na Carta constitucional italiana, sei bem que os juristas mais conscientes o consideraram relíquia de convicções passadas, mas sei também muito bem que as relíquias – enquanto existirem, expostas ao público – ainda podem receber a veneração dos insipientes. Como salientei outras vezes, ficarei mais tranqüilo quando o artigo 12 será varrido da esplêndida codificação italiana, como um traço inadmissível do estatalismo autoritário fascista, do mesmo modo como foram prontamente expurgados os imundos traços concernentes ao primado da raça ariana.

Foi um sinal eficaz, do ambíguo momento de ruptura em que ainda nos encontramos, a iniciativa tomada dez anos atrás por um inteligente filósofo italiano do direito, Giuseppe Zaccaria, que convidou diversos colegas de disciplina, mas também prudentemente alguns estudiosos do direito positivo, para discutir sobre "Direito positivo e positividade do direito"[17].

Na apresentação que fez à obra, Zaccaria insiste, tendo rara consciência da grande necessidade de refundamentação cultural do jurista atual, sobre "o organismo global da positividade", sobre o "funcionamento necessariamente 'plural' da positividade"[18], apontando com exatidão para um horizonte a ser concluído com urgência, ou seja, a ampliação inadiável da tradicional e esclerosada noção de positividade do direito.

---

[17] Torino: Giappichelli, 1991.
[18] ZACCARIA, G. *Presentazione*, *idem* (os textos citados se encontram na página XII).

Se o convite do coordenador da obra foi aceito e desenvolvido por alguns filósofos do direito, sobretudo por Francesco Viola[19], a parte que diz respeito aos estudiosos do direito positivo italiano põe-se, ao contrário, sob a égide de uma ambigüidade substancial; isso, mesmo se Zaccaria contava, nas pessoas do administrativista Guida Corso e do comercialista Mario Libertini, com dois cultos e sensíveis representantes da vida jurídica italiana.

O ensaio escrito por Corso é dominado pela idéia do primado da norma, delineando o jurista especializado em direito público como um personagem em uma busca desesperada de normas[20]; e especifica Corso: "o jurista positivo, mesmo o mais disposto a reconhecer as contribuições da jurisprudência, concebe a norma como um *quid* que logicamente e idealmente precede e condiciona a interpretação"[21]. Um contexto onde teimosamente parece se repetir a separação entre norma e interpretação, um fenômeno que freqüentemente condenou delicadas áreas do sistema normativo à morte por asfixia.

Libertini demonstra ainda estar amarrado por laços culturais dos quais, porém, não quer se livrar; e demonstra-se inteiramente intencionado a fornecer a esses alguma justificativa que possa tornar opaca a sua límpida consciência de jurista. "O aceite de uma ética da legalidade – escreve ele –,

---

[19] VIOLA, F. *Tre forme di positività nel diritto, idem.*
[20] CORSO, G. *In che senso il diritto positivo costituisce un vincolo per il giurista, idem*, p. 42-43.
[21] CORSO, G. *Idem*, p. 54.

faz com que o respeito das leis seja expressão do princípio geral de civilização do '*stare pactis*' e, desse modo, reconhecimento de que todos os cidadãos pertencem à mesma organização social"[22]; "a fidelidade à lei não deve ser entendida como obediência a um comando, mas como leal execução de um pacto"[23], "o princípio de lealdade impõe o aceite da idéia do primado do poder legislativo e, deste modo, o dever de 'levar a sério' as escolhas políticas do legislador"[24]. Um discurso em que, excluindo a enchente de argumentos paleo-*jus*naturalísticos, retorna-se ao velho fundamento mítico de um poder legislativo – e, deste modo, político – que interpreta e expressa com fidelidade o bem comum, tendo condições de representá-lo normativamente. Libertini insiste, com medo de que o argumento não tivesse sido bem compreendido: "reconhecer o princípio (a exigência, o valor) da taxatividade das fontes é também um modo de 'levar a sério' o Estado; e isso me parece ainda hoje indispensável (necessário, apesar de não ser suficiente) se se possuem certos valores e escopos políticos (liberdade, igualdade e segurança dos indivíduos)…"[25]. O autor conclui colocando-se a favor do "aceite do postulado da soberania, unidade e plenitude do ordenamento estatal" e da "taxatividade das fontes formalmente reconhecidas"[26], uma solução *jus*positiva que "perma-

[22] LIBERTINI, M. *Il vincolo del diritto positivo per il giurista*, *idem*, p. 74.
[23] *Idem*, p. 75.
[24] *Idem*, p. 76
[25] *Idem*, p. 89.
[26] *Idem*, p. 90.

nece mais moderna e mais maleável"[27]. Uma longa linha, bissecular, parece ter continuidade nesses escritos.

6. Interpretação-aplicação e novas fronteiras da positividade do direito

Realizamos essa análise aprofundada da iniciativa de Zaccaria e das contribuições nessa presentes, porque, na sua integralidade, parece ser um sintoma do trabalho atual do jurista italiano quando nos introduz no sacrário do moderno direito burguês, ou seja, o recinto das fontes, que se assemelha muito ao espaço sacro onde somente os membros de uma suprema hierarquia sacerdotal ingressava. O convite de Zaccaria não foi substancialmente acolhido pelos estudiosos do direito positivo, que ainda estão totalmente envolvidos no manto protetor do normativismo legalista. Um ponto específico desse convite foi expressamente rejeitado, o de "destacar a dimensão hermenêutica"[28] como elemento interno, essencial, da positividade da norma.

É a conquista que ainda deve ser realizada. A teoria hermenêutica deu, ao longo do século XX, passos enormes, aproximando de forma evidente o momento normativo e o momento de interpretação-aplicação. Atualmente estamos bem longe de poder tecer elogios à exegese, mesmo se recentemente existiram inundações neo-exegéticas. Mas o salto do fosso, que tornaria possível romper com os entraves

[27] *Idem*, p. 92.
[28] Como Zaccaria explica na *Presentazione* do volume (*idem*, p. X).

normativistas e adquirir uma visão ampla e integral da normatividade e da positividade, não tivemos a coragem de fazer. Na verdade, não éramos culturalmente capazes de nos libertarmos. Também porque a tradição pós-iluminista teve uma grande influência sobre operadores frágeis demais.

O ensaio de Guido Corso, acima mencionado, parece estar indicando o último elo de uma longa corrente, ainda solidíssima. E mesmo ao longo do século XX, existiram mensagens em direção oposta, que deveriam ser bem recebidas por serem provenientes não da imaginação de um filósofo, mas de robustos técnicos do direito imersos na práxis quotidiana (o primeiro nome que me vem em mente é o de um autor que me é caro, o comercialista Tullio Ascarelli).

O único meio para retirar do direito esse tradicional e repugnante esmalte potestativo e autoritário era e é conceber a norma como um procedimento que não se cumpre com a produção, mas que possui um momento subseqüente, o momento de interpretação, como se ele estivesse dentro do processo de formação da realidade complexa da norma; resumindo, a interpretação como momento essencial da positividade da norma, uma condição ineliminável para a concretização da sua própria positividade.

Certamente, para chegar a ele, os juristas precisam de outras lentes; lentes que não diminuam a interpretação a uma dimensão meramente cognitiva, mas que a concebam como vida da norma no tempo e no espaço, carnalidade da norma enquanto exercício, práxis, uso; lentes que também estejam

dispostas a acolher na paisagem jurídica a comunidade dos utentes em um papel que não seja meramente passivo, que estejam dispostas a admitir não somente um protagonista monocrático (o detentor do poder), mas sim uma ampla pluralidade de sujeitos. Talvez, tenha mesmo chegado o momento de começar a construir o direito também mediante aqueles sujeitos que a tradição chamou, com implícito desprezo, de os destinatários do comando.

Ao concluir essa conferência, torna-se possível captar o seu sentido através da indicação de duas idéias aqui recuperadas.

O direito é mais aplicação do que norma. Seria um desastre se um comando fosse imobilizado, ainda mais se o comando encontra a sua própria imobilização em um texto; seria um desastre se a regra jurídica se tornasse e permanecesse somente um pedaço de papel. O provável risco é que essa se separe da vida.

O direito é, em primeiro lugar, ordenamento; com isso vem salientado, além da mudança terminológica, que a sua autoridade está nos conteúdos em que se entrelaça e que propõe, está no fato de ser leitura objetiva da realidade, tentativa de racionalização do real. É uma autoridade que se move debaixo para cima, que torna espontâneo o aceite social e a observância; a observância – que é o grande mistério do direito – por isso mesmo perde a repugnância da coerção. Com o direito-ordenamento o homem do povo também pode se reconciliar.

7. Em direção ao declínio da mitologia jurídica pós-iluminista

Falamos de conteúdos e de racionalização do real, um desvio brusco no que diz respeito ao modo como o projeto jurídico burguês se desenvolveu entre os séculos XVIII e XIX, definindo-se com um progressivo processo de consolidação.

A norma suprema, que está no ápice da pirâmide hierárquica, ou seja, a lei, configura-se nesse projeto como um recipiente vazio, porque – sendo por definição axiomática expressão da vontade geral – não recebe, dos diferentes conteúdos, nenhuma contribuição a sua figura essencial. Efetivamente, uma norma não pode ser qualificada como lei em razão do seu conteúdo, mas por ter a sua origem no detentor da soberania, que a filtra mediante um rigoroso procedimento formal.

A lei vazia era uma espécie de sapientíssima forma dentro da qual um legislador onisciente, infalível, onipotente, poderia hospedar qualquer conteúdo que desejasse. O ordenamento jurídico, resumido em um grande esqueleto legislativo, admitia um só cordão umbilical, aquele com o poder, o único de onde pudesse retirar vitalidade, nutrimento, efetividade, não reconhecendo nenhum outro que representasse a complexidade da sociedade.

Em uma ordem como essa, legicêntrica e legolátrica, o supremo princípio constitucional passa a ser o de legalidade, que funge como precioso fecho; e torna-se evidente o fato de tratar-se de uma legalidade concebida em sentido

estreitíssimo como respeito da forma-lei; torna-se claro, por isso, que é legalidade, seja o respeito da lei que proíbe o homicídio (com todo a sua carga ética), seja o respeito da lei que sanciona o primado de uma raça sobre outra e impõe diminuições da capacidade para os pertencentes a um *etnos* considerado inferior. Desse modo, o princípio de legalidade perde todo seu valor de garantia, passando a representar somente o fosso intransponível que circunda e fecha de modo perfeito o mítico castelo, já edificado dessa forma. Seria interessante se os legalistas inconscientes, legalistas a qualquer custo, finalmente se dessem conta de tudo isso.

É obvio que essa mitologia, submetida à usura de dois séculos de vida jurídica, lentamente e beneficamente se deteriorou, enquanto a dogmática na qual se fundamentava revelava o seu próprio caráter mítico; e é obvio que, hoje, o profundo fosso que circunda o castelo foi em boa parte aterrado. Mas com quanta lentidão e com quanto esforço, nessa Europa continental tão caracterizada e quase marcada a fogo pela habilíssima propaganda pós-iluminista!

Ainda ontem, este que vos fala recebeu com satisfação um rico volume em que está compendiado o trabalho de um grupo de pesquisa, promovido e coordenado com sensibilidade e inteligência crítica por Michele Scudiero, sobre o problema da discricionariedade do legislador na jurisprudência da Corte Constitucional Italiana entre os anos 1988 e 1998[29].

[29] SCUDIERO, M. et STAIANO, S. *La discrezionalità del legislatore nella giurisprudenza della Corte Costituzionale (1988-1998)*. Napoli: Jovene, 1999.

A discricionariedade do legislador! Um dos organizadores da obra tem razão ao qualificá-lo "tema indócil"[30], em relação ao seu aspecto de clamorosa e ruinosa fenda nas muralhas do castelo mitológico há pouco mencionado, com a previsão de um juiz das leis e a queda do mito da infalibilidade.

Há algum tempo, finalmente a Corte Constitucional Italiana passou a fazer precisos e incisivos apelos à razoabilidade como limite da ação legislativa e ao direito vivo. Em um sistema formalista podem também aparecer simples "fórmulas verbais"[31]; o historiador do direito não hesita em ver nessas os traços da cansativa busca de ancoradouros (talvez toscos e imperfeitos) para a conquista daquele horizonte de civilização jurídica que é, deposto o esquema insaciável do mito, a lei justa, a justiça das leis. Uma conquista que o fundamento mitológico-dogmático tornou incerta e difícil.

A França, laboratório da modernidade jurídica continental, é o espelho mais fiel desse fenômeno; efetivamente, seria instrutivo repercorrer a íngreme subida, plena de obstáculos e de tortuosidade, ao qual ápice, em 1958, com a Constituição da Quinta República, chega-se à previsão, com a instituição do *Conseil Constitutionnel*, de um juiz das leis; seria instrutivo repercorrer o debate constelado de inacreditáveis

---

[30] STAIANO, S. *Introduzione, idem*, p. XIII.

[31] Vede PALADIN, L. *Esiste un 'principio di ragionevolezza' nella giurisprudenza costituzionale?*, in *Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza della Corte Costituzionale* (Atti del seminario, Roma 13-14 ottobre 1992). Milano: Giuffrè, 1994, p. 164 ss.

asperidades[32]; seria instrutivo seguir o empenho com o qual a esquerda democrática francesa, como autêntica herdeira dos programas jacobinos, interpretou a previsão como um "golpe de Estado permanente"[33], como um permanente fator de risco para a estabilidade do sublime e progressivo edifício constitucional projetado nos férteis anos da Revolução.

Falta somente um ponto para a conclusão desse discurso: razoabilidade, adequação, não arbitrariedade, apelo ao direito vivente, além do fato de serem indicadores genéricos e mesmo ambíguos, ao menos possuem o sentido e o valor de uma tentativa de apoio sob algumas formas. As mitologias, que tiveram um papel fundamental no projeto jurídico burguês, não conseguem se manter em pé diante das necessidades e das solicitações da sociedade contemporânea, extremamente complexa sob os aspectos social, econômico, tecnológico. Sob os esquemas formais – lineares, simples, em harmonia entre si –, existe uma constituição material que pressiona e que urge levar em consideração, se não queremos que se chegue a separações que podem se transformar em rupturas.

O direito – e menos ainda o direito moderno – não pode abdicar da sua dimensão formal, fornecendo categorias à incandescente fluidade dos fatos sociais e econômicos, mas

---

[32] Vede, na já citada obra organizada por Scudiero e Staiano, o ensaio de PATRONI GRIFFI, A. *Il Conseil Constitutionnel e il controllo della 'ragionevolezza': peculiarità e tecniche di intervento del giudice costituzionale francese*.

[33] Faz-se referência ao célebre *pamphlet* de François MITTERRAND. *Le coup d'état permanent*. Paris: Plon, 1964 (cfr. *Le Conseil Constitutionnel et les partis politiques*. Aix-en-Provence: Presses Universitaires, 1988, Introduction)

deve fazê-lo com a consciência sempre viva de que aquelas categorias dão forma e figura a um saber encarnado, a uma história viva. Resumindo, devem se tratar sempre de categorias ordenantes, que pescam na realidade, que não flutuam sobre o real, como acontece com todo fenômeno autenticamente e não ficticiamente ordenante. Ser e dever ser necessariamente se confundem, condenando as teorias puras a ficarem entre os admiráveis exercícios retóricos de engenhosíssimos juristas.

Gustavo Zagrebelsky tem razão quando – há alguns anos – afirmava categoricamente: "a idéia de direito que atualmente implica o Estado constitucional não entrou plenamente no ar que os juristas respiram"[34]. Uma velha idéia de legalidade, legalidade formal, deve substituir-se, e cada vez mais deve ser substituída, por uma legalidade diferente, que no final leve plenamente em consideração os dois níveis de legalidade em que se articulam os ordenamentos modernos, ou seja – para nos entendermos –, o dos Códigos e o constitucional, sendo que esse segundo expressa a sociedade nos valores que ela leva consigo e não somente a cristalização bastante pobre que se traduz no Estado-aparelho.

Deve ser superada a idéia de que o direito é feito mediante leis e que somente o legislador é *Jus*produtor, capaz de transformar tudo em direito, quase como um Midas dos nossos dias. Quantas vezes os produtos normativos fabricados

[34] ZAGREBELSKY, G. *Il diritto mite – Legge diritti giustizia. Op. cit.*, p. 4.

pelos legisladores modernos se mostram longe do ser direito! A hipertrofia e a hipervalorização da lei já custaram muito caro à sociedade e à cultura da Europa continental, assim como às zonas do mundo que essa condiciona. Através de um prisma desse tipo, falou-se de "descodificação" e até mesmo de "deslegificação". A exigência é uma e somente uma: retirar a lei do papel totalitário e socialmente insuportável que a idade burguesa lhe concedeu.

Somente um louco poderia pensar em prescindir da presença de normas imperativas gerais ou mesmo de Códigos. O que não precisamos, ao invés, é do instrumento pernicioso que se constitui em leis e Códigos que, com a minúcia de uma pormenorizada regulamentação da vida econômica e social, correm o risco de permanecer letra morta no momento seguinte à promulgação, por serem rejeitados pela comunidade dos utentes ou, pior ainda, terminam por amordaçar as comunidades, impedindo-as de se expressarem segundo o desenvolvimento do costume e a evolução das realidades econômicas e das ordens sociais.

A rapidez da transformação contemporânea exalta, em todas as suas manifestações, um primado da práxis. Quantos institutos, sobretudo no direito dos negócios, são intuídos, inventados, modelados na prática cotidiana, enquanto o legislador nacional ou comunitário limita-se a intervir tardiamente, apropriando-se do que o uso já tinha consolidado! O futuro direito econômico tende a ter um vulto geneticamente extralegislativo, com uma forte contribuição ofereci-

da pela reflexão científica. E se assiste a "atores modificados protagonistas do processo jurídico", a "diferentes modalidades de produção e de funcionamento das regras jurídicas"[35], a uma crescente privatização da produção jurídica: vitais centros monopoiéticos (ou seja, produtores de regras jurídicas pontualmente observadas pelos indivíduos) já estão inseridos em núcleos sociais, econômicos e culturais muito distantes dos Estados[36].

Essa é uma panorâmica que me sinto grato de mostrar aqui, na *Civitas* Amalfitana, na sede do seu município, nessa extraordinária forja jurídica medieval, onde mercadores e navegadores destemidos participaram da criação, mesmo sendo pobres de leis e de ciências, mas fortes na própria capacidade de escuta das forças econômicas e confiando quase unicamente na sensibilidade e na intuição do direito comercial e marítimo da *koiné* mediterrânea da idade média[37].

---

[35] Como bem se expressa uma inteligente socióloga do direito em uma obra a ser lida e meditada pelos juristas (cfr. FERRARESE, M.R. *Le istituzioni della globalizzazione – diritto e diritti nella società transnazionale*. Bologna: Il Mulino, 2000, p. 7).

[36] Tratam-se de instituições internacionais de organização cultural, de grandes escritórios profissionais, de grupos de empresários e assim por diante.

[37] Aos mercadores e navegadores amalfitanos, que tinham sólidos pontos de apoio no mediterrâneo oriental, foi concedido importar uma série de costumes de origens gregas. Ver, BOGNETTI, G.P. La funzione di Amalfi nella formazione di un diritto comune del Medioevo, in *Mostra bibliografia e Convegno internazionale di studi storici del diritto marittimo medioevale* – Amalfi, julho-outubro de 1934, Atti, Napoli, Associazione Italiana di diritto marittimo, 1934, p. 55-51.

III
CÓDIGOS: ALGUMAS CONCLUSÕES ENTRE UM MILÊNIO E OUTRO*

* Trata-se do texto da conferência final no Congresso *"Codici – Una riflessione di fine millennio"* (Códigos – Uma reflexão de final de milênio) acontecido em Florença nos dias 26 a 28 de outubro de 2000. Isto explica as referências a conferencistas e conferências do mesmo congresso. Foram omitidas as palavras iniciais de saudação, que podem ser lidas no texto publicado contendo os "Anais" do congresso. Nesta redação – que se dirige a um público possivelmente mais vasto, também de estudantes – foram inseridas notas integradoras contendo explicações, com a finalidade de tornar mais claras a esse público de leitores, afirmações e referências concisas perfeitamentes compreensíveis (mesmo na sua concisão) aos ouvintes do Congresso *fiorentino*.

1. O Código e o seu significado na modernidade jurídica. — 2. O Código e os elementos que historicamente o caracterizam. — 3. O Código hoje: algumas considerações do historiador do direito.

1. O Código e o seu significado na modernidade jurídica

Como historiador do direito sinto-me no dever de começar essas anotações dividindo com vocês uma preocupação. Uma noção nunca foi tão marcada por uma intrínseca polissemia como acontece no caso da noção de Código: o vocábulo unitário permite aproximar o Código Hermogeniano[1], o Código Justiniano[2], o Código Napoleônico e todos os demais Códigos, cada vez mais freqüentes na práxis contemporânea, que ouvimos mencionar nas várias conferências, em particular nas proferidas pelos estudiosos do direito positivo (Código dos jornalistas, dos consumidores, dos seguros, dos princípios, das regras, Código comum europeu dos contratos, e, assim por diante); o vocábulo unitário, tendo como denominador comum a tendência a estabilizar o instável, o que caracteriza toda

[1] Por Código Hermogeniano (*Codex Hermogenianus*) os historiadores do direito se referem à compilação sistemática de atos imperiais redigidas no século IV d.C. pelo jurista Hermogeniano.

[2] Ou seja, o recolhimento sistemático, em doze livros, das constituições imperiais mais relevantes, promovida e realizada na primeira metade do século VI d. C. pelo imperador Justiniano I.

codificação[3], através do engano que é típico de certas impassíveis persistências lexicais, mistura e associa realidades profundamente diferentes por origem e por função, gerando confusões e equívocos culturalmente perniciosos. O historiador do direito, cumprindo o seu *métier* fundamental, que é o de comparar, relativizar, diferenciar, sente a armadilha que se constitui no léxico, prefere abandonar o simulacro unitário e cair na realidade histórica que é, ao contrário, substancialmente marcada por insanáveis descontinuidades.

Deve ser salientada com vigor ao menos uma dupla descontinuidade: aquela entre o "Código do consumidor" de que hoje se fala (para dar um exemplo) e o que para nós, historiadores do direito, é *o Código*; entre esse último e os muitos Códigos da qual estava repleta – por exemplo – a Antigüidade clássica. Os tênues elementos associados – que existem – não devem enfraquecer a absoluta tipicidade histórica daquela escolha fundamental da civilização jurídica moderna que pôde se definir completamente entre os séculos XVIII e XIX na Europa continental, escolhida não por esta ou aquela política contingente, mas tão radical a ponto de se colocar como marco fronteiriço na história jurídica ocidental, assinalando um "antes" e um "depois" caracterizados por uma íntima descontinuidade, escolha que permite aos

[3] No âmbito dos trabalhos do Congresso foram dignas de atenção as palavras iniciais de saudação do Pro-reitor, Professor Giancarlo Pepeu, docente na Faculdade de Medicina, o qual salientou o uso que é feito da palavra "Código" na ciência médica (como, por exemplo, quando se fala de "Código genético") para indicar um conjunto de elementos marcados por uma íntima fixidade.

historiadores falar corretamente de "Código símbolo", "Código mito", de "forma Código", de "idéia de Código"[4].

Em outras palavras, para o historiador do direito, podem existir e existem muitos "Códigos", para os quais pode ser convencional e inócuo o emprego de um vocábulo unitário, mas, somente um é *o* Código, que irrompe em um determinado momento histórico, fruto de uma autêntica revolução cultural que bate em cheio e devasta os fundamentos consolidados do universo jurídico; justo por essa sua carga incisiva, justo por ser também e sobretudo uma *idéia*, o Código pode sofrer uma transposição, e, a partir do plano terrestre das fontes comuns de direito, vir a encarnar um *mito* e um *símbolo*. Porque, de fato, o Código quer ser um ato de ruptura com o passado: não se trata de uma fonte nova ou de um novo modo de conceber e confeccionar com profundidade e amplitude a velha *ordonnance*[5] real; trata-se, ao contrário, de um modo novo de conceber a produção do direito, e, desse modo, o inteiro problema das fontes, assim como o problema primário da conexão entre ordem jurídica e poder político.

Fez bem o amigo Halpérin ao nos oferecer, entre várias imagens significativas, a de Napoleão I quando esse rejeitava

---

[4] Amava falar de uma "idéia de Código" um grande estudioso italiano de direito comercial, Tullio Ascarelli. Sobre ele, vede, sobretudo, o iluminadíssimo ensaio: *L'idea di codice nel diritto privato e la funzione dell'interpretazione* (1945), atualmente em *Saggi giuridici*, Milano, Giuffrè, 1949.

[5] Com o termo *ordonnance* se entendia, na história medieval e pós-medieval do Reino da França, a norma que expressava a vontade do príncipe-soberano.

o velho *droit coutumier*[6]: nessa, foi testemunhada a presunção do primeiro[7] autêntico codificador da história jurídica européia – de romper com o passado por aquilo que o passado representava sob o aspecto da visão do "jurídico" e da posição do "jurídico" no "social" e no "político". Sob esse perfil, o "Código" expressa a forte mentalidade forjada no grande laboratório iluminista e se encontra – enquanto tal – em áspera polêmica com o passado.

Com esse esclarecimento, que deve ser feito: é obvio que, se olhássemos o tecido do primeiro verdadeiro Código, o *Code civil*, e, ainda mais se olhássemos os seus trabalhos preparatórios, poderíamos constatar a fértil continuidade de institutos cunhados e aplicados na imemorável práxis consuetudinária. Os redatores, primeiro entre eles Portalis[8], eram homens nascidos e educados sob o Antigo Regime, assim como não surpreende o fato de esses serem portadores, nas suas subconsciências, de noções, costumes, esquemas técnicos, enraizados na experiência da sociedade francesa e, portanto, aceitos e vividos na vida cotidiana. Isso eu daria por certo, considerando que a história nunca realiza saltos improvisados, e o futuro sempre tem um vulto antigo. O que conta é o que emerge e o

---

[6] Com a expressão *"droit coutumier"* entende-se, no antigo direito francês, o complexo do direito consuetudinário espontaneamente florescido e aplicado nas várias práticas locais e, sucessivamente, consolidado em redações escritas.

[7] Por motivos que pareciam claros no desenvolvimento dessas considerações, o Código Prussiano, o *"Allgemeine Landrecht"* de 1794, que admitia ainda a hétero-integração por parte dos direitos locais, é mais corretamente inquadrável entre as consolidações do século XVIII do que entre as verdadeiras codificações.

[8] O jurista francês Jean-Etienne-Marie Portalis (1746-1807) foi um dos protagonistas na redação da grande codificação ordenada por Napoleão I.

completo delinear de uma mentalidade energicamente nova que investe o coração da ordem jurídica, ou seja, o modo de conceber e de realizar a produção do direito. Neste ponto – que é uma noção crucial sobre a qual se edifica o jurídico –, concepções e soluções estão em uma polêmica frontal.

A produção acontecia no mundo pré-revolucionário através de três elementos básicos que a caracterizavam.

Era transbordante, ou seja, seguia sem tentar obrigar o advir da sociedade a se manter dentro de margens muito vinculantes: as opiniões dos doutores acumulavam-se uma após a outra, formavam-se opiniões comuns, mais que comuns, comuníssimas[9], entesourizantes naquelas confusas colheitas dos séculos XVII e XVIII, que forneciam aos práticos o suporte para as pretensões processuais; as sentenças se acumulavam uma após a outra, sendo que os Tribunais mais ilustres tinham a sorte de poder imprimi-las naquelas enor-

[9] Quando se fala de doutores, nos referimos aos *doctores*, ou seja, aos mestres do direito, os quais, com a *interpretatio* do velho direito romano justiniano e do direito canônico, constituíam o instrumento de adequação daquelas normas às exigências da experiência jurídica medieval e pós-medieval em contínuo crescimento e punham-se, por isso, como autênticas fontes do direito comum europeu. Aquelas *opiniones*, pareceres jurídicos que eram expressão não somente do jurista, mas que, pelo seu sucesso e pelo seu recebimento geral, poderiam parecer a expressão de toda a classe dos juristas, as chamadas *opiniones communes*, opiniões comuns, conseguiam ter uma particular autoridade junto aos juízes. Por isso, muito cedo, começou-se a recolhê-las, como preciosos subsídios para os advogados, organizando-as segundo os vários problemas a que se referiam. Nessa corrida, voltada a fornecer ao advogado instrumentos infalíveis para serem vitoriosos nas diferentes causas, existiu, no direito comum tardio (séculos XVII a XVIII), uma concorrência entre os vários recolhedores, que propunham não somente "opiniões comuns", mas até mesmo "mais que comuns" ou "comuníssimas".

mes coleções sobre as quais teve o mérito de ter chamado a atenção – único entre nós – o caro amigo Gino Gorla[10].

Era pluralista, ou seja, estava em conexão com a sociedade e com as suas forças plurais, expressando-as sem particularizações artificialmente construídas.

Era, conseqüentemente, extra-estatal, ou seja – excetuando as zonas que se encontravam em íntima relação com o exercício da soberania –, não registrava a voz do poder político contingente, conservando-se de um indefectível condicionamento. Em um ensaio bastante consciente, o romanista-civilista Filippo Vassalli advertia, em 1951, que o direito civil, o direito das relações cotidianas entre os indivíduos, tinha tido até a Idade do Código a conotação de uma íntima extra-estatalidade, encontrando a sua fonte nos indivíduos, nos costumes instituídos e observados pelos indivíduos, sucessivamente reduzidos em esquemas técnicos pela classe dos juristas[11].

Tudo isso vem apagado pela obstinação codificadora, não sendo por acaso que Napoleão queria realizar, com o *Code civil*, a primeira etapa de uma codificação totalizante. Uma circunstância nada banal, ou melhor, um gesto de suprema

---

[10] O civilista e comparativista italiano Gino Gorla (1906-1992) dedicou-se com paixão a vastas e relevantes obras de escavação das coletâneas de acórdãos dos grandes Tribunais que atuavam na época do direito comum tardio. Uma importante coletânea de escritos de Gorla é *Diritto comparato e diritto comune europeo*, Milano, Giuffrè, 1981.

[11] VASSALLI, F. *Estrastatualità del diritto civile*, atualmente em *Studi giuridici*, volume III, tomo II, Milano, Giuffrè, 1960.

coragem, em que o novo Príncipe pós-revolucionário ousava, seguríssimo de si mesmo, legislar em um terreno difícil, a razão civil, ultrapassando os limites onde os legisladores do passado tinham parado, mesmo os de Luís XIV, que com as suas grandes *Ordonnances* tinham realizado uma primeira experiência de redução de boa parte do direito a um corpo de leis soberanas[12]. O que Luís considerou que fosse melhor continuar regulamentado por costumes imemoráveis, sedimentados em um longo processo, agora – em 1804 – Napoleão aprisiona nos 2.281 artigos do *Code civil*, onde todo o direito civil passa a ser previsto, onde existem regras minuciosas para cada instituto (que freqüentemente encontra até mesmo a sua definição, elaborada pelo próprio legislador).

Tudo isso horroriza a velha lógica transbordante, cria aversão para aquele colocar-se nas mãos da história, mesmo a simples história de todos os dias, que foi o traço marcante da ordem jurídica tradicional. A historicidade do direito não satisfaz o novo Príncipe, ou melhor, mostra-se a ele no seu aspecto repugnante de complexidade desordenada e confusa.

O Código revela plenamente a sua filiação ao Iluminismo. O Príncipe, indivíduo modelo, modelo do novo sujeito liberto e fortificado pelo humanismo secularizador, tem condições de ler a natureza das coisas, decifrá-la e reproduzi-la em

[12] É a Luís XIV (e, por trás dele, ao seu ministro Colbert) que se devem algumas grandes *ordonnances*, a serem consideradas como uma etapa relevante no itinerário francês que levou ao Código, quando essas sistematizaram organicamente amplas zonas da vida jurídica, tais como o processo civil (1667), o direito penal (1670), o direito comercial (1673), o direito da navegação (1681).

normas que podem ser legitimamente pensadas como universais e eternas, como se fossem a tradução em regras sociais daquela harmonia geométrica que rege o mundo. Aqui se manifesta a fundamentação *jus*naturalista, que reveste de eticidade a certeza de que o Código se faz portador, já que, quando se torna possível ler a natureza das coisas, a veia ética passa a ser certa, mesmo se no fundo não existe mais o Deus-pessoa da tradição cristã, mas, no seu lugar, uma vaga divindade panteisticamente vislumbrada; desse modo, passa a ser certa a mitificação. Não é errado falar de catecismo, do Código como catecismo.

Filho do *jus*naturalismo iluminista, o Código leva consigo, bem penetrado na sua estrutura óssea, a marca da grande antítese *jus*naturalista, a mais grave e pesada antítese da história do direito moderno. Na nova cultura secularizada, a convicção na capacidade do novo sujeito de ler a natureza das coisas passa a ser acompanhada por um problema que a velha cultura medieval e pós-medieval pôde ignorar: quem possui legitimidade para ler a natureza das coisas e dessa extrair regras normativas? A nada serve o antigo leitor, único e necessário, a Igreja Romana, já condenada ao sótão das superstições e eliminada da categoria das possíveis fontes de direito. Esse leitor deve obrigatoriamente ser o Príncipe, o qual, após ter sido gratificado no âmbito da Reforma religiosa com o comando das Igrejas Nacionais, vê-se, agora, honrado e onerado, com uma nova missão inteiramente temporal.

Pressuposto desta gratificação é a sua idealização: o Príncipe é, ao contrário do juiz e do doutor, uma figura acima das paixões e das mesquinharias ligadas aos casos particulares e, por isso, tem condições de fazer uma leitura serena e objetiva. Quem não recorda, a propósito, os escritos, ao mesmo tempo contundentes e ingênuos, de Muratori ou de Beccaria[13]? Como antes fez a Reforma religiosa, também a cultura *jus*naturalista, imersa no novo mundo secularizado, precisava de um vigoroso gancho no temporal, e isso foi oferecido pelo novo sujeito político, vigoroso, já protagonista do cenário europeu transalpino, o Estado. E toma forma um fenômeno que poderia, à primeira vista, mostrar-se como uma completa antítese em relação ao que dissemos algumas linhas acima, sobre uma harmonia de geometrias eternas e universais: a estatização do direito, também do direito civil, o mais difícil a ser controlado nas malhas do poder.

O *jus*naturalismo vem a desembocar no mais agudo positivismo jurídico, e o Código, mesmo se portador de valo-

[13] Ludovico Antonio Muratori, que é lembrado sobretudo pela sua importante obra de erudito e de colecionador-editor de fontes históricas, é uma figura que interessa ao historiador do direito por uma pequena obra que publicou em 1742, entitulada "*Dei difetti della giurisprudenza*". Trata-se de um polêmico libelo contra o velho direito comum e o seu confuso pluralismo jurídico, trazendo a proposta de um novo direito tendo o Príncipe e a lei como protagonistas e que, por isso, coloca-se como testemunho genuíno do iluminismo jurídico italiano. No que diz respeito a Cesare Beccaria, faz-se referência ao seu notório libelo "*Dei delitti e delle pene*", publicado em 1764, e por todos conhecido devido as suas propostas criminalistas, mas aqui lembrado pelos seus escritos polêmicos contra um direito comum monopolizado por doutrinadores e juízes, contra um direito comum que, no século XVIII, ainda era interpretação do direito romano e do direito canônico, e a favor de um novo direito iluministicamente resumido em um complexo de leis soberanas.

res universais, é reduzido à voz do soberano nacional, à lei positiva desse ou daquele Estado.

Na França, a primeira grande codificação, a napoleônica, chega ao resultado final de um longo itinerário histórico, quando o direito já se identificou na lei, ou seja, na expressão da vontade autoritária do Príncipe; um itinerário difícil que, ainda no final do século XVI, Jean Bodin, cientista político de consistente formação jurídica, visualiza no dissídio entre *droit* e *loi*[14], entre direito e lei, ou, para melhor explicar, entre a práxis consuetudinária tradicional, compenetrada de eqüidade, e a vontade potestativa do Príncipe; um dissídio continuado feito de lutas e de resistências, mas que, lentamente, marca a progressiva vitória de uma monarquia sempre mais empenhada e satisfeita na sua dimensão legislativa. O direito francês – para usar uma expressão do léxico de Bodin – é, com o passar do tempo, sempre mais *loi* e sempre menos *droit*.

A idéia de Código, tendo sido deposta a sua projeção original e natural voltada a uma ordem universal, mortifica-se espiritualmente e potencia-se efetivamente, expressando a ordem jurídica de um Estado delimitado em termos temporais e espaciais. O Código insere-se plenamente no paroxismo legislativo que escorre nas veias do século XVIII e que se manifesta plenamente nas insistentes proclamações das declarações constitucionais revolucionárias e pós-revolucioná-

[14] BODIN, J. *Les six livres de la République*. Aalen: Scientia, 1977, livro I, cap. VIII.

rias: em que, mal se retira o maximalismo retórico, emerge com toda a sua rudeza uma fria e lúcida estratégia política[15].

A idealização do Príncipe provoca a necessária idealização da sua vontade soberana e, conseqüentemente, a cristalização normativa na lei. Aquela que é simplesmente a voz do poder recebe um lugar seguro no mais secreto sacrário da consciência laica. Delineia-se já uma escrupulosa mística da lei.

Essa é a única fonte capaz de expressar a vontade geral e é graças a uma qualidade desse tipo que o seu primado impõe-se, que o sistema das fontes fecha-se em uma ordem hierárquica com a inevitável desvitalização de qualquer outra produção jurídica. O velho pluralismo jurídico, que tinha nos seus ombros mais de dois mil anos de vida, mesmo com várias vicissitudes, passa a ser estrangulado em um rígido monismo.

E desenha-se mais claramente a intimíssima ligação entre doutrina dos poderes e produção jurídica, com a atribuição dessa última somente ao poder legislativo. A divisão dos poderes, ao lado do seu valor garantista, tem, para o historiador do direito, a função de fundamentar o monopólio jurídico nas mãos do legislador, já nesse momento identificado no detentor da soberania. O círculo fecha-se e o grande projeto

[15] Para se dar conta desse fato, basta ler as várias "Declarações", começando pela adotada em 26 de agosto de 1789 pela Assembléia Nacional Constituinte. A enunciação mais transparente encontra-se no "Ato Constitucional" de 24 de junho de 1793, no artigo 4: "a lei é a expressão livre e solene da vontade geral; a mesma é para todos, seja que proteja, seja que puna; pode ordenar somente o que é justo e útil à sociedade; pode impedir somente o que é nocivo".

*jus*naturalista revela a sua latente dimensão estratégica, ou seja, de sagaz estratégia da classe burguesa no momento de conquistar o poder político.

O problema das fontes, do sistema das fontes – de todas as fontes –, é sentido pela cultura jurídica burguesa como problema intimamente, genuinamente, constitucional, no coração da constituição do novo Estado; ou seja, não somente no heróico momento da conquista ou próximo a essa, mas também em tempos bastantes distantes, com uma continuidade inerte que tem muito a dizer. Vem em mente os escritos dos civilistas italianos do início do século XX, que recentemente reli para uma pesquisa[16], os quais estariam inclinados a reconhecer doutrina e jurisprudência como fontes de direito, mas o negam categoricamente por motivos de índole exclusivamente constitucional: tal fato teria constituído uma lesão à coluna que sustenta todo o Estado de direito burguês, ou seja, o princípio de divisão dos poderes.

2. O Código e os elementos que historicamente o caracterizam

Chegamos, desse modo, aos elementos que caracterizam o Código, sobre os quais se discutiu em uma vivaz dialética de posições, nas mais variadas relações.

---

[16] GROSSI, P. *Itinerarii dell'assolutismo giuridico – saldezze e incrinature nella 'parti generali' di Chironi, Coviello e Ferrara*, in *Assolutismo giuridico e diritto privato*. Milano: Giuffrè, 1998.

Uma tipicidade inconfundível, em relação a todas as outras fontes jurídicas que se manifestaram ao longo da história, é-lhe impressa por uma tríplice tensão que o percorre; efetivamente, tende a ser fonte unitária, espelho e fundamento da unidade de um ente estatal; tende a ser uma fonte completa; tende a ser uma fonte exclusiva. Esta tríplice tensão caracteriza fortemente o Código, ao menos no seu modelo originário, que nos foi proposto na realização francesa do início do século XIX.

Disse tensão porque, sem dúvida, é uma aspiração desse tipo. De fato, não esqueçamos nunca de conceber o Código – a idéia de Código – como o fruto extremo do comportamento geral de mística legislativa, de inseri-lo naquele quadro de monismo jurídico que identifica a lei acima de qualquer outra fonte de direito, no topo de uma rigidíssima hierarquia, com a conseqüente condenação das posições hierarquicamente inferiores a um *status* decididamente servil. Também não podemos esquecer a maquinação de um Código: pretende realizar a redução de toda a experiência em um sistema articuladíssimo e minuciosíssimo de regras escritas, contemplando todos os institutos possíveis, começando muito freqüentemente pelo dar a esses uma definição e disciplinando com uma precisão estudada todas as aplicações previstas pelos redatores.

Também acredito que não devamos nos deixar desviar pelos propósitos que, por vezes, floresciam nos preparativos, como quando Portalis apela para a eqüidade, ou seja, a um

dos valores que caracterizavam o Antigo Regime[17]. Os novos "legisladores" ainda levam sobre a pele os sinais da própria velhice, ou seja, de figuras educadas na época pré-revolucionária. O que conta é o clima histórico, a ideologia política e a cultura jurídica dominantes, das quais o Código é tradução em nível normativo e que o fazem ser instrumento de um rigoroso absolutismo jurídico. Não podemos nos deixar desviar pela consideração se, sob o conteúdo vago e ambíguo do notório artigo 4, obrigando o juiz a decidir a qualquer custo a controvérsia submetida a ele pelas partes, exista uma vontade de abertura além da lei por parte dos redatores, quando, imediatamente e com duradoura fortuna, dá-se uma interpretação positivista e legolátrica dessa, coerente com a imperante mística legislativa. No seu complexo, o Código é uma operação ideológica e cultural notavelmente compacta, e bastaria, para confirmar o seu relevo – já por nós realizado – acerca do território do qual toma início a operação, o direito civil plasmado por costumes seculares e a esse reservado.

Convencidos dessa densidade, torna-se impossível não salientar algumas fissuras na solidíssima muralha. A primeira que vem em mente é oferecida pelo parágrafo 7 do ABGB, o Código Austríaco, que tem como hipótese, como meio extremo para preencher as lacunas legislativas, o recurso aos

[17] Sobretudo no complexo *Discours préliminaire*, riquíssimo de velhos e novos motivos, pronunciado por Portalis quando apresenta ao Conselho de Estado o projeto de Código Civil redigido pela Comissão do governo (atualmente pode ser lido na coletânea: *Naissance du Code civil – la raison du législateur*. Paris: Flammarion, 1989)

"princípios do direito natural, respeitando as circunstâncias analisadas com diligência e maduramente ponderadas"[18] com uma dição que indica abertamente, ao mesmo tempo, as influências paralelas – enormes sobre aquele legislador – do robusto *jus*naturalismo alemão e do também robusto direito comum revivido na Idade Moderna da área germânica. Mas atrás do Código falta o embaraçante Estado-nação e falta a corrosiva incidência revolucionária que os franceses experimentaram na própria pele. Bastaria analisar como o ABGB coloca-se (e resolve) o problema da propriedade e dos direitos reais para se dar conta de que estamos em um planeta jurídico muito distante do francês, um planeta ainda intimamente ligado à estrutura feudal e às decrépitas invenções do domínio dividido, assim como foram teorizadas e sistematizadas pelos intérpretes medievais.

Passando aos Códigos da área italiana que surgiram ao longo do século XIX, não gostaria de supervalorizar as poucas referências ao direito comum, salientadas por Pio Caroni; efetivamente, essas podem ser observadas ou em zonas bastante separadas (como o Cantão Ticino), ou em zonas onde ainda perdura, em pleno século XIX, a vigência geral do mesmo direito comum (como acontece no Estado Pontifício).

---

[18] Trata-se da parte final do parágrafo 7 do "Código Civil geral austríaco" (*Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch*) de 1811. O texto completo do parágrafo recita: "Quando não seja possível decidir um caso nem segundo as palavras, nem segundo o sentido natural da lei, deverão ser respeitados os casos similares especificamente decididos pelas leis e os motivos de outras leis análogas. Permanecendo duvidoso o caso, deverá ser decidido segundo os princípios do direito natural, respeitando as circunstâncias analisadas com diligência e ponderadas com maturidade".

É mais encorpado, ao contrário, o apelo aos "princípios gerais do direito" – feito expressamente no artigo 3 das disposições preliminares do primeiro Código civil da Itália unificada, de 1865[19] – como último subsídio oferecido ao aplicador para preencher as lacunas normativas; porém, com o ulterior e significativo esclarecimento que a dição – por verdade, genérica – será sempre e constantemente entendida como uma redução do próprio espectro aos princípios gerais dedutíveis do direito positivo estatal italiano. Existirá – durante o longo império do Código de 1865 – quem o interpretará com um conteúdo de genuíno direito natural, mas será muito mais tarde, e será um filósofo do direito, Giorgio del Vecchio, na conferência que esse proferiu em Roma em 1921[20], dando livre curso a um debate aceso e fecundo, que torna viva e enriquece a reflexão jurídica italiana no início da década de vinte.

Aquilo que estou delineando é o modelo de Código assim como esse veio a se desenhar, com traços nítidos na França, nos primeiros anos do século XIX. Com o passar do tempo também passa muita água sob as pontes do Senna, do Tevere, do Reno; e essa não passa em vão. A história sempre traz consigo riqueza e transformação incessante. No final do sé-

---

[19] Código Civil de 1865, artigo 3: "Quando uma controvérsia não possa ser decidida com uma específica disposição de lei, deverão ser respeitadas as disposições que regulamentam casos similares ou matérias análogas: onde o caso permaneça duvidoso, deverá ser decidido segundo os princípios gerais de direito".

[20] DEL VECCHIO, G. *Sui principi generali del diritto*, atualmente em *Studi sul diritto*. Volume I. Milano: Giuffrè, 1958.

culo, já em um Código que reflete a conclusão do positivismo legalista da Pandetística[21], o Código Imperial Germânico, o BGB, existe um fervilhar de cláusulas gerais[22], de brechas abertas para o juiz através do mundo dos fatos, um tema – esse – caro a Stefano Rodotà, que o desenvolveu, há muitos anos, em uma esplêndida conferência proferida na cidade de Macerata[23]. E, no início do século XX, o Código suíço, marcado pelas convicções germanistas de Huber, surge imerso em uma realidade consuetudinária que merece ser valorizada, com um juiz que possui maior liberdade, podendo abrir as janelas do seu *métier* para absorver as mensagens sociais[24]. Poderia-se, até mesmo, mencionar o primeiro Código de direito canônico de 1917, único Código – de que eu saiba – expressamente aberto, com o can. 6, em direção ao passa-

---

[21] Com o termo "Pandetística" nos referimos sobretudo à grande corrente científica que, tendo por base as Pandetas de Justiniano, edifica na Alemanha do século XIX um saber jurídico extremamente conceitualizado, fundamentado sobre modelos abstratos e purificado das escorias factuais de índole econômica e social. Na falta de uma codificação na Alemanha durante todo o século XIX, a Pandetística constrói robustamente no plano teórico, mas permanece dominada por um forte positivismo legalista.

[22] Com a expressão "cláusulas gerais" pretende-se salientar as referências que o legislador faz a noções pertencentes à consciência coletiva (boa-fé, bom costume, usos comuns, diligência do bom pai de família, e, assim por diante) indicando ao juiz um reservatório *extra legem* a ser alcançado pela sua decisão.

[23] RODOTÀ, S. *Ideologie e tecniche della riforma del diritto civile*, in *Rivista del diritto commerciale*, 1967, I.

[24] Nos referimos ao "Código Civil suíço" (citado como ZGB) de 1907, mais do que a qualquer outro, um verdadeiro Código de autor, por ter sido fruto da engenhosidade de somente um notável personagem, o jurista Eugen Huber (1849-1922), um doutrinador especializado em direito privado e inspirado na cultura jurídica germanista. Os traços que caracterizam esse Código são a valorização da consciência jurídica popular e, conseqüentemente, a valorização do papel do costume e do juiz. É também, por isso, que no Código faz-se grande uso de "cláusulas gerais".

do, através do princípio constitucional não escrito da eqüidade canônica, com a possibilidade, para o juiz – sob determinadas condições –, de não aplicar a norma escrita[25]; mas aqui é fácil salientar que se trata de uma codificação peculiaríssima, relativa a um ordenamento sacro com imperiosas instâncias pastorais absolutamente ignoradas pelos ordenamentos laicos.

As matrizes *jus*naturalistas pesam sobre o Código. Como norma que presume prender a complexidade do social em um sistema fechado, o Código, toda codificação, somente pode traduzir-se em uma operação drasticamente redutiva: se a razão civil pode e deve desenhar-se em uma harmonia geométrica, sob a égide da máxima simplicidade e da máxima clareza, o legislador deve empenhar-se em um esforço de depuração e decantação.

Como norma que, rejeitando as escórias deformantes da historicidade, pretende redescobrir o indivíduo originário em toda a sua genuína privacidade, o Código tem por protagonistas sujeitos abstratos aos quais se refere uma faixa de relações igualmente abstratas. São os modelos desenhados sobre pegadas pré-históricas, modelos todos iguais, sem aquela pesada bagagem de carnalidade humana que a história inevi-

[25] O can. 6 valoriza o grande patrimônio jurídico que se acumulou na bimilenária vida da Igreja Romana e que entre os canonistas vem denominado *ius vetus*. Quanto à eqüidade canônica, ou seja, ao espaço de discricionariedade concedido ao juiz para evitar aplicações rigorosas da lei que pudessem ser motivo de pecado para os que julgam, essa, chamada expressamente pelo can. 20 do Código de 1917, deve todavia ser considerada como um princípio constitucional não escrito que permeia toda a codificação.

tavelmente põe sobre os ombros de quem age no seu seio. A carnalidade, no bem e no mal, era própria do Antigo Regime, onde haviam nobres e plebeus, camponeses e mercadores, ricos e pobres, cada um pensado no interior de uma comunidade historicamente definida, cada um desigual em relação ao outro graças a sua inabdicável historicidade.

No projeto jurídico burguês, abstração e igualdade jurídica (ou seja, a possibilidade de igualdade de fato) são noções "constitucionais" que fundamentam o mesmo projeto. E a muralha chinesa que separa o mundo do direito (e da relevância jurídica) do mundo dos fatos é compactíssima, impenetrável. Tão compacta e impenetrável como talvez nunca se tenha realizado na história jurídica ocidental. Sinal de que o projeto se misturava também com estratégia, com a exigência de um controle rigoroso no ingresso dos fatos na cidadela do direito.

A factualidade começará a ser discutida na Itália – após muitas dificuldades – no final do século XIX por civilistas hereges e se contraporá, então, à fria harmonia de museu que caracterizava o Código Civil, um "Código privado social" em que os sujeitos são patrões e empregados, ricos e pobres, sábios e ignorantes[26]; em suma, homens de carne e osso; e também começará a ser discutida, sempre no final do século XIX, na legislação especial – antes muito escassa – que logo se intensificará com o objetivo de remediar as muitas necessi-

[26] Tal fenômeno acontecerá na Itália, no final do século XIX, no âmbito da corrente ambígua e heterogênea de índole tipicamente solidarista que chamamos de "socialismo jurídico".

dades emergentes[27], e, finalmente, na legislação especial e excepcional surgida com a Primeira Guerra Mundial[28], que se transforma em uma corda no pescoço para o organismo rarefeito dos sujeitos e das relações do direito burguês.

Abstração e igualdade formal foram, talvez, as armas mais afiadas da grande batalha burguesa, armas só aparentemente desinteressadas, só aparentemente em benefício e para a proteção de todos. Aos meus alunos da disciplina de História do direito moderno, nunca deixo de ler uma frase retirada do magnífico romance "*Le lys rouge*", de Anatole France, uma frase que acumula em si um diagnóstico historiograficamente agudíssimo; o grande romancista assinala com pungente sarcasmo "*la majesteuse égalité des lois, qui interdit au riche comme au pauvre de coucher sous le ponts, de mendier dans les rues et de voler du pain*"[29]; e conclui, mal conseguindo esconder a zombaria: "*elle éleva, sous le nom d'égalité, l'empire de la richesse*"[30].

Esse discurso sobre a abstração como princípio estratégico me permite realizar alguns comentários sobre o que Paolo Cappellini dizia acerca da incomunicabilidade do Código.

---

[27] Nos referirmos, em modo particular, às primeiras leis sociais, que atenuam o surdo individualismo jurídico da legislação burguesa, começando a introduzir elementos de solidariedade e tutela dos sujeitos economicamente mais frágeis.

[28] Trata-se da densa e complexa obra do legislador italiano que salienta, de um modo até então desconhecido, por trás das urgências dos problemas bélicos, a dimensão socioeconômica com uma forte contribuição que vem a romper ou a subverter princípios inveterados, até então recebidos como autênticos dogmas.

[29] "a majestosa igualdade das leis, que proíbe ao rico assim como ao pobre de dormir debaixo das pontes, de mendigar nas ruas e de roubar o pão" (nota do tradutor).

[30] "ela eleva, sob o nome da igualdade, o império da riqueza"(nota do tradutor). In: *Le lys rouge*, cp. VIII.

É verdade, o Código sofre de incomunicabilidade ou, ainda, de grandes dificuldades ao comunicar si mesmo à generalidade. Isso por um motivo fundamental: o Código, como resultado de uma monopolização da produção jurídica por parte do poder político, é o instrumento de um Estado monoclasse (uso constantemente essa expressão felizmente cunhada por Massimo Severo Giannini, um importante pensador italiano do direito público falecido no início do ano 2000); é o instrumento de um Estado centralizador que se expressa em uma língua nacional, culta, literária, que tenta se manter o mais distante possível de todo o tipo de localismos vernáculos, os únicos verdadeiramente agradáveis e compreensíveis à massa popular.

Se o Código fala a alguém, esse alguém é a burguesia que fez a Revolução e que finalmente realizou a sua plurissecular aspiração à propriedade livre da terra e à sua livre circulação; o Código francês é tomado por uma realização desse tipo, a ser desenhada, ainda, em 1804, ou seja, um protagonismo da terra – sobretudo da terra rural – como objeto possível de propriedade, que era substancialmente desmentido por uma situação econômica em plena evolução, valorizando cada vez mais decididamente outras fontes de riqueza; não estava errado Pellegrino Rossi, que, daí há pouco, teria salientado o atraso da consciência econômica dos codificadores napoleônicos[31].

[31] Nos referimos às notas *Observations sur le droit civil français consideré dans ses rapports avec l'état économique de la societé*, in *Mélanges d'économie politique, de politique, d'histoire et de philosophie*. Tomo II. Paris: Guillaumin, 1867.

O Código fala ao coração dos proprietários, é sobretudo a lei tuteladora e tranqüilizadora da classe dos proprietários, de um pequeno mundo dominado pelo "ter" e que sonha em investir as próprias poupanças em aquisições fundiárias (ou seja, o pequeno mundo da grande *comédie* balzaquiana). É por isso que, ao lado da lei do Estado, única concessão pluralista, mas, ao contrário, bem fechada no interior de um surdo monismo ideológico, é admitida como única lei concorrente o instrumento príncipe da autonomia dos indivíduos, ou seja, o contrato[32]. É por isso que o Código – mais do que aos utentes, entendidos sempre como destinatários passivos – fala aos juízes, ou seja, aos efetivos aplicadores nas quais mãos passa a ser entregue a *tranquillitas ordinis*.

Mesmo existindo a hipótese de uma lei dos indivíduos a ele paralela, o Código permanece inserido em uma dimensão autoritária. Recentemente foi medida a respeitabilidade da fonte "Código" em referência aos conteúdos[33], mas o substancial autoritarismo está em outro lugar, na exigência centralizadora do Estado monoclasse, no seu conseqüente panlegalismo, na mitificação do legislador que surge quase como um Zeus fulminante do Olimpo, onisciente e onipotente, na mitificação do momento de produção do direito como momento de revelação da vontade do legislador. E é um

[32] É eloqüente o artigo 1123 do Código Civil italiano de 1865 (reproduzindo um idêntico ditado contido no Código Civil napoleônico): "Os contratos legalmente formados têm força de lei para todos os que dele participam".

[33] ZENCOVICH, V. Z. *Il 'codice civile europeo', le tradizioni giuridiche nazionali e il neopositivismo*, in *Foro Italiano*, 1998, V, 60 ss.

autoritarismo que intensifica a incomunicabilidade entre Código e sociedade civil, já que, a respeito das incessantes transformações socioeconômicas, o Código inevitavelmente permanece um pedaço de papel cada vez mais velho e cada vez mais alienado.

Venho a um outro ponto fundamental sobre o qual pesam as raízes *jus*naturalistas do Código, o ponto que há pouco indicávamos. A legolatria iluminista imobiliza o direito no momento da produção; tal procedimento chega à exaustão com a revelação (deve-se insistir com esse termo teológico) de uma vontade suprema, sendo que o momento de interpretação e aplicação permanece estranho a esse. Talvez se tenha falado muito pouco disso no nosso congresso, como salientou Luigi Lombardi Vallauri.

O procedimento de normatização conclui-se no momento em que a norma vem produzida; conclui-se e extingue-se. O resto conta pouco, porque a norma jurídica é aquela abstratamente confeccionada pelo legislador. É certo que em seguida acontece o momento da sua aplicação, ou seja, da vida da norma em contato com a vida dos utentes, mas sem dar nenhuma contribuição a uma realidade que nasce e permanece compacta e rígida, impermeável à história.

Essa mentalidade é tipicamente iluminista, e não somente peculiar aos entusiasmados homens do século XIX, tão impregnados do positivismo jurídico; caiu – o confessamos – nas profundezas da alma do jurista europeu continental e, mesmo com tudo o que aconteceu na experiência e cientifi-

camente ao longo do fertilíssimo século XX, ali permanece, intacta, seguramente revestindo o subconsciente, mas encontrando também um pleno aceite por parte da sua consciência opaca. Perdura, intacta, a atitude de ácida hostilidade em relação à interpretação – toda interpretação que não seja a autêntica – muito bem expressa por Cesare Beccaria em memoráveis escritos da literatura jurídica italiana[34].

Mas Beccaria está ali, no seu nicho do século XVIII, eficaz ao expressá-lo e, portanto, merecendo a nossa compreensão historiográfica. Merece uma compreensão menor a rejeição da historicidade da norma, de toda norma, mesmo da legislativa, no incontrastado domínio que tem sobre a alma dos juristas.

A idéia de Código, ou seja, de uma geometria de regras abstratas, simples, lineares, conceitualmente não concebe a possibilidade de uma incidência do momento de aplicação. A ideologia jurídica pós-iluminista fica profundamente perturbada com a visão de uma norma que vive além da sua produção e elasticamente modifica-se, segundo o seu percurso, que continuamente se reproduz recebendo as mensagens dos diferentes terrenos históricos por onde passa. É por isso que, nessa, a interpretação assume a única veste que lhe é possível, de exegese: a norma deve ser somente explicada, no máximo penetrando no interior do cérebro do Zeus legisla-

[34] BECCARIA, C. *Dei delitti e delle pene* (1764), cap. IV – *Interpretazione delle leggi*. Milano: Giuffrè, 1964.

dor (procedimento desdenhosamente rejeitado pelo ortodoxo Beccaria) para adentrar e esclarecer a sua soberana intenção. Rejeita a historicidade da lei porque essa infligiria uma lesão mortal à estratégia que se conclui no projeto iluminista.

Se consideramos os filões mais inovadores – e também mais fecundos – do nosso século XX, pode-se observar que esse difícil itinerário (ainda hoje não concluído) está buscando uma valorização cada vez maior do momento de interpretação, da sua recuperação no interior do procedimento de produção da norma como momento essencial desse mesmo procedimento, o único que pode fazer da norma abstrata uma regra de existência cotidiana.

A experiência do século XIX francês deveria ser uma advertência. A ciência reduz-se a exegese[35], uma corte de laboriosíssimos e fecundíssimos operadores que trabalhavam satisfeitos na sombra da codificação. O colega Rémy, de um modo brilhante, teceu um elogio[36] a eles, e é seguramente digna de consideração a inteligência esclarecida e documentada deles, manifestada em comentários limpidíssimos. Porém, eu não poderia assinar o mesmo elogio: porque entre eles dominava uma psicologia substancialmente passiva em relação ao texto normativo, uma concepção que minimiza o

[35] E não sem razão foi chamada "escola da exegese" a rica corte de interprétes franceses que, em boa parte do século XIX, trabalhou na sombra da codificação napoleônica. Certamente esses não constituíam uma "escola" unitária, mas, em uma avaliação unitária, podem muito bem serem associados devido a um comportamento psicológico e metodológico comum entre eles.

[36] REMY, J.P. *Eloge de l'exegése* (1982), atualmente em Droits-Revue française de théorie juridique, I, 1985.

direito, reduzindo-o a um texto respeitável, uma incapacidade de responder e corresponder às incumbentes exigências de uma sociedade marcada por um forte crescimento e precisando ser ordenada com categorias e escolhas técnicas corajosas e inovadoras.

Uma jurisprudência prática tem consciência desse objetivo e trabalha nessa direção, investida pela fricção entre lei velha e novas necessidades, tomando para si essa tarefa enorme, não a evita e, mesmo sofrendo uma verdadeira crucificação no abismo entre surdez de um texto e transformação dos fatos sociais, freqüentemente faz as suas escolhas parando no respeito formal a um texto que foi efetivamente esvaziado ou violado por essa transformação; uma jurisprudência prática que quis e soube construir *"au delà du code"* e *"malgré le code"*, trabalhando *"avec les textes"*, mas chegando *"au dessus des textes et par delà les textes"* [37] [38]. Pode ser extremamente instrutivo ler os "anais" das celebrações centenárias acontecidas em 1904: junto a tantos escritos triunfalistas, chamam a atenção outros, como, por exemplo, os do Presidente da Corte de Cassação, Ballot-Beauprè[39], em que o elogio à codificação consiste no fato de essa ser vaga e genérica, no fato de ser portadora de muitas lacunas, circunstâncias que

[37] "além do código"; "apesar do código"; "com os textos"; "acima dos textos e além dos textos" (nota do tradutor).

[38] A proposta metodológica e a linha de ação que constituíram o fulcro da mensagem de Raymond Saleilles, como acreditamos ter salientado no ensaio citado, podem ser encontradas na nota 40.

[39] Nos referimos ao discurso pronunciado em 29 de outubro de 1904, nas festividades do centenário da promulgação do Código.

por si mesmas não são edificantes, mas permitem aos juízes franceses construir apesar do texto.

Isso, devido ao fato de o Código ter se tornado um texto, um texto em um pedaço de papel. Nesse contexto não posso deixar de citar dois grandes civilistas franceses que tive a sorte de poder estudar profundamente[40]: Raymond Saleilles e François Gény. Estamos nos últimos vinte anos do século XIX; eles são o testemunho do que há pouco eu disse ser a crucificação de um jurista socialmente sensível e culturalmente consciente; Gény e Saleilles, intolerantes com um direito identificado e cristalizado em um texto, orientam as suas reflexões tentando evitar a separação funesta entre a cortiça jurídica e a subjacente linfa social e econômica, uma linfa que, por natureza, é mutabilíssima.

Entre nós, na Itália, deve-se obrigatoriamente recordar a figura de Tullio Ascarelli, apaixonado por um ramo do direito privado imerso na prática econômica, como é o direito comercial, e que tentou, no convulsionado momento que tivemos imediatamente após a Segunda Guerra Mundial, harmonizar formas e práxis *inventando* categorias de interpretação sob a égide de um diagnóstico despudorado do direito vivo[41].

---

[40] *Ripensare Gény*, e *Assolutismo giuridico e diritto privato: lungo l'itinerario scientifico di Raymond Saleilles*, atualmente em *Assolutismo giuridico e diritto privato*, *op. cit.*

[41] São exemplos, entre tantos ensaios ascarellianos: *Funzioni economiche e istituti giuridici nella tecnica dell'interpretazione* (1946), atualmente em *Saggi giuridici*. Milano: Giuffrè, 1949.

3. O Código hoje: algumas considerações do historiador do direito

Falou-se, nesse congresso, do passado, mas também do presente, assim como não faltaram olhares para o futuro. O historiador sente-se "em casa" no sulco dessa longa linha que chega ao "hoje" e o ultrapassa, e tem, provavelmente, algo fundamentado a dizer.

Atualmente ainda se fala de Códigos e de codificações: somente há pouco tempo pode-se ter o único modelo ideologicamente coerente de Código civil realizado em um Estado de regime comunista, o da República Democrática Alemã, que hoje interessa somente ao historiador do direito, mas que representa uma experiência cultural e tecnicamente de relevo[42]; e hoje refloresce – sendo objeto de excessivas e algumas vezes vazias discussões – o projeto de um "Código comum europeu de direito privado"[43].

A esse ponto, torna-se legítima uma pergunta: a idéia de Código ainda é atual? Ou se trata, mesmo nesse caso, da maldição misoneísta dos juristas sempre apegados a modelos passados e sempre tardios e avessos a superá-los?

Neste contexto, impõem-se algumas considerações.

A primeira concerne à rapidez da transformação social na civilização moderna. A transformação de ontem era extrema-

---

[42] A rica introdução premissa a: *Il Codice civile della Repubblica Democratica Tedesca*, trad. e introd. De G. Crespi Reghizzi e G. De Nova. Milano: Giuffrè, 1976.

[43] Pode-se ler, a respeito BUSSANI, M. et MATTEI, U. (Ed.) *Making European Law – Essays on the "Common Core" Project*. Trento: Università degli Studi, 2000.

mente lenta e podia prestar-se, também, a ser ordenada em categorias não elásticas, enquanto hoje a mesma rapidez freqüentemente obriga o legislador a uma atividade febril, modificando o conteúdo de uma norma logo após tê-la produzido. Penso em nós, na Itália (e o digo somente para os amigos não italianos), ao recentíssimo Código de processo penal, um Código que eu – secamente, mas não inconseqüentemente – tomo a liberdade de qualificar como "redigido em versos", um texto abstratamente respeitadíssimo, mas inadequado para ordenar uma práxis criminal que se encontra em um tumultuado e alarmante crescimento, que foi apresentado não sei quantas vezes apesar do breve período de vigência.

A segunda concerne à complexidade da civilização contemporânea. Se é verdade que a codificação inaugurada em 1804 foi uma tentativa de redução da complexidade, é também verdade que se tratava de uma complexidade reduzível (mesmo se, no final, a tentativa não chegou perfeitamente ao seu objetivo e o Código acabou por nascer "velho"). Hoje, a situação é inacreditavelmente diferente, com fronteiras das dimensões econômicas e tecnológicas que continuamente alargam-se, modificam-se, complicam-se. Os pontos salientados por Rodotà no que diz respeito à evolução tecnológica confirmam que a atual complexidade dificilmente pode ser reduzível.

A terceira consideração concerne à tensão voltada à universalização (intencionalmente, omito-me de pronunciar o termo correntíssimo de globalização, que evoca demasiadamente o desagradável espectro do imperialismo econô-

mico norte-americano e das suas vorazes multinacionais). Não existem dúvidas quanto ao fato de o panorama geral ter variado muito em relação à velha paisagem estatal e inter-estatal[44], colocando em dificuldade o Código que, mesmo se atulhado de instâncias originárias e veias *jus*naturalistas, historicamente se tornou lei nacional e nela se identificou.

Enfim, uma última consideração, sobre o que, talvez, tivéssemos que refletir mais profundamente. Falou-se de Código-Constituição. *Verissimo*! De fato, não existe dúvida que, quando nasceu, o Código encarnou a autêntica Constituição do Estado burguês, já que, tendo as primeiras "cartas dos direitos" se revestido de um caráter filosófico-político, coube ao Código civil enunciar regras jurídicas que disciplinassem os institutos fortemente "constitucionais" da propriedade individual e do contrato. Na longa estrada percorrida após 1804, o Código viu multiplicarem-se os níveis de legalidade, primeiro – no século XIX – a legislação especial ou excepcional do legislador ordinário, que, porém, limitava-se a responder questões contingentes que o Código abstrato não tinha conseguido responder, após – no século XX – as Constituições, que a essa altura já tinham se tornado verdadeiras ordens normativas, mas, ao mesmo tempo, ordens concretíssimas onde podia ser enxertado de modo imediato e des-

[44] "Em termos de fragmentação e opacização da soberania, em termos de modificados atores e protagonistas do processo jurídico, assim como em termos de diferentes modalidades de produção e funcionamento das regras jurídicas", como nobremente indica uma inteligente socióloga do direito em uma obra recente, que recomendo aos juristas (FERRARESE, M. R. *Op. cit.*, p. 7).

coberto o mundo dos valores, fazendo com que essas se tornassem portadoras de um harmonioso sistema de valores. E justamente – mesmo se bastante atrasada – a doutrina civilista italiana colocou-se o problema da relação entre o que já tinha tornado-se dois níveis de legalidade, a legalidade constitucional e a legalidade do Código[45].

Impõe-se uma resposta para a pergunta que acima formulamos: a idéia de Código é atual? Nesse caso, qual papel podemos dar hoje para o futuro do Código?

Não é tarefa do historiador fazer propostas operativas; porém, o historiador pode utilizar a sua consciência tendo o sentido da linha histórica para incentivar o espírito crítico do observador e projetador do presente. Há pouco tempo Salvatore Tondo, a propósito da *lex mercatoria*, invocada muitas vezes nesse nosso tríduo *fiorentino*, salientava a sua fé na capacidade de o Código ordenar convenientemente essa realidade emergente. Eu teria mais dúvidas a respeito. Perguntamo-nos, retoricamente, tendo por objetivo somente esclarecer melhor o discurso, o que entendemos quando fazemos uso de um sintagma desse tipo. Simplificando e reduzindo ao máximo, são as invenções da práxis que em um novo cenário econômico e tecnológico precisam sempre de instrumentos novos; *lex mercatoria* é o conjunto das invenções realizadas com criatividade e bom senso pelos homens de negócios nas praças mercantis, nos portos, nos mercados financeiros.

---

[45] Uma obra exemplar a respeito é: PERLINGIERI, P. *Il diritto nella legalità costituzionale*. Napoli: ESI, 1984.

Os glosadores falavam, no século XII, dos *nova negotia*, embaraçadíssimos sobre como poder inserir nos esquemas ordenantes do *Corpus iuris* justiniano todos esses casos que, naquele momento, eram "zero-quilômetro" – como, por exemplo, todos os casos comerciais e de navegação – fervilhantes e invasivos na grande *koiné* mediterrânea. Mas eles estavam convictos – mesmo tendo de forçar e superar as categorias clássicas – de que deveriam apropriar-se dessa riqueza consuetudinária que a potente classe mercantil solicitava e apoiava[46]. Estamos em uma situação muito semelhante a deles: uma práxis que continuamente forma institutos novos e continuamente os supera, massacrando-os ou criando novos, em uma corrida caracterizada por uma extrema rapidez.

Para essas criaturas elásticas e mutáveis, a codificação corre o risco de tornar-se um revestimento rígido demais, com o ulterior risco de um envelhecimento precoce do texto normativo e de uma práxis que continua a galopar seguindo os fatos, prescindindo das inadequadas regras autoritárias.

Atualmente, perante uma transformação rápida e uma complexidade pouco dócil, resta ao Código, na minha opinião, a possibilidade de se oferecer como uma espécie de grande moldura. Rodotà nos falava de um Código dos princípios[47]. Provavelmente eu e ele não estamos muito distantes um

---

[46] GROSSI, P. *L'ordine giuridico medievale*. Bari: Laterza, 1995.

[47] Uma rica resenha dos recentíssimos problemas florescidos em nível europeu pode ser encontrada em: ALPA, G. *Il codice civile europeo: 'e pluribus unum'* in *Contratto e impresa/Europa*, 1999.

do outro. Acredito que o legislador pretendeu realizar uma ingerência excessiva no mundo moderno através de uma arrogante monopolização do fenômeno jurídico; infelizmente, fazendo isso, também demonstrou o quanto é impotente.

O amigo Schiavone foi prudente ao convidar para a inauguração do nosso Congresso o respeitabilíssimo Presidente da Câmara dos Deputados da República Italiana, Luciano Violante (que, por profissão, também é um jurista), e foi eloqüente a confissão que esse fez, sobre a lentidão do legislador italiano e sobre a incapacidade deste para corresponder às solicitações de uma sociedade civil extremamente complexa, hoje também extremamente complexa no que se refere ao crescimento rápido da sua organização tecnológica. Violante falou pudicamente de lentidão, eu, com mais brutalidade, mas não sem motivos, prefiro falar de impotência.

Acredito ser necessário, perante essa realidade alarmante, repensar o sistema formal das fontes, também para torná-lo mais consoante ao projeto e ao desenho da nossa carta constitucional; e repensar principalmente o papel da lei, que, me parece, possa ser o de fornecer algumas molduras relevantes para o desenvolvimento da vida jurídica.

É claro que o Estado não pode abdicar da fixação de linhas fundamentais, mas também é claro que se impõe uma deslegificação, abandonando a desconfiança iluminista do social e realizando um autêntico pluralismo jurídico, onde os indivíduos sejam os protagonistas ativos da organização jurídica do mesmo modo que acontece nas transformações so-

ciais. Somente dessa forma será possível preencher o fosso que atualmente constatamos com amargura.

Retornando ao nosso tema dos Códigos e, concluindo essas considerações finais, também é claro que os Códigos que construiremos seguindo uma linha operativa desse tipo não terão e nem poderão ter o valor do *Code civil* e dos grandes Códigos do século XIX, vozes constitucionais do Estado monopolizador, fontes de fontes por serem emanação da única potestade nomopoiética, o Parlamento; fontes que formalmente condicionam todos os órgãos aplicadores na ingênua pretensão de oferecer um sistema normativo tendencialmente exaustivo.

Uma dupla descontinuidade delineia-se perante os nossos olhos. Não existe somente a história descontínua que liga esses Códigos com o Antigo Regime. Uma outra descontinuidade delineia-se: a que se encontra entre os Códigos do imediato futuro e a idéia de Código, assim como essa se afirmou no sulco das eficazes sugestões iluministas.

IV
AS MUITAS VIDAS DO JACOBINISMO JURÍDICO *

(ou seja: a "Carta de Nice", o Projeto de "Constituição Européia" e as satisfações de um historiador do direito)

* Publicamos aqui o texto da conferência ministrada em Rimini, em agosto de 2003, no *"Meeting per l'amicizia tra i popoli"*, por ocasião do Encontro de agosto de 2003 que tinha por tema: *Se ti distrai, l'Europa è giacobina*, no qual fomos conferencista ao lado de Joseph Weiler (da New York University) e de Augusto Barbera (da Università di Bologna).

1. O papel crítico do historiador do direito no diálogo com o estudioso do direito vigente. — 2. Um risco da modernidade: absolutização e mitificação. — 3. Um esclarecimento indispensável: significados e mensagens do jacobinismo jurídico. — 4. A "redução" jacobina da complexidade social. — 5. A "Carta de Nice" como a última "carta" de direitos. — 6. A ilusão de uma redução do direito em um pedaço de papel. — 7. E o seu característico individualismo: o indivíduo como indubitável protagonista. — 8. O indivíduo insular. — 9. O insuficiente projeto de dimensão coletiva do sujeito no tecido da "Carta": um sinal de continuidade pós-iluminista. — 10. A exigência de um resgate: contra a monopolização estatal da dimensão política; a sociedade intermediária como autenticamente política. — 11. O insuficiente projeto de dimensão social do sujeito.

1. O papel crítico do historiador do direito no diálogo com o estudioso do direito vigente

O jurista é alguém em busca de ordem, um tecelão de ordem, porque o direito é essencialmente ciência ordenadora; ele esforça-se para identificar e indicar as linhas da ordem que se encontram invisíveis, mas reais, abaixo do desordenado conflito das coisas. Só que essas coisas, para o jurista, não são os elementos da natureza cósmica, um co-acervo de cristais caracterizado por uma substancial imobilidade; são, ao contrário, os elementos da natureza social envolvidos por uma dinâmica contínua, por uma íntima historicidade.

O mal para o jurista é, muito freqüentemente, o de esquecer-se de que maneja um material riquíssimo em história e que os resultados por ele obtidos, mesmo quando válidos, são

relativos. Relativos a certos lugares, a certos tempos, a certos estágios de civilizações históricas, ou seja, devem ser fixados como passíveis de variações devido a sua elasticidade natural. O mal para o jurista é a tentação – intensa em todo ordenador – de imobilizá-los e de torná-los absolutos – uma tentação, aliás, que é quase constante no estudioso do direito positivo, avesso, no mais das vezes, a separar e a isolar o *ponto* mínimo do seu objeto de indagação, o direito vigente, da *longa* linha histórica, ventre no qual se insere e se justifica.

E é justamente aqui que se revela prudente, inserindo-se ao lado do jurista que se dedica ao direito privado e ao jurista que se dedica ao direito público, a atividade do historiador do direito, uma figura de per si relativizadora que – justamente nesta sua roupagem – tem o privilégio de servir como sua consciência crítica.

Durante os últimos anos tivemos ocasião de salientar muitas vezes[1]: o historiador do direito, inimigo de toda absolutização e enfatização, pode – com seus apelos – desempenhar um papel providencial e profícuo nesta civilização jurídica pós-moderna, ainda muito íntima das absolutizações e enfatizações que a modernidade, a despeito de todo o seu superficial disfarce de secularização e de cientificismo, foi, portadora.

---

1 GROSSI, P. *Il punto e la linea (impatto degli studi storici nella formazione del giurista)*. In: REBUFFA, G. et VISINTINI, G. (a cura di). *L'insegnamento del diritto oggi*. Milano: Giuffrè, 1996; GROSSI, P. *Storia del diritto e diritto positivo nella formazione del giurista di oggi*. *Rivista di storia del diritto italiano*, 1997, p. LXXX; GROSSI, P. *El punto y la línea (Historia del derecho y derecho positivo en la formación del jurista de nuestro tiempo)*. Sevilla: Universidad de Sevilla, 1998.

2. Um risco da modernidade: absolutização e mitificação

Explicaremos melhor, tornando o discurso mais pontual através de uma referência específica.

Ainda não se apagou na minha memória a ênfase extremamente inflada com que foi comemorado por todos os lados o bicentenário daquele evento seguramente formidável que foi, em 1789, o início da Revolução Francesa. Evento, sem dúvida alguma, formidável, até mesmo por sua enorme influência na história política e jurídica da Europa continental, mas que deve ser avaliado historiograficamente, com a distância que um conhecimento autenticamente crítico oferece na avaliação de criaturas inseridas no ventre da história.

Temos diversas dúvidas quanto a este distanciamento em relação aos eventos iniciados em 1789 e, igualmente, tenho diversas dúvidas no que concerne a manutenção deste afastamento nas comemorações promovidas pouco tempo atrás. O motivo é logo dito: aqueles eventos sofreram uma absolutização, examinados pelos contempladores contemporâneos e futuros à luz de uma deformadora dialética maniqueísta: absolutização e mitificação. A dimensão cognitiva cedeu lugar àquela mitológica, gerando como fácil conseqüência entusiasmos e sentimentos incontrolados; do conhecimento passou-se decididamente a uma outra dimensão, aquela da crença, e o fato histórico – relativo justamente por ser histórico – transformou-se em mito, absolutizando-se.

Ter-se-ia o direito de crer que um comportamento deste gênero fosse estranho à modernidade, devido, precisamente,

às duas características pouco antes apresentadas: secularização e cientificismo, afirmadas com soberba como elementos de distinção e de separação do passado medieval e de suas bobagens metafísicas. Todavia, um exame minucioso e objetivo seria capaz de desmenti-lo imediatamente: a modernidade é uma fábrica muito fértil de mitologias, e isso porque, uma vez liberada a consciência coletiva das solidíssimas fundações metafísicas de antes e estando exilada a Igreja Romana a contar suas fábulas nos ambientes fechados dos seus templos, o mundo sócio-jurídico ficava sem apoio e suporte, ou seja, encontrava-se imerso em uma espécie de vazio e de conseqüente solidão, com o risco da perda de todo o controle social.

A mitificação de tão relativas, embora relevantes, conquistas históricas foi a fonte indispensável para garantir sua duradoura observância. E é justamente a Revolução Francesa – evento tido como libertador por aqueles que dela participaram como promotores e estimuladores – que se propõe, na sua roupagem mais de projeto intelectual do que de revolução popular, como um eficaz laboratório mitológico aos nossos olhos historiográficos despidos de malícia. Tal fenômeno acontece sobretudo quanto à sua encarnação mais radical, constituída pelo jacobinismo.

3. Um esclarecimento indispensável: significados e mensagens do jacobinismo jurídico

Revolução Francesa é – como bem sabe todo o historiador, ainda que singelo aprendiz – uma referência histórica que, na sua generalidade, não satisfaz, já que se trata de evento complexo que se articula por mais de um qüinqüênio, oferecendo diversos vultos muito diferentes entre si, com desenvolvimentos que assinalam fases diversas em relação ao programa contido nas primeiras enunciações e realizações do verão europeu de 1789.

Um destes vultos, ou melhor, o mais radical, mas também aquele que devido ao seu radicalismo mais se empenhou na construção de um modelo sócio-político-jurídico duradouro – e, querendo-o duradouro, armou-o com uma couraça solidíssima de mitificações, fonte, por sua vez, de crenças absolutas – foi justamente o jacobinismo, que aqui nos interessa enquanto fábrica de um projeto jurídico. Interessa-nos porque um projeto deste tipo concretizou-se em um discurso que chegou quase intacto até nós, com uma capacidade extraordinária de ter muitas vidas nos diferentes contextos históricos que se sucederam nos últimos duzentos anos, discurso que – neste seu perdurar e neste seu radicar-se em crenças – constituiu e constitui um obstáculo para a livre adequação do direito aos sinais dos tempos.

Jacobinismo jurídico – para compreender o pleno significado desta conferência, será proveitoso partir de uma pre-

missa que esclareça em quais conclusões essenciais é identificável a sua mensagem[2].

Existe a idéia central de um Estado, que tem por vocação transformar a sociedade e modelar o povo e que, conseqüentemente, é pensado e desejado como Estado forte, centralizador. Somam-se, ademais, dois comportamentos complementares: a desconfiança do "social", em cujo cerne circula rastejante um costume que, para a autoridade, é incontrolável, mas também permeável por forças desviantes (como, por exemplo, os "execráveis" influxos religiosos); a confiança e, conseqüentemente, completo crédito ao "político" (entendido no modo mais restrito e exclusivo), que tem por tarefa vigiar permanentemente a sociedade civil, através de uma classe de profissionais organizados em uma comunidade ideologicamente bem fechada (o partido)[3].

As conseqüências são pesadíssimas mesmo no plano jurídico. A visão é rigorosamente estatalista, ou seja, monista, pre-

2 Um primeiro guia pode ser encontrado no verbete *Jacobinisme*. In: FURET, F. et OZOUF, M. (sous la direction de). *Dictionnaire critique de la Révolution française*. Paris: Flammarion, 1993. Para um aprofundamento, são úteis diferentes ensaios contidos na coletânea de LUCAS, C. (ed.). The French Revolution and the creation of modern political culture, II. *The political culture of the French Revolution*. Oxford: Pergamon, 1994, assim como o recente e excelente GUENIFFEY, P. *La politique de la Terreur. Essai sur la violence révolutionnaire* (1789/1794). Paris: Gallimard, 2000. Uma reconstrução personalíssima encontra-se em JAUME, L. *Le discours jacobin et la démocratie*. Paris: Fayard, 1989, e em JAUME, L. *Échec au libéralisme: les Jacobins et l'État*. Paris: Kimé, 1990.

3 *"Activité, pureté, surveillance"* é o lema do Comitê de Saúde Pública nos anos 1793-1794 (a propósito, ver as páginas – há pouco escritas – de STOLLEIS, M. *Das Auge des Gesetzes. Geschichte einer Metapher*. München: C.H. Beck Verlag, 2004, p. 55-56, em um feliz quadro histórico sobre a metáfora do olho da lei que vigia e controla os cidadãos).

vendo um único produtor de direito: o aparelho estatal. No centro deste, a assembléia dos representantes, onipotente, já que nessa se conclui e se resume o problema da soberania do povo, este último, reduzido a servir como coro que, no fundo, aplaude, sem nenhuma capacidade operativa direta; uma assembléia que pretende agir não só em nome do povo, mas, também, no lugar do povo, o qual se encontra completamente desprovido de poderes de controle e de censura.

E o direito se resume à lei, as única fontes que, na pretensão jacobina, expressariam a vontade geral: graças à sua generalidade e abstração, as leis poderiam obter o resultado de uma projeção jurídica compactamente uniforme, os cidadãos, por seu turno, seriam – no plano jurídico – considerados todos abstratamente iguais, concebidos como indivíduos abstratos, malgrado as misérias e os grilhões das situações concretas em que vivem.

O Estado jacobino não é nem anônimo, nem neutro; ou melhor, como fonte de civilização e de progresso, é portador de princípios[4], defensor de uma determinada ortodoxia, não pode deixar de tender à proclamação de verdades indiscutíveis e, conseqüentemente, de regras absolutas; não pode deixar de propor-se – como se mencionava mais acima – como eficaz laboratório mitológico, fábrica de conclusões que devem ser acreditadas e não criticamente examinadas.

4 *"Nous voulons substituer, dans notre pays, […] les principes aux usages"*, afirma Robespierre no seu *rapport* à *Convention* de 5 de fevereiro de 1794 (citado em Gueniffey. P. *Op. cit.*, p. 318)

4. A "redução" jacobina da complexidade social

No coração deste eixo de crenças jurídicas está o vínculo restrito e exclusivo entre Estado e *vontade geral*, entre a vontade normativa do Estado, a lei, e a *vontade geral*: somente o primeiro pode expressá-la, somente à segunda é concedido manifestá-la.

Em outros termos, a decidida virada jacobina – que não nasce improvisadamente, mas recolhe com fidelidade (e intensifica) ideais e convicções que há tempo circulavam em todo o iluminismo jurídico[5] – dá consistência histórica a duas escolhas fundamentais, uma conseqüência da outra: o Estado como único produtor de direito; a lei como sua única fonte. Deste modo, toma corpo definido o axioma que imobiliza as fontes do direito em uma escala hierárquica (axioma que foi muito bem recebido) e que, substancialmente, desvitaliza todas, menos aquela inserida no primeiro e supremo degrau.

Estatalidade e legalidade do direito, que o positivismo jurídico do século XIX receberá e aplicará com rigor, projetando uma clara tendência a transformar-se em estatolatria e legolatria, com os perversos resultados que se encontram em toda a história jurídica moderna. A lei vinha a assumir uma virtude, em certo sentido, taumatúrgica. Passava a ser o instrumento capaz de transformar as desordenadas relações

5 Recolhendo também as instâncias das novas monarquias modernas, que cada vez mais encarnam a forma e a substância de verdadeiros Estados, com Príncipes que são e querem ser, acima de tudo, legisladores.

sociais em regras jurídicas merecedoras de ser observadas por parte dos súditos. O legislador, sofrendo um processo de forte idealização, apresentava-se como uma espécie de moderno rei Midas, acima das paixões humanas, com o olhar constantemente voltado à felicidade pública[6]; e a atenção se deslocava, de modo arriscado, do conteúdo à forma da lei: o importante era que o ato normativo proviesse de um determinado sujeito – aquele investido pelo poder supremo da soberania – com a única garantia do respeito a um certo processo e a uma adequada publicidade.

O elogio da lei consistia sobretudo no elogio da norma, certa e clara, ficando absorvido o problema do seu conteúdo em uma confiança ilimitada no legislador, uma confiança que logo se revelaria mal depositada, como teria demonstrado com eloqüência o uso e o abuso do instrumento legislativo feito não só pelas ditas democracias burguesas, como também pelos regimes totalitários do século XX.

Tratou-se de uma operação drasticamente redutiva: o universo sócio-político-jurídico passava a ser reduzido a dois protagonistas, Estado e indivíduo, com a anulação quase que total da sua complexa articulação. Iniciava-se a realização da grande promessa contida na mais autêntica mensagem iluminista; a sociedade passava a ser reduzida a uma pureza

6 Tratava-se da típica idealização iluminista do Príncipe, que se unia à visão pessimista da ciência jurídica e da jurisprudência prática. No século XVIII italiano, é o comportamento que encontrava voz consumada e prestigiosa nos libelos de Muratori e de Beccaria.

de linhas. Transferir-se-ia para ela a pureza de linhas geométricas que os novos estudiosos das ciências naturais identificavam, dia após dia, de modo sempre mais evidente, abaixo da emaranhada natureza física. Redução da velha complexidade sócio-político-jurídica em uma estrutura simples, o mais simples possível, seguida de apressada identificação da complexidade como caótica desordem e da simplicidade em linearidade e essencialidade. Florescia, deste modo, uma mentalidade que tinha como pano de fundo o horror e o desprezo em relação à velha complexidade.

Esquecia-se de um aspecto bastante relevante: aquela complexidade significava história viva e cotidianamente vivida, significava historicidade de princípios, regras, instituições, a nova ordem, por sua vez, assumia sempre mais a figura de um modelo abstrato catapultado na cotidianidade.

Uma opção clara parecia guiar o novo modelo jurídico, um modelo que deveria subordinar a multiformidade da experiência: generalidade e abstração. O direito, justamente por ser concebido como abstrato, facilmente se tornava um sistema unitário e coerente, espelho e cimento da unidade política do Estado. Tal fenômeno representava, também, maior risco para uma dimensão da sociedade naturalmente vocacionada a uma função essencialmente ordenadora: o risco de tornar-se uma substancial mitificação.

A abstração e a generalidade das regras jurídicas permitiam atingir como resultado positivo uma coerência racional, mas continham em si o risco de vir a ser a vulgar "folha de

figo" que oculta as misérias e as vergonhas com as quais, inevitavelmente, é tecida a história cotidiana de um povo; misérias e vergonhas que continuavam a subsistir, não obstante o exorcismo representado pelos edifícios geométricos construídos sobre as fundações de um indivíduo abstrato e de um sujeito estatal igualmente abstrato por ser desejado e pensado intacto em relação às contaminações da historicidade factual.

Entre os leitores pode vir a florescer uma suspeita: quer-se, talvez, repetir hoje um inadmissível elogio do antigo regime pré-revolucionário? Absolutamente não, mesmo porque seria ridiculamente anti-histórico e constituiria um pecado cultural bastante grave, ainda mais vindo da boca de um estudioso da história do direito.

O antigo regime, sistema intimamente estamental, não era só politicamente caótico, como era, outrossim, socialmente percorrido por grandes iniqüidades. Era, porém, fruto de uma tradição histórica milenar, lentamente sedimentada através do costume – o uso imemorável –, poderoso instrumento de decantação e de assimilação. Tratava-se de uma sociedade desigual em que cada um tinha o seu lugar, profundamente perverso, diga-se, porquanto previa a existência do nobre e do plebeu, do rico e do pobre – porque, enfim, o pobre era nesta previsto como pobre.

Contudo, nesta previsão impiedosa, existia a contemplação desencantada de um sujeito de carne e osso, um sujeito que a consciência coletiva contemplava como tal e, desta feita, incluía-o no ventre da sociedade, providenciando alguma

tutela elementar mesmo que seguramente insuficiente. Os *privilegia pauperum*, bem conhecidos dos historiadores do direito, são o resultado jurídico desta contemplação. Pouco, muito pouco, para lavar a mancha de uma iníqua condição essencial que permanece, mas talvez alguma coisa a mais do que aquela previsão de somente projetos abstratos, por sorte todos iguais, mas iguais unicamente em um mundo teórico irreal, em que não existiam vestígios do pobre, como se – por encanto – tivessem sido apagadas as míseras condições e as privações da sua vida cotidiana.

Quando, logo após o deflagrar da Revolução, o inglês Edmund Burke escreveu algumas páginas polêmicas que se tornaram famosas, contra os eventos e os projetos que amadureciam em Paris[7], às vezes as suas avaliações foram ao encontro de uma unilateralidade partidarista, o que as tornava muito discutíveis: mas, certamente é inegável seu acerto quanto à estigmatização e à enorme redução da complexidade histórica que se estava realizando por de trás da opção pela abstração. Era, de fato, uma rejeição global de todo o passado, mas também da riqueza que poderia estar contida em sua eventual herança; era alcançar uma meta falaz, já que a simplicidade cativante do novo projeto exorcizava só nominalmente a atualidade da vida social.

7 Faz-se referência à obra *Reflections on the Revolution in France* (Oxford: Oxford University Press, 1999), que Edmund Burke escreveu ainda no calor dos fatos, em 1790.

5. A "Carta de Nice" como a última "carta" de direitos

Todo esse reducionismo – que antes de tudo é jusnaturalista e posteriormente iluminista, para depois encarnar de modo particularmente intenso no projeto jacobino e chegar bastante intacto até ontem – deve estar bem presente como premissa de um discurso que quer avaliar a "Carta dos direitos fundamentais da União Européia" aprovada no final de 2000 pelo Parlamento Europeu e pela Comissão, subscrita e proclamada na sessão de Nice, de 7 de dezembro de 2000, por parte dos respectivos Presidentes e que se tornou, agora, parte integrante do projeto de Constituição Européia.

Tentaremos explicar bem a relação, ou melhor, a estreita conexão que há pouco foi indicada.

A "Carta de Nice" é uma "carta": afirmação óbvia que quer, entretanto, salientar a artificialidade de uma redação dominada pela idéia-condutora que se fundamenta na possibilidade e na oportunidade de identificar algumas situações subjetivas essenciais por parte de uma Comissão de especialistas revestida de poderes demiúrgicos; com o risco de uma provável separação entre o refinado projeto elaborado por intelectuais de grande porte e as aspirações, as exigências que floresceram na experiência cotidiana da vida histórica da União. Em outras palavras, o risco é de uma separação forte entre uma catalogação teoricamente prezável (e, por isso, imóvel) e o contexto histórico.

A única salvação que se deve objetivamente salientar, ou seja, o único gancho ao contexto, consistiu na recepção – feita pela Comissão redatora – de diversas aquisições realizadas pelo Tribunal de Justiça da União, quando este último – empiricamente –, aproveitando as ocasiões oferecidas pelos casos individualmente levados a sua atenção, mas fazendo referência constante às "tradições constitucionais comuns", chegou, passo após passo, no sulco de uma experiência viva, à identificação judiciária dos direitos.

A opção por uma "Carta" reproduz hoje a velha desconfiança iluminista e jacobina em relação ao estamento dos juristas[8] e ao juiz aplicador, assim como a velha confiança na "política", o velho culto da ortodoxia que somente um texto em um pedaço de papel pode plenamente garantir. Mas convém reforçar que o Tribunal, sabiamente, já havia traçado a estrada mestra, sem proclamações e enfatizações, na humildade de um contato imediato com o direito vivo.

Contemplando o passado de uma capilar e eficaz construção lentamente edificada, mas se projetando também em direção ao presente e ao futuro, um internacionalista-comunitarista do valor de Antonio Tizzano, em uma recentíssima ocasião congressual da qual participávamos, não tergirversou ao sintetizar através de claras notas o seu pensamento com um trocadilho eficazmente feliz: "mais Corte do que Car-

8 O que não é desmentido pelo fato de a Comissão redatora ser composta em absoluta prevalência por juristas, que, no interior dessa, serviam de especialistas a representar os Estados, fato que os tornava perfeitamente controláveis pelas autoridades públicas individualmente.

ta"[9], querendo, por um lado, salientar o grande papel desempenhado pelo supremo órgão judiciário comunitário e também a substancial e latente contribuição à parte duradoura da "Carta"; pretendendo, por outro, expressar o pesar pelo fato de que não se continuasse na estrada – nem rápida, nem vistosa, mas segura e bem fundamentada – de uma fixação judiciária dos direitos.

Optou-se, ao contrário, por uma "Carta", o que nos relançou à tradição jusnaturalista e do século XVIII. Tanto é verdade que este documento de Nice nos foi proposto como o último elo de uma plurissecular cadeia. Com uma ponta declaradamente polêmica, quisemos chamá-la, em recente reflexão sobre ela, a "última Carta de direitos", uma qualificação que, parecendo-nos absolutamente apropriada, reproduzimos ao intitular este capítulo[10].

6. A ilusão de uma redução do direito em um pedaço de papel

A redução do direito em "Cartas", em textos – enfim – em pedaços de papel, é aspecto peculiar da história do direito moderno no seu momento de plena maturidade.

---

9 *"Più Corte che Carta"*. Foi no Encontro promovido nos dias 19 e 20 de junho de 2003 pelo Istituto dell'Enciclopedia Italiana sobre *"La Costituzione Europea tra Stati nazionali e globalizzazione"* [A Constituição Européia entre Estados nacionais e globalização]. A conferência de Antonio Tizzano tinha por tema *Il ruolo del giudice comunitario nel processo di integrazione europea* [O papel do juiz comunitário no processo de integração européia].

10 Ver VETTORI, G. (a cura di). *Carta europea e diritti dei privati*. Padova: Cedam, 2002, p. 247 ss., assim como a obra coletânea *Diritti, nuove tecnologie, trasformazioni sociali*. Scritti in memoria di Paolo Barile. Padova: Cedam, 2003.

É também uma suprema ilusão, a ser entendida sob a égide de um comportamento otimista e, ao mesmo tempo, pessimista. Expressa a confiança em poder fixar – talvez para sempre – o tornar-se jurídico. Expressa a desconfiança na formação espontânea do direito, com a conseqüente exigência de que seja controlado pela "política", ou – até mesmo –, de que seja monopolizado pelo Estado. Como já dissemos, e convém aqui repetir, por um lado se trata de um reducionismo ingênuo e pretensioso, por outro, de prática sabiamente estratégica, que encontrou na voz jacobina sua expressão mais límpida e lúcida.

O *Código*, os *Códigos*, com o qual é constelada a Idade Moderna a partir dos primeiros anos do século XIX, são a manifestação mais plena de tal mania redutiva. Todo o direito pode e deve ser reduzido às páginas de um sucinto livrinho, aprisionado em uma rede de regrinhas chamadas artigos (ou parágrafos), em que claramente são fixados princípios e comandos; todo o direito, mesmo o direito civil que ordena a vida cotidiana dos privados.

No ano 2000, a nossa "Carta de Nice" também se inseriu nesta linha. Esta enrijeceu o patrimônio vivo que provinha da experiência do Tribunal, imobilizou-o como que numa catalogação, temperou-o com abstração, fixando-o em uma Declaração. Mas o conjunto dos direitos fundamentais – para o sujeito – não é uma decoração externa, é, ao contrário, garantia essencial, ou seja, vivida na luta cotidiana e que se tornou tutela efetiva. É, em suma, o exercício que o torna

positivo e palpável. Conseqüentemente, é natural que, na história da União, fosse justamente no momento de aplicar este conjunto que surgisse tal problema, que dele se deduzisse a sua fixação, sem fossilizá-lo mas, ao contrário, estando plenamente disponível para revisões, acréscimos, intensificações, como é próprio da flexível práxis judicial.

Após a Cúpula de Tessalônica, a "Carta" foi inserida num projeto de carta constitucional mais vasto, entretanto uma pergunta se impõe: a "Carta" está em sintonia com as tradições constitucionais comuns, em relação às quais o Tribunal de Justiça tivera tão prezável sensibilidade? Ou se corre o risco de termos uma separação entre Constituição formal e Constituição material da Europa?

Acreditamos que ainda hoje se deva levar em consideração a advertência, velha, mas não envelhecida, que Santi Romano, quase cem anos atrás, considerava-se no dever de fazer a respeito das primeiras cartas constitucionais. Uma advertência, mas também uma diatribe contra o comportamento acrítico, de baixa apologética, da absoluta maioria dos constitucionalistas, seguramente ancorada na deferência a lugares comuns. Aos olhos demitificadores do grande jurista siciliano, essas se apresentavam mais como simples "enunciados", simples "índices, além de tudo não completos, de um código infinitamente mais amplo", quando não "catecismos" a serem postos à veneração pública[11]. Emergia forte, deste

11 ROMANO, S. *Le prime Carte costituzionali*. In: *Lo Stato moderno e la sua crisi*. Saggi di diritto costituzionale. Milano: 1969, p. 164-168.

modo, o problema de relacionamento entre estas pontas que floresciam e o continente submerso que as mesmas pontas deixavam privado e mal entrevistas.

7. E o seu característico individualismo: o indivíduo como indubitável protagonista

Também em um outro aspecto, a "Carta de Nice" mostra a sua herança iluminista e típica do século XVIII: no característico individualismo que a domina. No texto se faz menção ao indivíduo, com um estribilho monotonamente recorrente: "Todo indivíduo (...)"[12].Não façamos, no entanto, questões nominalistas, até porque a terminologia não é a mesma nas redações das várias línguas.

O aspecto individualista torna-se evidente pelo modo de conceber o sujeito em exame. Trata-se, claramente, de um indivíduo isolado, presente de um modo vigoroso em todas as "Cartas" dos séculos XVIII e XIX. Um indivíduo abstrato, cujo adjetivo é portador perfeito do preciso significado contido na expressão latina *abs-tractus*, ou seja, *extraído* do seu contexto histórico, isolado da sua carnalidade histórica representada sobretudo pela sua sociabilidade.

"Um homem abstrato, que não existia em nenhum lugar", segundo o profundo esclarecimento fornecido por Hannah Arendt[13]. Um homem de pouca humanidade, uma espécie

---

[12] Conforme a versão italiana da "Carta":*"Ogni indivíduo (...)"* (Nota do Tradutor).
[13] ARENDT, H. *Le origini del totalitarismo*. Milano: Einaudi, 1997, p. 404 (edição brasileira: ARENDT, H. *As origens do totalitarismo*. São Paulo: Cia. das Letras, 2004).

de robô que existe somente naquele paraíso artificial jusnaturalista – nem céu, nem terra, mas nuvem flutuante – um indivíduo – em suma – sem terra e sem céu.

Um indivíduo que não é pessoa, já que para se ter uma "pessoa" é necessário que esta se encontre inserida em um feixe de relações, que seja um sujeito que se relaciona com outros, sujeito *comunitário* por ser vocacionado à família, à igreja local e universal, à corporação e também ao sindicato, ao partido, à comunidade política local, nacional e internacional.

Este indivíduo, que encontra o próprio cunho entre as dobras da modernidade, é realidade anônima, qualitativamente anônima, marcado prevalentemente por um apêndice que é externo a ele, mas que lhe fornece uma insubstituível integração, insinuando-se na sua identidade e desempenhando, deste modo, um papel exorbitante e desnaturalizador – exatamente desnaturalizador por ser exorbitante –, ou seja, o *ter*.

A dicotomia fundamental sobre a qual se articula a civilização burguesa, que toma vulto sempre mais definido com o progredir da ordem econômica capitalista, baseia-se na distinção entre quem tem e quem não tem. Para a civilização do ter, isto basta, porque tanto mais se *é*, quanto mais se *tem*, com uma mescla e quase fusão entre duas dimensões que, por si mesmas, são tão distantes. A propriedade não é somente fonte de riqueza, de bem-estar e também de poder: sofre uma elevação nunca antes conhecida, entra de modo prepotente no cuidadoso campo da moral, torna-se até mesmo instrumento de edificação, sacralizando-se. Vem à men-

te, em um primeiro momento, o genial, ainda que unilateral, ensaio weberiano sobre o nexo entre ética protestante e espírito capitalista[14]. Mas, para mim, jurista, também a desconcertante introdução que o civilista francês do século XIX, Jean-Baptista Proudhon, elabora para a sua obra extremamente técnica – o *Traité du domaine de propriété* –, em que propriedade e virtude são indissoluvelmente ligadas[15].

Não será, contudo, a maior ou menor quantidade de patrimônio que tornará menos anônimo o sujeito. Isso, malgrado os esforços da multíplice reflexão burguesa (filosófica, política, jurídica). O indivíduo é e permanece espiritualmente e socialmente anônimo. É este o protagonista da "Carta de Nice", mesmo que formalmente despido do peso patrimonial.

Surge, então, uma suspeita legítima: que este documento do ano 2000 herde e reproduza com fidelidade a dimensão econômica que seguramente era elemento relevante (mas não o único) nas origens e no desenvolvimento de um sistema comunitário europeu, voltado a constituir uma ordem transnacional que desse suporte à instituição de uma grande área de livre circulação de mercadorias, de capitais, de serviços.

---

[14] É evidente a referência ao ensaio famosíssimo de WEBER, M. *Die protestantische Ethik und der "Geist" des Kapitalismus*. Weinheim: Julius Beltz-Athenaeum, 2000 (edição brasileira: WEBER, M. *A ética protestante e o espírito do capitalismo*. São Paulo: Cia. das Letras, 2004).

[15] PROUDHON, J.-B. *Traité du domaine de propriété*. Dijon: Lagier, 1839, n.°s 57, 58, 59, 62.

8. O indivíduo insular

O indivíduo, justamente por encontrar na dimensão econômica a sua fundamentação e a sua arquitetura, é bastante cimentado em uma posição egoísta e necessariamente egocêntrica. Se a pessoa deve mesmo ser pensada na sua projeção para com o outro e, deste modo, em conexão com o outro, o indivíduo, ao contrário, é voltado para a sua insularidade. O exercício da dimensão econômica inevitavelmente o conduzirá a uma vida de relacionamento com outros, mas a regra que rege o seu microcosmos, o lucro, permitirá gerir esta vida somente sob a égide da satisfação individual. Deste modo, a sua característica psicológica somente poderá ser a insularidade.

Os indivíduos, enquanto *homines oeconomici*, serão separados uns dos outros precisamente devido ao objetivo essencial da própria ação, isto é, o lucro, já que o meu lucro é realidade que não leva em consideração o outro, nem mesmo sob o grosseiro perfil do lucro do outro.

As liberdades com as quais o indivíduo se reveste sofrem os efeitos desta insularidade, medindo-se através da sua subjacente hipertrofia e refletindo-na. De um modo contundente, uma estudiosa italiana da teoria do direito, após uma análise atenta e desapaixonada, não pôde deixar de falar de "direitos insaciáveis", ou seja, de direitos pensados e construídos prescindindo do outro, fruto de uma visão isoladora que os hipertrofia e os deforma[16].

[16] PINTORE, A. *Diritti insaziabili*. In: FERRAIOLI, L. *Diritti fondamentali – Un dibattito teorico*. Bari: Laterza, 2001.

Superficialmente se pensa a liberdade como ausência de ligações[17], ao passo que – ao contrário – a autêntica liberdade consiste somente na relação harmônica e respeitosa entre a minha liberdade e a do outro. Por ser dimensão da sociabilidade, não encontra na solidão o seu terreno por excelência. Só mesmo em uma ilha deserta o homem não é livre nem merece, enquanto ficar sozinho, ser qualificado como livre. Para este homem não faz sentido falar de liberdade. Para ele, que vive em uma espécie de vazio social, a liberdade é dimensão ausente, que não nasceu, nem nunca poderá nascer, fulgurando somente no momento fértil do encontro com o outro.

Certamente um mundo pensado como povoado por indivíduos pode articular-se em liberdades, mas se tratando – como vimos acima – de pluralidade insular, as liberdades não poderão ser construídas sobre o molde do individual e serão "insaciáveis" por serem próteses a fagocitar as demais liberdades ou a prescindir delas, chegando até mesmo a desprezá-las. Gostaríamos de concluir este ponto com uma recomendação: não esqueçamos – ou, melhor, façamos nossa – a advertência que dois cuidadosos juristas italianos colocaram no centro de uma recentíssima reflexão, a ser lida e meditada: "nenhuma liberdade individual se mantém sem a dimensão coletiva"[18]. Complementamos ainda: devido ao fato de as

[17] A indicação do risco vem do exercício reflexivo da teologia católica. Um texto exemplar neste sentido o é GIUSSIANI, L., ALBERTO, S. et PRADES, J. *Generare tracce nella storia del mondo*. Milano: Rizzoli, 1998, p. 164 ss.

[18] *"nessuna libertà individuale regge senza la dimensione collettiva"*. In: LOMBARDI, G. et ANTONINI, L. Principio di sussidiarietà e democrazia sostanziale: profili costituzionali della libertà di scelta. *Diritto e società*, n.° 2 (2003), p. 15.

dimensões social e coletiva serem o ventre natural das liberdades e por somente nessas se apresentarem elas sem alterações deformadoras, por somente nestas não assumirem a desnaturação da "insaciabilidade".

9. O insuficiente projeto de dimensão coletiva do sujeito no tecido da "Carta": um sinal de continuidade pós-iluminista

Na "Carta" menciona-se apenas a dimensão coletiva do sujeito. Na nossa opinião, esta encontra-se insuficientemente projetada. A "Carta" demonstra, deste modo, estar em continuidade com a tradição política e jurídica burguesa, caracterizada por uma hostilidade frontal em relação a toda e qualquer coletividade onde o sujeito possa vir a encontrar condicionamentos à própria liberdade individual.

A anulação radical das sociedades intermediárias, que consta nos programas dos mais convictos Príncipes iluminados e que se identifica com a ação política a ser realizada com a máxima urgência, encontrou no aceso clima revolucionário a sua manifestação mais intensa. Mas é um comportamento que não se esgota no projeto utópico do iluminismo político-jurídico e na imediação da fogueira revolucionária. Trata-se de uma constante de pensamento e de ação, de enunciações teóricas e comandos legislativos que têm suas próprias raízes na mais genuína mitologia individualista. É portanto, tradição de difícil extinção, que se viu duramente combatida somente durante o século XX – período a partir do qual passou a ter expostas fissuras e rejei-

ções – e que, ainda hoje, cremos, não está completamente superada, embora muita água tenha passado sob as pontes dos grandes rios europeus.

A redução da complexidade sócio-política ao binômio Estado-indivíduo pareceu satisfatória, definitivamente satisfatória, mas, de fato, sacrificou a riqueza plural da sociedade, tornando-a de qualquer modo incompleta, inconsumada, inexpressiva. Atualmente, existe a inadiável exigência de pensar (e analisar) o sujeito no interior de um tecido social. Um tecido a quem tenha sido restituída toda a sua complexidade, além da sua capacidade integral de manifestar e realizar suas multíplices potencialidades, cortadas pelo reducionismo estatalista e individualista moderno.

10. A exigência de um resgate: contra a monopolização estatal da dimensão política; a sociedade intermediária como autenticamente política

Deve ser reconhecida à tradição católica o mérito de ter mantido acesa a confiança na função positiva das sociedades intermediárias. Positiva para a sociedade global e para o mesmo sujeito-indivíduo. João Paulo II, na carta encíclica que comemorou o centenário da leonina *Rerum novarum*, afirmou, com força, o papel da agregação coletiva que vai além da célula familiar.

Deixamos a ela a palavra, já que se trata de um texto vigoroso e eficaz:

> "Além da família, também outras sociedades intermédias desenvolvem funções primárias e constroem específicas redes de solidariedade. Estas, de fato, amadurecem como comunidades reais de pessoas e dinamizam o tecido social, impedindo-o de cair no anonimato e na massificação"[19].

É um forte apelo a mudar de estrada, a rever profundamente o nosso inveterado estatalismo, invertendo uma marcha que levou ao ressequir da política e aos incômodos que atualmente encontramos na edificação de uma entidade transacional européia.

Os nossos pais acreditaram convictamente no Estado. Acreditaram tanto a ponto de esgotar neste a gama múltipla da politicidade entregue a eles pela civilização precedente. Estatalismo e estatolatria nunca desmentidos, ou melhor, reforçados nos últimos duzentos anos da história continental européia, tornaram-se indiscutíveis por serem considerados insuperáveis. O Estado, isto é, o Estado moderno, se apresentava a eles como uma conquista, uma meta, o ponto alto atingido pela inteligência humana ao racionalizar as desordenadas e obstinadas forças sociais. Finalmente se tinha colocado ordem onde não existia: esta era a convicção, a crença sobre a qual se construiu na Europa continental o mito do Estado, da sua sublimidade e, por isso, da sua venerabilidade.

---

[19] A referência evidente é à encíclica *Centesimus annus* de 1.° de maio de 1991, n.° 49. Reportamos aqui o texto oficial, em latim: *"Extra familiam vero, primas partes agunt nexusque aptant proprios solidarietatis aliae interpositae societates. Suo etenim fungente munere, omnes hae societates veluti personarum communitates adolescunt quae veluti nervos socialis corporis paene texunt prohibentes quominus in ignota illud decidat et inter multitudines sine misceatur"*. In: *Enchiridion vaticanum 13. Documenti ufficiali della Santa Sede. 1991/1993*. Bologna: ESD, 1996, p. 158-159.

As lentes mitológicas impediram até hoje uma visão mais crítica do processo histórico de formação do Estado moderno e de seu perdurar, indo muito além das circunstâncias que o tinham provocado e legitimado. Com os dois resultados objetivamente negativos citados acima.

Realizou-se uma espécie de restrição da política: era político somente o que se ligava ao macrocosmos político, ou seja, ao Estado. O dano que causou não foi de pequena dimensão. Repetimos, já que é o elemento fundamental sobre o qual fomos urgentemente chamados a refletir: a dimensão política se esgotou e se identificou na dimensão estatal, mas, com isso, acabou por se tornar enrugada e mais pobre. Sem pensar que o Estado moderno, mesmo hoje na sua usual estruturação democrático-parlamentar, é sempre aparelho do poder, é sempre um nó corrediço que sufoca o social, freando e contendo o seu espontâneo pluralismo; porque o poder exige compactação, tem horror a um terreno acidentado e fragmentado em que o seu exercício se vê impedido de desenvolver-se livremente. Pode-se entender o motivo por que, deste modo, o Estado não tolera a sociedade intermediária: porque ela torna o terreno social acidentado. E pode-se entender a razão pela qual o Estado se harmoniza bem com o indivíduo e, ao revés, muito menos com a pessoa; porque o indivíduo – criatura eticamente e socialmente anônima – possui uma projeção econômica e, estando protegido nesta sua projeção, não tem pretensões políticas, não colocando em risco a compactação do poder. A pessoa, ao contrário, representa um risco. Precisamente pela sua natureza relacional e pelas suas

complexas projeções ético-sociais, que fazem delas criaturas não anônimas, e possíveis – quando não provável – brechas na compacta muralha do poder.

O segundo resultado negativo é tão relevante quanto o primeiro, mas interessa menos no que concerne a este ensaio. Mencionaremos somente para fornecer um quadro mais completo: o Estado, enquanto aparelho de poder, devido à sua compactação – aquela compactação que se expressa em termos político-jurídicos como soberania –, se traduz em forte insularidade que impede ou, ao menos, reduz o vigor do processo unificador transnacional que tende à construção de entidades políticas sempre mais amplas. Foi possível verificar de modo amargo tal fenômeno justamente nos dias do final de 2003, quando fomos obrigados a tomar conhecimento, com espanto, dos muitos nós dificilmente desenlaçáveis no enredo do tecido político-jurídico europeu.

Devemos, contudo, retomar o fio do discurso, revendo alguns pontos contidos no acima citado fragmento da Encíclica papal.

A opção feita pelos modernos, de identificar a politicidade na estatalidade, o "político" no "estatal", é uma operação estratégica bastante conveniente para o Estado moderno, já que lhe permite atingir o *maximum* da compactação. Se, por acaso, porém, o observatório de onde olhamos se voltar do Estado para a sociedade, imediatamente nos daremos conta do sacrifício que essa operação custa para a sociedade; aquilo que para o Estado é balanço ativo da compactação, para a sociedade é

o balanço passivo – usamos as eficazes palavras de João Paulo II – de uma "impessoal massificação". Continuando a citá-lo, o resultado é o "anonimato" do tecido social.

Em outras palavras – concluindo – tem-se um resgate urgente a ser feito. O "político" não pode ser confinado no absolutamente "público" – o Estado –, em que tudo soa como autoridade e poder; é também "político", sobretudo, a expansão pública do "privado", constituída pelas sociedades intermediárias em todas as suas concretizações e manifestações. Sociedade intermediária entendida como um "público" que não se separa do "social", mas que neste permanece embebida, impregnando-se de todas as facetas deste último; que impede, por seu turno, a total massificação e despersonalização que a confiança total no Estado/aparelho provoca e comporta.

O resgate a ser realizado, em resumo, é o das sociedades intermediárias como momento autenticamente "político". Com uma consciência invertida a respeito daquela que os velhos plágios ideológicos impuseram à cultura do cientista político e do jurista, não se deve parar no mesmo considerável porto, ou seja, aquele que nos faz crer que a dimensão política seja representada somente pelo Estado. Urge, ao contrário, tomar consciência de que a autêntica politicidade, aquela que não massifica e não empobrece o sujeito, está nas sociedades intermediárias. E hoje, período em que tanto se fala – e por sorte – de subsidiariedade[20], resta-nos fazer um salto

[20] Sendo, também, muitos e vazios os discursos sobre esse tema.

qualitativo invertendo o eixo de valores trazidos e dando efetividade à consciência a que aqui fizemos menção: não é tanto o Estado que graciosamente concede um espaço limitado às sociedades intermediárias, mas são as sociedades intermediárias – finalmente livres no que concerne à sua operatividade dentro das raízes do social – que encontram no forte aparelho estatal um precioso suporte.

Ecco, sobre esta dimensão coletiva do sujeito – ou seja, sobre a presença e o papel de entidades coletivas em que o sujeito se expande e se enriquece – a "Carta de Nice" é substancialmente surda. Trata-se de uma constatação que nos parece ligada a uma leitura objetiva dos artigos que a compõem.

11. O insuficiente projeto de dimensão social do sujeito

Mas não é somente a dimensão coletiva, é também a dimensão social do sujeito que não recebe, em nossa opinião, um espaço satisfatório.

O perfil individualista que se apóia sobre um indivíduo meta-histórico e que ainda possui uma grande desconfiança da história social pode somente atenuar a sociabilidade do sujeito. Dever-se-ia pensar mais no "meu" direito como situação dentro de uma relação, ou seja, uma situação mais complexa, que chegasse a receber dele um perfil de deveres, o único capaz de resgatar a relação com o outro.

É, de fato, o contraponto direito/deveres que socializa e historiciza o sujeito, transformando-o em criatura carnal na sua consistência vital. Na "Carta", diz-se muito pouco de

deveres, ainda que conste no Preâmbulo; "O gozo destes direitos implica responsabilidades e deveres, tanto para com as outras pessoas individualmente consideradas, como para com a comunidade humana e as gerações futuras", afirmação tal que parece flutuar sobre a substância de um documento em que é bastante estranha uma ética da responsabilidade como princípio informador.

O caráter do documento entendido como "Carta" (e desejado como "Carta", como Declaração, como Catálogo, por fim) também faz com que esteja pouco presente a dimensão do exercício. Os direitos são um fenômeno intrisicamente constitucional, ou seja, inerente à constituição profunda, aquela que a reflexão germânica chama *Verfassung* e que poderemos aproximativamente qualificar à italiana como "*Costituzione materiale*".

Foi o Tribunal de Justiça das Comunidades Européias que, de um modo lento, mas progressivo, realizou a identificação de direitos fundamentais trabalhando sobre as raízes profundas das "tradições constitucionais comuns". Uma identificação por via judiciária que teve o grande mérito de fundamentar-se sobre o direito vivo europeu.

O Conselho Europeu de Colônia, de junho de 1999, fez uma opção que tomava uma estrada diferente e desmentia o caminho e os meios pelos quais resultados tão notáveis foram lentamente alcançados pelo Supremo Organismo judiciário. Prevaleceu a legítima necessidade de fixar rapidamente e textualmente em um corpo orgânico um sistema de direitos

fundamentais. Escolheu-se como instrumento uma "Carta"; mas, mesmo com toda a devida compreensão dos motivos que regeram o Conselho, existia – como ainda existe – um grave risco: o da artificialidade, da textualidade imóvel que separa um contexto constitucional em contínua evolução.

O risco, apesar da inteligência e do zelo profuso de tantos redatores, está no fato de que a "Carta de Nice" é uma "carta", último elo de uma cadeia que, *continuamente*, nos liga a um 1789 que hoje deveria estar não só temporalmente, mas sobretudo espiritualmente, longínquo. Referindo-nos à intitulação felicíssima e acertadíssima do encontro para o qual elaboramos esta conferência, concluiremos deste modo: não é somente se te distrai que a Europa se torna jacobina. Na realidade, o fio que nos liga às soluções mais radicais do grande evento revolucionário nunca se interrompeu.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALPA, G. Il codice civile europeo: 'e pluribus unum'. In: *Contratto e impresa/ Europa*, 1999.

ARENDT, H. *Le origini del totalitarismo*. Milano: Einaudi, 1997 (edição brasileira: ARENDT, H. *As origens do totalitarismo*. São Paulo: Cia. das Letras, 2004).

ASCARELLI, T. Funzioni economiche e istituti giuridici nella tecnica dell'interpretazione. In: *Saggi giuridici*. Milano: Giuffrè, 1949.

ASCARELLI, T. L'idea di codice nel diritto privato e la funzione dell'interpretazione. In: *Saggi giuridici*. Milano: Giuffrè, 1949.

BECCARIA, C. *Dei delitti e delle pene*. Milano: Giuffrè, 1964.

BOBBIO, N. Kelsen e il potere giuridico. In: BOVERO, M. (a cura di). *Ricerche politiche – Saggi su Kelsen, Horkheimer, Habermas, Luhmann, Foucault, Rawls*. Milano: Il Saggiatore, 1982.

BODIN, J. *Les six livres de la République*. Aalen: Scientia, 1977.

BOGNETTI, G. P. La funzione di Amalfi nella formazione di un diritto comune del Medioevo. In: *Mostra bibliografia e Convegno internazionale di studi storici del diritto marittimo medioevale*. Napoli: Associazione Italiana di diritto marittimo, 1934.

BONGIOVANNI, G. *Reine Rechtslehre e dottrina giuridica dello Stato – Hans Kelsen e la Costituzione austriaca del 1920*. Milano: Giuffrè, 1998.

BOVERO, M. (a cura di). *Ricerche politiche – Saggi su Kelsen, Horkheimer, Habermas, Luhmann, Foucault, Rawls*. Milano: Il Saggiatore, 1982.

BURKE, E. *Reflections on the Revolution in France*. Oxford: Oxford University Press, 1999.

BUSSANI, M. et MATTEI, U. (Ed.) *Making European Law – Essays on the "Common Core" Project*. Trento: Università degli Studi, 2000.

CALAMANDREI, P. La certezza del diritto e le responsabilità della dottrina. In: *Opere giuridiche*. Volume I. Napoli: Morano, 1985.

CARRINO, A. *L'ordine delle norme – Politica e diritto in Hans Kelsen*. Napoli: ESI, 1990.

CORSO, G. In che senso il diritto positivo costituisce un vincolo per il giurista. In: ZACCARIA, G. (a cura di). *Diritto positivo e positività del diritto*. Torino: Giappichelli, 1991.

DEL VECCHIO, G. Sui principi generali del diritto. In: *Studi sul diritto*. Volume I. Milano: Giuffrè, 1958.

Diritti, nuove tecnologie, trasformazioni sociali. Scritti in memoria di Paolo Barile. Padova: Cedam, 2003.

Enchiridion vaticanum 13. Documenti ufficiali della Santa Sede. 1991/1993. Bologna: ESD, 1996.

FERRARESE, M. R. *Le istituzioni della globalizzazione – diritto e diritti nella società transnazionale*. Bologna: Il Mulino, 2000.

FERRAIOLI, L. *Diritti fondamentali* – Un dibattito teorico. Bari: Laterza, 2001.

FRANCE, A. *Le lys rouge*. Paris: Calmann-Lévy, 1994.

FURET, F. et OZOUF, M. (sous la direction de). *Dictionnaire critique de la Révolution française*. Paris: Flammarion, 1993.

GIUSSIANI, L., ALBERTO, S. et PRADES, J. *Generare tracce nella storia del mondo*. Milano: Rizzoli, 1998.

GORLA, G. *Diritto comparato e diritto comune europeo*. Milano: Giuffrè, 1981.

GROSSI, P. *Assolutismo giuridico e diritto privato*. Milano: Giuffrè, 1998.

GROSSI, P. *El punto y la línea* (Historia del derecho y derecho positivo en la formación del jurista de nuestro tiempo). Sevilla: Universidad de Sevilla, 1998.

GROSSI, P. Il punto e la linea (impatto degli studi storici nella formazione del giurista). In: REBUFFA, G. et VISINTINI, G. (a cura di). *L'insegnamento del diritto oggi*. Milano: Giuffrè, 1996.

GROSSI, P. *L'ordine giuridico medievale*. Roma-Bari: Laterza, 1995.

GROSSI, P. Storia del diritto e diritto positivo nella formazione del giurista di oggi. *Rivista di storia del diritto Italiano*, LXX (1997).

GROSSI, P. *Scienza giuridica Italiana* – Un profilo storico, 1860-1950. Milano: Giuffrè, 2000.

GUENIFFEY, P. *La politique de la Terreur*. Essai sur la violence révolutionnaire (1789/1794). Paris: Gallimard, 2000.

JAUME, L. *Échec au libéralisme*: les Jacobins et l'État. Paris: Kimé, 1990.

JAUME, L. *Le discours jacobin et la démocratie*. Paris: Fayard, 1989.

Il Codice civile della Repubblica Democratica Tedesca. Milano: Giuffrè, 1976.

Le Conseil Constitutionnel et les partis politiques. Aix-en-Provence: Presses Universitaires, 1988.

LIBERTINI, M. Il vincolo del diritto positivo per il giurista. In: ZACCARIA, G. (a cura di). *Diritto positivo e positività del diritto*. Torino: Giappichelli, 1991.

LOMBARDI, G. et ANTONINI, L. Principio di sussidiarietà e democrazia sostanziale: profili costituzionali della libertà di scelta. *Diritto e società*, n.° 2 (2003).

LUCAS, C. (ed.). The French Revolution and the creation of modern political culture, II. *The political culture of the French Revolution*. Oxford: Pergamon, 1994.

LUHMANN, N. *Illuminismo sociologico*. Milano: Il Saggiatore, 1983.

MITTERRAND, F. *Le coup d'état permanent*. Paris: Plon, 1964.

MONTAIGNE, M. *Essais*. Paris: Flammarion, 1993 (edição brasileira: MONTAIGNE, M. *Os Ensaios*. São Paulo: Martins Fontes, 2000).

PALADIN, L. Esiste un 'principio di ragionevolezza' nella giurisprudenza costituzionale? In: *Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza della Corte Costituzionale*. Milano: Giuffrè, 1994.

PATRONI GRIFFI, A. Il Conseil Constitutionnel e il controllo della 'ragionevolezza': peculiarità e tecniche di intervento del giudice costituzionale francese. In: SCUDIERO, M. et STAIANO, S. (a cura di). *La discrezionalità del legislatore nella giurisprudenza della Corte Costituzionale (1988-1998)*. Napoli: Jovene, 1999.

PEDRAZZA GORLERO, M. *Il potere e il diritto – Elementi per una introduzione agli studi giuridici*. Padova: CEDAM, 1999.

PERLINGIERI, P. *Il diritto nella legalità costituzionale*. Napoli: ESI, 1984.

PINTORE, A. Diritti insaziabili. In: FERRAIOLI, L. *Diritti fondamentali* – Un dibattito teorico. Bari: Laterza, 2001.

PORTALIS, J. E. M. Discours préliminaire. In: *Naissance du Code civil – la raison du législateur*. Paris: Flammarion, 1989.

PROUDHON, J.-B. *Traité du domaine de propriété*. Dijon: Lagier, 1839.

REBUFFA, G. et VISINTINI, G. (a cura di). *L'insegnamento del diritto oggi*. Milano: Giuffrè, 1996.

REMY, J. P. Eloge de l'exegése. *Droits-Revue française de théorie juridique*, I, 1985.

RESCIGNO, P. *Persona e comunità – Saggi di diritto privato*. Padova: CEDAM, 1987.

RIPERT, G. *Le Déclin du droit – Études sur la législation contemporaine*. Paris: L.G.D.J., 1949.

RODOTÀ, S. Ideologie e tecniche della riforma del diritto civile. *Rivista del diritto commerciale*, I, 1967.

ROMANO, S. *Frammenti di un dizionario giuridico*. Milano: Giuffrè, 1947.

ROMANO, S. Le prime Carte costituzionali. In: *Lo Stato moderno e la sua crisi*. Saggi di diritto costituzionale. Milano: 1969.

ROMANO, S. *L'ordinamento giuridico*. Firenze: Sansoni, 1946.

ROMANO, S. *Lo Stato moderno e la sua crisi*. Saggi di diritto costituzionale. Milano: Giuffrè, 1969.

ROSSI, P. Observations sur le droit civil français consideré dans ses rapports avec l'état économique de la societé. In: *Mélanges d'économie politique, de politique, d'histoire et de philosophie*. Tomo II. Paris: Guillaumin, 1867.

S. TOMMASO. *Scriptum in 4 libros Sententiarum magistri Petri Lombardi*. Bologna: ESD.

S. TOMMASO. *Summa contra gentiles*. Bologna: ESD (edição brasileira: AQUINO, Tomás de. *Suma contra os gentios*. Porto Alegre: Sulina, 1990).

S. TOMMASO. *Summa Theologicae*. Bologna: ESD (edição brasileira: AQUINO, Tomás de. *Suma Teológica*. São Paulo: Loyola, 2002).

SCUDIERO, M. et STAIANO, S. (a cura di). *La discrezionalità del legislatore nella giurisprudenza della Corte Costituzionale (1988-1998)*. Napoli: Jovene, 1999.

STAIANO, S. Introduzione. In: SCUDIERO, M. et STAIANO, S. (a cura di). *La discrezionalità del legislatore nella giurisprudenza della Corte Costituzionale (1988-1998)*. Napoli: Jovene, 1999.

STOLLEIS, M. *Das Auge des Gesetzes*. Geschichte einer Metapher. München: C.H. Beck Verlag, 2004.

VASSALLI, F. Estrastatualità del diritto civile. In: *Studi giuridici*, Volume III, Tomo II. Milano: Giuffrè, 1960.

VETTORI, G. (a cura di). *Carta europea e diritti dei privati*. Padova: Cedam, 2002

VIOLA, F. *Autorità e ordine del diritto*. Torino: Giappichelli, 1987.

VIOLA, F. Tre forme di positività nel diritto. In: ZACCARIA, G. (a cura di). *Diritto positivo e positività del diritto*. Torino: Giappichelli, 1991.

WEBER, M. *Die protestantische Ethik und der "Geist" des Kapitalismus*. Weinheim: Julius Beltz-Athenaeum, 2000 (edição brasileira: WEBER, M. *A ética protestante e o espírito do capitalismo*. São Paulo: Cia. das Letras, 2004).

ZACCARIA, G. *Diritto e positività del diritto*. Torino: Giappichelli, 1991.

ZACCARIA, G. Presentazione. In: ZACCARIA, G. (a cura di). *Diritto positivo e positività del diritto*. Torino: Giappichelli, 1991.

ZAGREBELSKY, G. *Il diritto mite – Legge diritti giustizia*. Torino: Einaudi, 1992.

ZAGREBELSKY, G. *Il sistema costituzionale delle fonti del diritto*. Torino: UTET, 1984.

ZENCOVICH, V. Z. Il 'codice civile europeo', le tradizioni giuridiche nazionali e il neo-positivismo. *Foro Italiano*, 1998, V.

PRINCIPAIS OBRAS PUBLICADAS PELO AUTOR

- *Il dominio e le cose* (O domínio e as coisas). Milano: Giuffrè, 1992.
- *L'ordine giuridico medievale* (A ordem jurídica medieval). Roma-Bari: Laterza, 1995.
- *Assolutismo giuridico e diritto privato* (Absolutismo jurídico e direito privado). Milano: Giuffrè, 1998.
- *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico. 1860-1950* (Ciência jurídica italiana. Um perfil histórico. 1860-1950). Milano: Giuffrè, 2000.
- *Mitologie giuridiche della modernità* (Mitologias jurídicas da modernidade). Milano: Giuffrè, 2001.
- *La cultura del civilista italiano. Un profilo storico* (A cultura do civilista italiano. Um perfil histórico). Milano: Giuffrè, 2002.
- *Prima lezione di diritto* (Primeira lição de direito). Roma-Bari: Laterza, 2003.
- *Il Diritto tra Potere e Ordinamento* (O Direito entre Poder e Ordenamento). Napoli, Scientifica, 2005.